

外國法院定親權及認可收養 未成年子女裁判之承認*

——我國法、德國法、歐盟法及海牙公約之比較研究

陳瑋佑**

摘要

外國法院家事非訟裁判之承認及執行，我國家事法第97條及第186條第2項係準用非訟法第49條及強執法第4條之1為之。然而，關於承認之程序及承認之效果，非訟法第49條並未為明文規定，關於承認之要件，非訟法第49條之設計亦未必全然符合家事非訟事件之特性，而亟待建構穩妥之解釋論；此於外國法院針對「未成年子女親權事件」、「認可收養未成年人事件」所為裁判，尤因涉及兒童權利公約第3條所揭示未成年子女最佳利益原則之具體實踐，而更形迫切。為此，本文乃以外國法院定親權、認可收養未成年人裁判之承認為中心，從事比較法之研究，並在此基礎上，檢討我國學說、實務見解，嘗試於外國法院裁判承認法上具體實踐未成年子女最佳利益原則，進而提出運用我國法之基本方針。

關鍵詞：外國法院裁判之承認與執行、兒童權利公約、未成年子女最佳利益、自動承認、公序良俗、效力延伸說。

* 投稿日：2020年9月23日；接受刊登日：2021年9月10日。〔責任校對：郭宇傑〕。

本文為作者執行科技部專題研究計畫（MOST 108-2410-H-002-158-）之研究成果。作者衷心感謝諸位匿名審稿人之批評與指教，使本文更加完整，惟文責當由作者自負。

** 國立臺灣大學法律學院副教授（wychen0904@ntu.edu.tw）。
穩定網址：<https://publication.iias.sinica.edu.tw/72106022.pdf>。



目次

壹、序論	二、布魯塞爾第二之一規則與海牙兒童保護公約
一、外國法院家事裁判承認法之基本課題	三、海牙兒童收養公約
二、問題之提出：外國法院定親權及認可收養未成年人裁判之承認	參、我國法之規範與解釋
貳、比較法之觀察	一、承認之程序
一、德國家事及非訟法與收養效力法	二、承認之要件
	三、承認之效果
	肆、結論
	後記

壹、序論

一、外國法院家事裁判承認法之基本課題

隨著全球化的進展，除跨國民、商事交易蓬勃成長外，超越國界之身分行為亦益發常見，如何妥適解決相關涉外家事法律爭議，係各個法秩序皆必須面對之課題。其中，外國法院對於個別（家事）事件（如：離婚事件、收養事件、親權事件）之處置（如：准予離婚、認可收養、命交付子女）是否於內國發生如何之效力即外國法院（家事）裁判之承認（及執行）的議題，甚屬重要。蓋以：姑且不論得否自（程序、實體）基本權推論本國承認外國法院有關身分地位裁判（即：形成或確認婚姻或親子關係）之義務¹，如外國法院之裁判得於本國發生一定之效力（如：解消婚姻、發生養親子關係、強制交付子女），即得避免因本國法院作成相矛盾之裁判

¹ 參見Reinhold Geimer, in: Zöller/Althammer (Hrsg.), ZPO, 33. Aufl., 2020, § 328 Rn. 2; Peter Gottwald, in: Krüger/Rauscher (Hrsg.), Münchener Kommentar zur ZPO, Bd. 1, 6. Aufl., 2020, § 328 Rn. 1.

而導致國際間之跛行法律關係（hinkende Rechtsverhältnisse）（如：夫妻於一國已離婚，其婚姻關係於他國仍存在、收養者與被收養者於一國已完成收養，其養親子關係於他國並不存在），並可節省重複審判所耗費之司法資源，以貫徹當事人（或關係人）之實體、程序利益（如：得依外國交付子女之裁判為強制執行，而無庸重新向本國法院請求交付子女）、謀求身分關係所特應重視之法安定性及維護程序經濟²。然而，由於司法資源之節省既非審判制度優先追求之目的，身分關係之內容亦常牽涉一國法秩序之基本價值，故本國尚不能無限制地承認（或執行）外國法院之裁判，而應相當程度予以管控³。因此，外國法院裁判承認法之任務，可謂在於一面促進上開承認外國法院裁判所得實現之公、私益，一面劃定其應退讓於內國正義理念之界限⁴；此事並應反映於其關於以下三大面向之具體規範內容：其一涉及內國設有何種判斷是否承認外國法院裁判之程序即承認程序之面向、其二涉及法院裁判應符合如何之條件始能於內國受承認即承認要件之面向、其三涉及經承認之外國法院裁判得於內國發生如何之效力即承認效果之面向。

在我國，相關統計資料顯示涉外家庭生活已達一定普遍程度⁵，而如當事人向外國法院請求處理因此所衍生之婚姻、（養）親

2 參見許士宦，許可外國民事及家事裁判執行之訴（上），月旦法學教室，206期，頁46（2019年）；蔡華凱，外國裁判承認執行之主、客觀範圍，月旦法學教室，219期，頁26-27（2021年）。

3 參照許耀明，外國確定身分判決之承認與執行，月旦法學教室，51期，頁100-101（2007年）；許士宦（註2），頁48-49。

4 Wolfgang Hau, in: Prütting/Helms (Hrsg.), FamFG Kommentar, 5. Aufl., 2020, § 108 Rn. 3.

5 關於本國籍與外國籍人士離婚之狀況，參見內政部網站，109年第28週內政統計通報，<https://www.moi.gov.tw/cp.aspx?n=11694>（最後瀏覽日：2022年6月26日）；關於外國籍女性於我國生育子女之狀況，參見內政部戶政司網站，人口統計資料，<https://www.ris.gov.tw/app/portal/346>（最後瀏覽日：2022年7月16日）；關於我國兒童或少年跨國收出養之狀況，參見衛生福利部社會及家庭署網站，108年兒童及少年收出養媒合服務概況表，<https://www.sfaa.gov.tw/SFAA/Pages/Detail.aspx?nodeid=421&pid=2667>（最後瀏覽日：2020年7月16日）。

子或繼承等身分法律糾紛，並經該外國法院作成裁判，即有探討我國應否加以承認（及執行）之必要；此類事件亦係我國法院所常受理之涉外事件的一種⁶。就此，除越南、中國法院之裁判及外國法院所核發之（家暴）保護令應適用特別規定外（即：臺越協定19至23、兩岸條例74、家暴28），包含香港及澳門法院（港澳條例42 I）在內之外國法院裁判，應自我國法之觀點，視其得否被定性為針對家事訴訟事件或家事非訟事件所為者，分別適用家事事件法（下稱：家事法）之一般規定承認之⁷：前者（即：家事訴訟裁判）依家事法第51條，準用民事訴訟法（下稱：民訴法）第402條之規定，而後者（即：家事非訟裁判）依家事法第97條，準用非訟事件法（下稱：非訟法）第49條之規定⁸；其具給付性而有予以執行之必要者（如：命賠償離婚損害、命交付子女），則依家事法第186條第2項所準用之強制執行法（下稱：強執法）第4條之1之規定⁹，應

6 關於我國法院受理涉外事件之狀況，參見司法院網站，涉外案件統計：地方法院民事第一審涉外事件終結情形及原告與被告國籍統計表，<https://www.judicial.gov.tw/tw/lp-1774-1.html>（最後瀏覽日：2020年7月16日）。

7 參見許士宦（註2），頁46；關於應依承認國法對於外國法院裁判進行定性以決定應適用之外國法院裁判承認規範，參見沈冠伶，親權及交付子女事件之外國裁判的承認及執行與「未成年子女最佳利益保護」原則，收於：民事程序法之新變革，頁335（2009年）；許士宦（註2），頁59；亦參照 Rolf Wagner, *Ausländische Entscheidungen, Rechtsgeschäfte und Rechtslagen im Familienrecht aus der Sicht des autonomen deutschen Rechts — Eine Neubearbeitung*, FamRZ 2013, S. 1620 (1625)，氏指出，理論上雖不無依裁判國法對於該國法院裁判進行定性之餘地，惟此事在實際上常容易導致程序之延滯，而仍宜依承認國法為之；西谷祐子，人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄等に関する新法制（2・完），法曹時報，71卷4号，頁748（2019年）。

8 應附言者係：在外國法院裁判之標的依我國法應定性為家事非訟事件的情形（參見前揭註7），我國實務向來常忽視其應適（準）用之承認規範為非訟法第49條，而仍逕行適用民訴法第402條（如：臺灣高等法院105年度家上字第195號民事判決、臺灣高等法院臺南分院105年度重家上字第7號民事判決、臺灣高等法院高雄分院100年度上易字第316號民事判決），此事實會因非訟法與民訴法後述規範內容之差異，而導致未必妥適之結果（保留見解：沈冠伶（註7），頁335註6）。

9 參見許士宦（註2），頁46-47。

先經我國法院宣告准予執行（所謂執行宣告），始得為之¹⁰。

前揭承認（及執行）外國法院家事裁判之規範，就家事法之一般規定而言，實有其簡略性，而不論在前揭承認程序、承認要件及承認效果之面向上，均存在相當程度之疑義¹¹；此又以家事法第97條準用非訟法第49條之規定所生者，尤待澄清¹²：

首先，關於承認之程序，雖應認為我國法採取自動承認制，亦即，除前述許可執行程序外（家事186 II、強執4-1），外國法院家事非訟裁判符合承認要件者，無庸先經我國法院（或其他公權機關）行一定之承認程序予以確認，即得於我國自動發生其效力¹³，惟此事是否表示我國法並不容許獨立之承認確認程序¹⁴？

其次，關於承認之要件，(1)非訟法第49條所謂確定裁判，是否一概排除尚得依外國法救濟之實體裁判或欠缺本案終局性之暫時處分？又是否涵蓋外國法院程序上之和解、調解甚或公權主體所核發或辦理之證書、登記？(2)非訟法第49條第1款所謂用以決定外國法院有無承認管轄權（或稱：間接管轄權）之中華民國法律，究何所指？(3)非訟法第49條第2款僅保障中華民國人免遭聽審請求權之剝奪，又未要求程序開始文書之送達應具備一定之適式性，是否妥

10 關於外國法院裁判之「承認」及「執行」之概念區別及其政策基礎，參見劉鐵錚、陳榮傳，國際私法論，修訂6版，頁647（2018年）；陳啓垂，外國判決的承認與執行，月旦法學雜誌，75期，頁149（2001年）。

11 類似觀察：Florian Loyal, Zur Struktur und Dogmatik der Anerkennung ausländischer Gerichtsentscheidungen, ZZP 131 (2018), S. 373 (373).

12 關於家事法第51條所準用之民訴法第402條的解釋適用，僅參見劉鐵錚、陳榮傳（註10），頁649-669；柯澤東著、吳光平增修，國際私法，5版，頁360-365（2016年）；李後政，國際民事訴訟法論，增訂3版，頁301-323（2015年）；邱聯恭，口述民事訴訟法講義（三），2017年筆記版，頁149-155（2017年）；陳啓垂（註10），頁147；陳啓垂，承認外國判決的效力及程序，月旦法學雜誌，235期，頁219（2014年）；蔡華凱（註2），頁27-28。

13 許士宦（註2），頁46；最高法院104年度台上字第1085號民事判決。

14 如：臺灣臺北地方法院109年度家聲字第46號民事裁定；臺灣高雄少年及家事法院108年度家聲字第260號民事裁定。

當？(4)非訟法第49條第3款所定之公序良俗，是否包含程序法與實體法之面向？我國法院應依何標準、以何時間點為基準，判斷外國法院家事非訟裁判是否牴觸我國之公序良俗？(5)非訟法第49條第4款緩和相互保證（或稱：互惠原則）要求，有無合理依據？

再者，關於承認之效果，符合承認要件之外國法院家事非訟裁判，其得於我國發生之效力，究係延伸、擴張自裁判國所本來有之者¹⁵、視同我國法院之裁判¹⁶，抑或鑑於（家事）非訟事件所呈現程序法與實體法之緊密連結¹⁷，而取決於我國涉外民事法律適用法（下稱：涉民法）之內容及其所指定原因關係準據法（*lex causae*）之立場¹⁸？

二、問題之提出：外國法院定親權及認可收養未成年人裁判之承認

於應依家事法第97條準用非訟法第49條之規定承認的外國法院裁判中，宜優先回應上述（「壹、一」）承認之程序、承認之要件及承認之效果所涉疑問者，係外國法院針對酌定、改定、停止親權、交付子女或酌定會面交往之方式及期間之「未成年子女親權事件」（家事3 V ⑧至⑩）及「認可收養未成年人事件」（家事3 IV ⑦）所為之裁判（下泛稱：外國法院定親權、認可收養未成年人裁判）。茲各舉一則我國實務上頗值檢討之案例如下：

【事例一¹⁹】X（妻）與Y（夫）婚後育有A1、A2二名子女。X、Y、A1及A2均具美國籍且共同定居於美國（德州）。嗣Y於2014年間攜A2（時年約3歲）至我國探親後，決定

15 如：許士宦（註2），頁50-51。

16 如：臺灣高等法院104年度家上字第265號民事判決。

17 *Geimer* (Fn. 1), vor § 97 FamFG Rn. 13.

18 如：最高法院103年度台簡抗字第182號民事裁定。

19 案例事實簡化自：最高法院107年度台上字第2469號民事裁定及其歷審判決。

不再偕同A2返美，並向我國法院對X提起離婚訴訟。X旋向美國（德州）法院對Y提起離婚等訴訟，經該院於2015年間駁回Y委託美國B律師所為之管轄抗辯，而以缺席判決（default judgment）准兩造離婚，且未經訪視或調查即酌定X為A2之單獨親權人（sole managing conservator）；此二項裁判均未據上訴而告確定。X乃向我國法院請求許可該美國法院裁判關於指定X為A2之單獨親權人及Y應交付A2予X之強制執行，經我國法院認無民訴法第402條第1項各款情事而容認確定；其理由略為：類推適用家事法第52條第1項之規定，美國法院有離婚事件之管轄權，並得附帶取得酌定親權事件之管轄權。美國法律未明定酌定親權前應訪視評估、美國法院亦未為訪視評估等事，雖與我國家事法所要求者不同，惟不當然違背我國之公序良俗，何況Y未於美國法院酌定親權之程序上為實體陳述，亦未於裁判後尋求救濟，自不能再爭執其違反公序良俗；此外，美國法院裁判中既已表明其處置合於A2之最佳利益，即與民法第1055條之1之意旨相符，難謂有違我國之公序良俗²⁰。

【事例二²¹】X（夫）與Z（妻）婚後育有A女。X具我國籍且定居於我國，A雖亦具我國籍，惟於出生後不久即由Z委託其母Y照護，並與Y共同定居於日本。嗣X與Z於2010年間協議離婚，並約定由Z任A之單獨親權人。越3年，Y及其日本籍之夫B共同收養A（時年約5歲），經日本法院以合於A身心發展之最佳利益為由准許之；Z則於同年間因病死亡。X即向我國法院聲請命Y交付A予X，經

²⁰ 臺灣高等法院105年度家上字第195號民事判決。

²¹ 案例事實簡化自：最高法院103年度台簡抗字第182號民事裁定及其歷審裁定。

我國法院容認確定；其理由略為：Y、B與A間之收養是否有效，依照我國涉民法第54條第1項之規定，除適用日本法外，並應適用我國法；A為Y、B之直系血親、直系姻親，且未經X之同意，其收養亦未受我國法院認可，依照民法第1079條之4規定係屬無效。系爭收養既不生效力，則於Y死亡後，X為A之當然親權人，自得請求Y排除對其親權之妨害²²。

前揭研究範圍之限定，除因案件數量多寡以及【事例一】、【事例二】所顯現我國實務對於外國法院家事非訟裁判承認法之陌生程度，而不無實際上之迫切性外，亦有其理論上之正當性：一方面，「未成年子女親權事件」與「認可收養未成年人事件」係家事非訟事件中，需求法院之保護照顧且具公益性之所謂本質上非訟事件²³，而能一定程度代表其他相類似者（如：未成年人監護事件、監護或輔助宣告事件、保護安置事件）；至於偏重法院之權利判定且具私益性之所謂真正訟爭事件（如：夫妻同居或給付家庭生活費用事件、宣告終止收養成年人事件、親屬間扶養事件）²⁴，則多可比照性質上相同之家事訴訟事件（如：離婚事件、確認親子關係事件、夫妻財產分配事件），而參考家事法第51條所準用之民訴法第402條運作非訟法第49條之規定²⁵。另一方面，「未成年子女親權事

22 臺灣臺中地方法院103年度家聲抗字第100號民事裁定。

23 關於家事法所定家事非訟事件中之本質上非訟事件，參見沈冠伶，家事非訟裁定之效力，收於：家事程序之新變革，頁180（2015年）；李太正，家事事件法之理論與實務，5版，頁62-63（2018年）。

24 關於家事法所定家事非訟事件中之真正訟爭事件，參見許士宦，家事非訟之程序保障，收於：家事審判與債務執行，頁30-36（2013年）；李太正（註23），頁62-63。

25 類似見解：山本和彥，國際非訟事件における手続上の諸問題，判例タイムズ，1361号，頁70（2012年）；應附言者係：外國法院針對家事非訟事件中之真正訟爭事件所為裁判，其承認雖在解釋論上宜比照外國法院針對家事訴訟事件所為者行之，惟此並不表示應全面追隨同於外國法院針對民事訴訟事件所為裁判之處理模式，蓋家事訴訟事件本應再區分為家事身分事件與家事財產事件二類

件」與「認可收養未成年人事件」既涉及法院所採取直接調整、變動（未滿18歲）未成年子女家庭生活之措施，自必須符合1989年聯合國兒童權利公約（Convention on the Rights of the Child，下稱：兒童權利公約）第3條第1項所揭示之未成年子女最佳利益（best interests of the child）原則（兒權施2）²⁶，此項原則於我國法院決

- （參見許士宦，家事審判之請求，收於：家事事件法論，頁5-13（2019年）），而外國法院之家事財產訴訟裁判固多得依據向來關於民訴法第402條之見解加以承認（關於外國法院分配夫妻財產裁判之承認，參見徐美貞，外國離婚判決承認與執行——兼論最高法院96年台上字第582號判決，真理財經法學，14期，頁96-97、99-100（2015年）），然外國法院之家事身分訴訟裁判則未必適合原樣移用之（關於外國法院確認親子關係裁判之承認，參見小林貴典，論涉外代孕案件中外國裁判之承認，臺北大學法學論叢，103期，頁235-247（2017年））。
- 26 兒童權利公約第3條第1項：「所有關係兒童之事務，無論是由公私社會福利機構、法院、行政機關或立法機關作為，均應以兒童最佳利益為優先考量」；應說明者係：兒童權利公約第3條第1項之規定，係與同公約第2條、第6條及第12條之規定並列為兒童權利公約之四大基本原則（參見聯合國兒童權利委員會第5號一般性意見（CRC, General Comment No. 5, CRC/GC/2003/5）段碼12），該條項所揭櫫之未成年子女最佳利益原則，更可謂係兒童權利公約本身存在之理由（*Stefanie Schmahl*, Kinderrechtskonvention mit Zusatzprotokollen, 2. Aufl., 2017, Art. 3 Rn. 1）。未成年子女最佳利益原則之內容，可自其所具實體權利（substantive right）、解釋原則（interpretative legal principle）及程序規則（rule of procedure）之三重性質（參見聯合國兒童權利委員會第14號一般性意見（CRC, General Comment No. 14, CRC/C/GC/14）段碼6）加以分析（另參照林沛君，由聯合國兒童權利委員會第14號一般性意見重新檢視「子女最佳利益」，華岡法粹，58期，頁139（2015年））：其實體權利之面向係具體呈現於與兒童權利公約所臚列之兒童（實體）權利及國家相對應之義務（參見施慧玲，從《聯合國兒童權利公約》到子女最佳利益原則——兼談法律資訊之應用與台日比較研究方法，台灣國際法季刊，8卷2期，頁100-101（2011年）），蓋此等權利義務規範之解釋均應依未成年子女最佳利益原則為之（參見前揭第14號一般性意見段碼51）；其解釋原則面向係於兒童權利與他人（含：父母、其他兒童）之權利甚或公共利益有所衝突時（參見MICHAEL FREEMAN, A COMMENTARY ON THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD, ARTICLE 3: THE BEST INTERESTS OF THE CHILD 62-64（2007）），要求優先謀求兒童權利之貫徹，而發揮分配論證負擔（即：採取不利於兒童之措施者應說明理由）之功用（參見*Schmahl*, ebd. Art. 3 Rn. 4 f.）；其程序規則面向則展現於保障兒童之參與權（participation）即其聽審請求權（the right to be heard）（兒權12）與探求未成年子女最佳利益間之強烈關連性（參見前揭第14號一般性意見段碼43：「……第3條第1項之正確適用係以滿足第12條之要求為前提……」），國際上並咸認使兒童表示意見並加以斟酌一事，係最能貫徹兒童之保護及實現其利益的途徑（*Schmahl*, ebd. Einl. Rn. 28）。準此，於有關單位（如：法院）決定是否採取如

定是否或如何承認外國法院定親權、認可收養未成年人裁判時，無疑亦有其適用²⁷；如能釐清未成年子女最佳利益原則於承認該等外國法院裁判之程序、要件及效果上的作用，即有助於類型化此一不確定法律概念²⁸，進而形塑外國法院裁判承認法乃至於一般國際民事程序法上未成年子女最佳利益原則之具體內容²⁹。

為妥適解決前揭非訟法第49條之解釋論上疑義，宜參考比較法上之規範狀態。此不僅因非訟法第49條係繼受自德國（舊）非訟法第16條之1³⁰，而含有外國法之要素所應然。為儘可能實現國際間法律關係之一致性或裁判之無矛盾性，亦不應漠視外國法院裁判承

何之兒童相關措施（如：酌定會面交往方式及期間），而應運用未成年子女最佳利益原則時，必須在該兒童適當、充分參與的基礎上（參見前揭第14號一般性意見段碼85-99），斟酌(1)兒童之意願、(2)兒童之（社會、文化或個人）身分、(3)家庭完整性之維持、(4)兒童之安全照護、(5)兒童所處之弱勢情境、(6)兒童之健康權、(7)兒童之受教權等因素（參見前揭第14號一般性意見段碼52-79），形成最能兼顧各種（互相衝突之）兒童權利的方案（*Schmahl*, ebd. Art. 3 Rn. 12），再與可能因此受影響之他人權益或公益進行利益衡量，除非後者遠大於前者，否則一般而言並無放棄或調整該方案之必要（同旨：前揭第14號一般性意見段碼39）。

27 參照 *Bettina Heiderhoff*, Das Kindeswohl im internationalen Familienverfahren, in: Schütze (Hrsg.), Fairness Justice Equity, Festschrift für Reinhold Geimer zum 80. Geburtstag, 2017, S. 231 (231)（以下簡稱：*Heiderhoff*, FS Geimer）；*Bettina Heiderhoff*, Kindeswohl im europäischen Familienverfahren — ein Lippenbekenntnis?, in: Budzikiewicz u. a. (Hrsg.), Standards und Abgrenzungen im Internationalen Familienrecht, 2019, S. 39 (67, 72)（以下簡稱：*Heiderhoff*, Standards und Abgrenzungen）。

28 關於未成年子女最佳利益作為法律概念之不確定性，參見鄧學仁，子女最佳利益之適用爭議與發展方向，台灣法學雜誌，155期，頁45-46（2010年）；*Schmahl* (Fn. 26), Art. 3 Rn. 9; FREEMAN, *supra* note 26, at 27.

29 關於國際管轄法上未成年子女最佳利益原則之具體內容，參見陳瑋佑，國際家事管轄法之比較研究——以未成年子女親權事件為中心，中研院法學期刊，25期，頁247-248、262-263（2019年）。

30 2005年非訟法第49條增訂理由二：「現今交通發達，國際間往來頻繁，外國法院之非訟事件裁判若於我國聲請承認，應如何處理，殊有明定必要，以保障關係人之權益，爰參考民事訴訟法第四百零二條、德國非訟事件法第十六條之一之例，增設本條，對外國法院之確定非訟事件裁判，原則上承認其效力，僅於外國法院裁判有下列情形時，始不認其效力……」。

認法之國際發展；尤其係以實踐未成年子女最佳利益原則為目標之外國法秩序，更屬我國為履行保障兒童權利之義務（兒權4）所不得不加以顧慮者³¹。準此，著眼於法律繼受之淵源、國際統合之成果及體現未成年子女最佳利益之指標意義，本文選擇以（2021年修正前）德國家事及非訟事件程序法（下稱：家事及非訟法³²）及（2021年修正前）依外國法收養未成年子女效力法（下稱：收養效力法³³）為主要參照對象，並在制度設計上有所差異的限度內，附帶引介（現行）歐盟婚姻及親權程序之管轄及承認與執行規則（下稱：布魯塞爾第二之一規則）³⁴、海牙親權及子女保護措施之管轄、準據法、承認與執行及合作公約（下稱：海牙兒童保護公約³⁵）及海牙兒童保護及跨國收養合作公約（下稱：海牙兒童收養公約）³⁶，期能利用此等比較法研究之結果，進一步理解、反省並改善我國家事法第97條、非訟法第49條之解釋適用³⁷。

31 關於國際公約或統一法之解釋原則，參見Uwe Kischel, Rechtsvergleichung, 2015, § 2 Rn. 55; Theodor Schilling, Internationaler Menschenrechtsschutz, 2. Aufl., 2010, Rn. 37 f.

32 Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG).

33 Gesetz über Wirkungen der Annahme als Kind nach ausländischem Recht (Adoptionswirkungsgesetz — AdWirkG).

34 Die VO (EG) 2201/2003 des Rates vom 27.11.2003 über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung (Brüssel IIa-VO).

35 Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children, Oct. 19, 1996, 2204 U.N.T.S. 503; 依照海牙國際私法會議（HCCH）官網之統計，截至2022年6月26日止，本公約之締約國為53國（HCCH, <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=70> (last visited June 26, 2022)）。

36 Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption, May 29, 1993, 1870 U.N.T.S. 167; 依照海牙國際私法會議官網之統計，截至2022年6月26日止，本公約之締約國已達104國（HCCH, <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=69> (last visited June 26, 2022)）。

37 關於所謂比較法解釋方法之意義，參見Kischel (Fn. 31), § 2 Rn. 63 f.; Franz Reimer, Juristische Methodenlehre, 2016, Rn. 396; Georg E. Kodek, Rechtsvergleichung als

以下即先說明德國法上關於「未成年子女親權事件」及「認可收養未成年人事件」之外國裁判承認規範（下述「貳、一」），再對照其分別與布魯塞爾第二之一規則、海牙兒童保護公約（下述「貳、二」）及海牙兒童收養公約（下述「貳、三」）之異同。在瞭解外國及國際法之現況的基礎上，嘗試建構我國外國法院家事非訟裁判承認法之應有內涵（下述「參」）。最後則整理本文論點並簡析【事例一】、【事例二】之判旨（下述「肆」）。

貳、比較法之觀察

一、德國家事及非訟法與收養效力法

德國法上關於外國法院家事裁判之承認（及執行），係規定於家事及非訟法第107條至第110條：第107條及第108條分別規定婚姻事件及其他事件之承認程序、第109條規定拒絕承認事由（*Anerkennungshindernisse*），而第110條則規定外國給付裁判之執行力；其中，涉及父母親權、會面交往權及交付子女而相當於本文所稱「未成年子女親權事件」之「父母責任（*elterliche Verantwortung*）事件」（德家非151 ①至③）者，係適用同法第108條、第109條第1項、第5項及第110條第1項，而涉及「收養未成年人事件」（德家非186 ①）者，則適用同法第108條第1項、德國收養效力法第2條、第5條及第6條（德家非108 II 3）³⁸、家事及非訟

Auslegungsmethode im Privatrecht — akademischer Aufputz oder Bereicherung?, in: Gamper/Verschraegen (Hrsg.), Rechtsvergleichung als Juristische Auslegungsmethode, 2013, S. 23 (50 f.); *Susanne Augenhöfer*, in: Krüper (Hrsg.), Grundlagen des Rechts, 2. Aufl., 2013, § 10 Rn. 28, 氏指出，外國法之論據得對於本國司法實務發揮啟發及控制之機能；關於「選擇比較對象」之考量因素，參見陳瑋佑（註29），頁213-214。

³⁸ 應附言者係：依照德國收養效力法第1條之規定，該法不僅適用於本文所探討之外國收養中的宣告收養（*Dekretadoption*），亦及於契約收養（*Vertragsadoption*）

法第109條第1項及第5項。依照家事及非訟法第97條第1項之規定，國際協議及歐盟法應優先於本國法受適用，因此，有關外國法院定親權裁判之承認（及執行），應優先適用布魯塞爾第二之一規則或海牙兒童保護公約之相關規定（下述「貳、二」）³⁹，而有關外國法院認可收養未成年人裁判之承認，則應優先適用海牙兒童收養公約之相關規定（下述「貳、三」）⁴⁰；不過，由於國際協議及歐盟法之宗旨在於促進裁判之國際流通性，而非加以阻礙，故針對國際協議、歐盟法與本國法間之關係，不宜採取嚴格之優先原則（Vorrangsprinzip），而原則上應承認優惠原則（Günstigkeitsprinzip），如外國裁判不能依上開布魯塞爾第二之一規則、海牙兒童保護公約或海牙兒童收養公約受承認（或執行），仍得依德國家事及非訟法（或收養效力法）為之⁴¹。

（一）承認之程序

1. 基本原則

德國家事及非訟法第108條第1項規定：「除婚姻事件及收養效力法第1條第2項所定裁判外，外國裁判之承認，無庸依特別之程序為之」。依照此項承繼（舊）非訟法第16條之1並參照民訴法第328條所設之規定，外國法院針對非婚姻事件所為之家事或非訟裁判，

及以外國法為準據法之內國收養，且不限於完全（或稱：斷絕型）收養（Volladoption、starke Adoption），亦包含單純（或稱：非斷絕型）收養（schwache Adoption）（僅參見Tobias Helms, in: von Hein (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bd. 12, 8. Aufl., 2020, § 1 AdWirkG Rn. 2 f., 7 f.）。

39 關於「父母責任事件」之承認法上法源及適用順序，參見 Rainer Hausmann, Internationales und Europäisches Familienrecht, 2. Aufl., 2018, N. Rn. 13 ff.

40 關於「收養未成年人事件」之承認法上法源及適用順序，參見 Hausmann (Fn. 39), P. Rn. 1 ff.

41 Hau (Fn. 4), § 109 Rn. 3 f.; 關於布魯塞爾第二之一規則是否承認優惠原則之爭議，參見 Robert Sieghörtner, in: Hahne/Schlögel/Schlünder (Hrsg.), BeckOK FamFG, 35. Aufl., Stand: 01.07.2020, § 108 Rn. 4; 關於海牙兒童收養公約是否承認優先原則之爭議，參見 Sieghörtner, ebd. § 108 Rn. 24.

係採取自動承認制⁴²。亦即，如不存在家事及非訟法第109條所列之拒絕承認事由，外國裁判即得依法（*ipso iure*）於德國發生一定之效力，而無庸先經德國法院（或其他公權機關）行承認程序（*Delibationsverfahren*）賦予之⁴³；其具給付性而有予以執行之必要者，除涉及家事及非訟法第95條第1項所定義務之執行者外（如：命給付離婚慰撫金、命遷出住居所），亦不須先經德國法院為執行宣告（*Exequatur*）（德家非110），即得逕行為之⁴⁴。不過，此並不表示外國裁判是否符合德國法上之承認要件（詳後述）一事，無庸接受任何審查，毋寧是，如德國法院（或其他公權機關）所受理之事件，係取決於外國裁判於德國是否亦生效力（如：外交機關是否核發依親簽證，係取決於外國法院定親權裁判是否有效⁴⁵、土地登記機關是否辦理繼承登記，係取決於外國法院核發之繼承證書是否有效⁴⁶），即應於該事件處理程序上間接判定承認要件之該當性，而確認其有無所謂承認適格性（*Anerkennungsfähigkeit*）⁴⁷；此於依外國給付裁判所為之強制執行事件，亦然⁴⁸。

42 BT-Drucks. 16/6308, S. 222.

43 Thomas Rauscher, in: Rauscher (Hrsg.), Münchener Kommentar zum FamFG, Bd. 1, 3. Aufl., 2018, § 108 Rn. 21; Ulrich Spellenberg, in: Spellenberg/Henrich (Hrsg.), J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: Internationales Verfahrensrecht in Ehesachen, Bd. 2, 2016, § 108 FamFG Rn. 165; Hau (Fn. 4), § 108 Rn. 39.

44 BT-Drucks. 16/6308, S. 222.

45 BVerwG, FamRZ 2013, S. 547, Rz. 17 ff.; 亦參見Rauscher (Fn. 43), § 108 Rn. 22 aE，氏強調，外國法院裁判是否符合德國法上承認要件一事，不僅應於民事事件受審查，於以身分地位或親屬狀態（如：親權歸屬）為程序標的法律關係要件之行政程序或行政訴訟，尤有加以審查之必要。

46 Jörg Dimmler, in: Keidel/Engelhardt/Sternal (Hrsg.), FamFG, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 20. Aufl., 2020, § 108 Rn. 11.

47 Rauscher (Fn. 43), § 108 Rn. 22; Dimmler (Fn. 46), § 108 Rn. 11.

48 BT-Drucks. 16/6308, S. 222：「……外國裁判欠缺承認適格性者，即不得執行之。因此，外國裁判之承認……應作為先決問題加以審查」。

上開亦被稱為中間承認（*Inzidentanererkennung*）之規範模式⁴⁹，儘管有助於促進裁判於內、外國間之流通性，可是，由於外國裁判之承認適格性係在各該事件中作為（實體法或程序法上）先決問題而由不同機關判斷，且一機關認定之結果並無拘束他機關之效力，故難免會發生裁判之矛盾（如：外國法院解消伴侶關係裁判是否符合承認要件，分別於贍養費事件及伴侶財產分配事件遭不同之判定）⁵⁰，而背反於法安定性之要求⁵¹。因此，受啟發於布魯塞爾第二之一規則第21條第3項、海牙兒童保護公約第24條等規定⁵²，家事及非訟法第108條第2項明定：「對於外國非財產權裁判之承認與否有法律上利益之關係人，得聲請法院裁判之。第107條第9項之規定，準用之。（略）」，而針對非以財產權為內容之外國裁判（如：自然血親事件、親子關係事件、成年輔助事件）⁵³，創設獨立、任意之承認確認程序（*Anerkennungsfeststellungsverfahren*）⁵⁴，允許因承認之結果而法律地位受影響之人（如：繼承人之於外國法院確認親子關係裁判）⁵⁵，請求德國法院確認外國裁判是否具備承認要

49 關於「自動承認」與「中間承認」之用語選擇，參見Abbo Junker, Internationales Zivilprozessrecht, 4. Aufl., 2019, § 27 Rn. 9.

50 Spellenberg (Fn. 43), § 108 FamFG Rn. 165.

51 Haimo Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht mit internationalem Insolvenzrecht und Schiedsverfahrensrecht, 7. Aufl., 2017, Rn. 971（以下簡稱：*Schack*, IZVR⁷）；亦參見Haimo Schack, Das Anerkennungsverfahren in Ehesachen nach § 107 FamFG — Vorbild für Europa?, in: Bernreuther u. a. (Hrsg.), Festschrift für Ulrich Spellenberg zum 70. Geburtstag, 2010, S. 497 (498)（以下簡稱：*Schack*, FS Spellenberg），氏強調，於涉及身分地位之事件（*Statusangelegenheit*），法安定性即裁判之一致性係最為重要之考量。

52 Christoph Althammer, Verfahren mit Auslandsbezug nach dem neuen FamFG, IPRax 2009, S. 381 (387).

53 Rauscher (Fn. 43), § 108 Rn. 23.

54 BT-Drucks. 16/6308, S. 222；應附言者係：如外國法院裁判之標的依德國法應定性為非訟事件，則其承認確認程序亦屬非訟事件，而應適用家事及非訟法第2條以下之一般規定（*Hau* (Fn. 4), § 108 Rn. 60；另參照Fabian Klinck, Das neue Verfahren zur Anerkennung ausländischer Entscheidungen nach § 108 Abs. II S. 1 FamFG, FamRZ 2009, S. 741 (748)）。

55 Dimmler (Fn. 46), § 108 Rn. 91; Sieghörtner (Fn. 41), § 108 Rn. 50.

件⁵⁶，並賦予該（積極或消極）確認裁判之既判力拘束全體法院及行政機關的對世效（*erga omnes*）⁵⁷；同樣的設計，亦早見於德國收養效力法第2條及第5條第2項（詳後述）。

無論承認適格性係作為先決問題於各該事件中受審查，或作為主要問題於承認確認程序上受審查（下合稱：承認適格判定程序），均應適用家事及非訟法第109條第5項延續（舊）非訟法第16條之1之解釋論所明文規定之禁止實質再審查原則（*Verbot der révision au fond*）⁵⁸；家事及非訟法第109條第5項謂：「外國裁判之適法性，不得審查之」。亦即，審查之對象僅限於承認要件之滿足與否，而不及於外國裁判之內容或程序是否適法⁵⁹，蓋基於司法等價原則，原則上應對於外國裁判採取與本國裁判相同之態度，而接受其可能之違背法令情事⁶⁰；外國裁判之瑕疵，基本上應於該外國加以救濟，而非於德國謀求其排除⁶¹。依照上開禁止實質再審查原則，不僅外國法院認定事實或適用（實體、程序）法律有無違誤，並非所問，其審判結果是否與德國強行法規所要求者相符合⁶²，或準據法之選擇是否與德國衝突法所指定者相一致⁶³，亦不屬審查之

56 *Hau* (Fn. 4), § 108 Rn. 62; *Dimmler* (Fn. 46), § 108 Rn. 86.

57 *Dimmler* (Fn. 46), § 108 Rn. 86, § 107 Rn. 54; *Hau* (Fn. 4), § 108 Rn. 2, 62.

58 *Althammer* (Fn. 52), S. 387; *Rauscher* (Fn. 43), § 109 Rn. 2.

59 *Dimmler* (Fn. 46), § 109 Rn. 33.

60 *Hau* (Fn. 4), § 109 Rn. 18; *Schack*, IZVR⁷ (Fn. 51), Rn. 39.

61 *Hau* (Fn. 4), § 109 Rn. 44; *Dimmler* (Fn. 46), § 109 Rn. 33.

62 BGH, FamRZ 2018, S. 1846, Rz. 15; BGH, FamRZ 2015, S. 240, Rz. 28.

63 *Rauscher* (Fn. 43), § 109 Rn. 10; *Sieghörtner* (Fn. 41), § 109 Rn. 49; *Spellenberg* (Fn. 43), § 109 FamFG Rn. 5，氏並指出，此亦係衝突法上「實質法秩序等價原則」之展現。應附言者係：德國（舊）民訴法第328條第1項第3款原本在一定條件下，將外國裁判違背德國（舊）民法施行法第13條、第17條、第18條、第22條所定法律衝突規則（如：離婚準據法、收養準據法）列為「拒絕承認事由」，嗣1986年之國際私法改正法案（IPR-Novelle）以其背反禁止實質再審查原則且外國裁判之承認不宜過度著重衝突法等理由加以刪除（BT-Drucks. 10/504, S. 88；另參見Jan Kropholler, Internationales Privatrecht, 4. Aufl., 2001, S. 631，氏認為，立法者所謂外國裁判之承認不宜過度著重衝突法云云，係指不宜以衝突法之考量過度限縮外國裁判之承認）。此項亦邏輯一貫地反映於德國（舊）非訟

標的。不過，正由於外國裁判係在其內容或審判程序不經實質審查之情況下被承認，而可能產生本國法律或社會秩序所不能接受之後果，故為維護更重大之個人權利或公益，仍必須例外容許某程度之實質再審查⁶⁴；此即承認法上保留公共秩序（*ordre public*）（即：公序良俗，下簡稱：公序）作為拒絕承認事由（德家非109 I ④）之法理基礎⁶⁵。

2. 父母責任事件

上述（「貳、一、（一）、1.」）德國家事及非訟法所採取之自動承認制、承認確認程序及禁止實質再審查原則，均適用於外國法院定親權裁判之承認：首先，外國法院定親權裁判於德國係自動發生效力（德家非108 I）⁶⁶；其具給付性者（如：命交付子女、容忍會面交往），亦無須循許可執行程序取得執行力，而得逕依家事及非訟法第86條以下之規定，聲請法院予以執行（德家非110 I）⁶⁷。其次，尤其係不具給付性之外國法院定親權裁判（如：酌定父或母為單獨親權人），多有透過獨立之承認確認程序（德家非108 II）謀求法安定性之實際需求⁶⁸；其承認適格性之有無，於德國法院、行政機關間遭歧異認定或於父母、其他親權人間有所爭執者，即存在加

法第16條之1規定之立法（BT-Drucks. 10/504, S. 93），正顯示國際民事程序法相對於國際私法之優先性（參見Schack, IZVR⁷ (Fn. 51), Rn. 962; Kropholler, ebd. S. 632，氏認為，此一修法雖伴隨德國衝突規範失其一部效用，而增加當事人任擇法庭以規避德國法院所應適用之法的缺點，惟鑑於承認外國裁判有其更大之利益，而仍宜加以接受）。

⁶⁴ Geimer (Fn. 1), § 328 Rn. 209; Helmut Borth/Mathias Grandel, in: Musielak (Hrsg.), Familiengerichtliches Verfahren 1. und 2. Buch FamFG, 6. Aufl., 2018, § 109 Rn. 7; Sieghörtner (Fn. 41), § 109 Rn. 31.

⁶⁵ Spellenberg (Fn. 43), § 109 FamFG Rn. 225; Hau (Fn. 4), § 109 Rn. 18 aE.

⁶⁶ Hausmann (Fn. 39), N. Rn. 617; Marianne Andrae, Internationales Familienrecht, 3. Aufl., 2014, § 6 Rn. 152.

⁶⁷ Hausmann (Fn. 39), N. Rn. 660; Andrae (Fn. 66), § 6 Rn. 196.

⁶⁸ Hau (Fn. 4), § 108 Rn. 54; Hausmann (Fn. 39), N. Rn. 618.

以確認之法律上利益⁶⁹，法院得依關係人（德家非7）之聲請⁷⁰，依親子關係事件所應適用之程序規範（如：非律師強制代理）以裁定（德家非38 I）確認之⁷¹。此外，在不牴觸德國公序之限度內，外國法院定親權裁判之內容或審判程序有無違背法令、其準據法之選擇是否與德國法律衝突規定（如：海牙兒保16、17、德民施21）所指定者相一致，在所不問⁷²；此亦不因此類裁判涉及未成年子女最佳利益（Kindeswohl）之保護⁷³，而有所不同⁷⁴。

3. 收養未成年人事件

上述（「貳、一、（一）、1.」）德國家事及非訟法所採取之自動承認制及禁止實質再審查原則，原則上亦適用於外國法院認可收養未成年人裁判之承認：一方面，外國法院認可收養未成年人裁判，除不得依（後述）海牙兒童收養公約予以承認者外，於德國係自動發生效力（德家非108 I）⁷⁵，另一方面，其內容或審判程序是否適

69 Hausmann (Fn. 39), N. Rn. 619.

70 Andrae (Fn. 66), § 6 Rn. 152, § 5 Rn. 79; Dimmler (Fn. 46), § 108 Rn. 90.

71 Hausmann (Fn. 39), N. Rn. 621.

72 Hausmann (Fn. 39), N. Rn. 656.

73 關於德文「Kindeswohl」與英文「best interest of the child」之同義性，參見Schmahl (Fn. 26), Art. 3 Rn. 2.

74 參照Heiderhoff, FS Geimer (Fn. 27), S. 237.

75 Hausmann (Fn. 39), P. Rn. 108; Andrae (Fn. 66), § 7 Rn. 64；不同見解：Dieter Henrich, in: Henrich/von Hein (Hrsg.), J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Artikel 19 — 24 EGBGB, 2019, Art. 22 EGBGB Rn. 85；應附言者係：2002年收養效力法立法時，立法者基於維持（舊）非訟法第16條之1促進外國法院裁判流通性之基本立場等考量，認為無庸採取「裁判承認制」，而以獨立、任意之承認及效力確認程序（詳後述）為已足（BT-Drucks. 14/6011, S. 32 f.）。不過，2021年之收養協助法案（Adoptionshilfe-Gesetz），則為遏制未經中介機構媒合之國外收養，以確保未成年子女之最佳利益，增訂收養效力法第1條第2項，針對不得依海牙兒童收養公約予以承認之外國裁判，改採裁判承認制，亦即，此類外國法院認可收養未成年子女之裁判，未經德國法院確認其承認適格性者，於德國不生效力，收養者尚未取得父母之地位（BT-Drucks. 19/16718, S. 29, 59）；後一修法，亦符合德國（行政）實務上要求收養者先進行收養效力法所定程序並取得確裁判，始允許入境之常態（參見Helms (Fn. 38), § 2 AdWirkG Rn. 1）。

法、準據法之選擇是否合於德國法律衝突規則（即：德民施22、23），均不受審查⁷⁶。

相對於此，前揭德國家事及非訟法所設之承認確認程序，並不適用於外國法院認可收養未成年人裁判之承認，而係由收養效力法第2條、第5條及第6條之特別規定取代之（德家非108 II 3）。申言之，為減緩（舊）非訟法第16條之1採用中間承認之規範模式所導致矛盾裁判之危險，並避免向來所謂重複收養（Wiederholungs-adoption）之不便，而謀求關係人間之法安定性⁷⁷，收養效力法第2條明定：「第1條第1項所稱之收養應否承認或有效與否，以及是否解消未成年子女與其原父母間之親子關係，由家事法院依聲請確認之（第1項）。（略）（第2項）。收養應予承認或為有效者，法院應附帶確認以下事項：一、第1項所稱親子關係解消者，其收養關係視同依德國實質規定（Sachvorschriften）所成立之收養關係。二、其他情形，其收養關係所涉收養者之親權及扶養義務視同依德國實質規定所成立之收養關係。同時依第3條之規定宣告轉換者，得免為第1句之確認（第3項）」，創設獨立、任意之承認及效力確認程序（Anerkennungs- und Wirkungsfeststellungsverfahren）⁷⁸。依此，德國法院得依收養者、被收養人、原父母（即：本生父母或前收養者）或戶政機關（德收養效力5 I 1 ①）之聲請⁷⁹，依家事非訟事件所應

⁷⁶ Hausmann (Fn. 39), P. Rn. 143; Wolfgang Weitzel, Adoptionswirkungsgesetz, 2. Aufl., 2013, § 2 Rn. 2.

⁷⁷ 參見Helms (Fn. 38), vor § 1 AdWirkG Rn. 4; Hausmann (Fn. 39), P. Rn. 59 f.; Michael Busch, Adoptionswirkungsgesetze und Haager Adoptionsübereinkommen — von der Nachadoption zur Anerkennung und Wirkungsfeststellung, IPRax 2003, S. 13 (13 f.).

⁷⁸ 關於創設獨立程序之需求及不強制進行該程序之立法考量，參見BT-Drucks. 14/6011, S. 28, 32.

⁷⁹ 應注意者係：其他非收養效力法第5條第1項第1款所列，而對於外國法院認可收養未成年人裁判承認與否有利害關係之人（如：收養者之其他親屬），立法者明白否定其聲請權，以避免收養家庭被迫進行法院程序所得蒙受之不利利益（BT-Drucks. 14/6011, S. 48）。準此，該等利害關係人亦不得依照家事及非訟法

適用之程序規範（如：職權探知主義）及收養效力法第6條第3項第2句至第4句分別針對被收養人、收養者、原父母及主管機關所設之特別程序參與規定⁸⁰，以裁定確認外國法院認可收養未成年人裁判是否具備承認要件，如是，並依職權確認其是否斷絕被收養人與其原父母（及其親屬）間之法律關係及其效力如何為德國法上收養所（部分）替代（(Teil)Substitution）⁸¹；其（積極或消極）確認裁判所生之既判力，原則上並有拘束全體（含：法院及行政機關）之對世效（德收養效力5 II 1）⁸²。

（二）承認之要件

1. 基本原則

德國家事及非訟法第109條第1項規定：「外國裁判，有下列各款情形之一者，不予承認：一、依德國之法律，該外國法院無管轄權者。二、關係人對於本案未為陳述，而主張未依法受開始程序文書之通知，或未及時受通知致不能行使其權利者。三、該裁判與本國裁判、先前應予承認之外國裁判，或該裁判所據之程序與先繫屬於本國之程序相牴觸者。四、承認裁判之結果，顯然違背德國法之重要原則，尤其係侵害基本權者」。依照此項承繼（舊）非訟法第16條之1並參照民訴法第328條所設之規定，外國法院之家事或非訟

第108條第2項第1句之規定，聲請法院確認外國法院認可收養未成年人裁判之承認及其效力（*Helms* (Fn. 38), § 4 AdWirkG Rn. 3）。

⁸⁰ *Helms* (Fn. 38), § 5 AdWirkG Rn. 2 f., 10；關於「承認及效力確認事件」應否定性為收養事件（德家非186）之爭議，參見*Weitzel* (Fn. 76), § 5 Rn. 4.

⁸¹ *Hausmann* (Fn. 39), P. Rn. 69 f, 72; *Weitzel* (Fn. 76), § 2 Rn. 7 f.; *Helms* (Fn. 38), § 2 AdWirkG Rn. 17 ff.

⁸² *Helms* (Fn. 38), § 4 AdWirkG Rn. 10; *Hausmann* (Fn. 39), P. Rn. 91；應注意者係：依照收養效力法第5條第2項第2句至第4句之規定，原父母除已（主動或被動）參與承認及效力確認程序外，尚不為確認裁判之既判力所及（*Andrae* (Fn. 66), § 7 Rn. 89），此項緩和對世效之規定，雖有礙於法安定性之貫徹，惟係為避免承認及效力確認程序因必須使身處外國且難以通知之原父母參與而造成之延滯所必要者（BT-Drucks. 14/6011, S. 48 f.; *Busch* (Fn. 77), S. 14 Fn. 15）。

裁判，如無該條所列有關承認管轄權、程序開始之通知、裁判或程序之衝突、公序之四款拒絕承認事由⁸³，且該外國法院不欠缺審判權（*Gerichtsbareit*）（或稱：國家審判權）⁸⁴，即應予以承認⁸⁵；反之，如有上開拒絕承認事由之一或欠缺審判權者，則必須拒絕承認⁸⁶。除此之外，不僅德國與裁判國間有無相互承認，原則上並非所問⁸⁷，外國法院所適用之法律是否為德國法律衝突規範所指定者，更與承認與否無關，蓋1986年之國際私法改正法案已明白將衝突法之考量排除於拒絕承認事由之外⁸⁸，而揚棄承認法上之所謂衝突法上控制（*kollisionsrechtliche Kontrolle*）⁸⁹；在此意義上，可謂德國法對於外國裁判採取徹底之程序法上承認（*verfahrensrechtliche Anerkennung*），而明確與對於在外國作成之法律行為（如：兩願離婚）或完成之手續（如：法人登記）所運用之所謂實體法上承認（*materiell-rechtliche Anerkennung*）相區別⁹⁰，亦即，外國裁判是否

83 *Rauscher* (Fn. 43), § 109 Rn. 2.

84 *Geimer* (Fn. 1), vor § 97 FamFG Rn. 32, § 109 FamFG Rn. 2, 氏指出，此一要件雖未為家事及非訟法所明定，惟係國際公法上應予肯認者；*Schack*, IZVR⁷ (Fn. 51), Rn. 919；關於國家審判權之用語，參見陳瑋佑，2017年民事程序法裁判回顧，臺大法學論叢，47卷特刊，頁1796（2018年）。

85 應附言者係：儘管家事及非訟法係以承認外國法院裁判為原則（參見*Rauscher* (Fn. 43), § 109 Rn. 1; *Dimmler* (Fn. 46), § 109 Rn. 2; *Hau* (Fn. 4), § 109 Rn. 16），德國學說多仍表示家事及非訟法第109條並無「推定」承認之效力（*Dimmler*, ebd.; *Rauscher*, ebd. § 108 Rn. 9; *Sieghörtner* (Fn. 41), § 109 Rn. 17; *Spellenberg* (Fn. 43), § 109 FamFG Rn. 33）。

86 *Hau* (Fn. 4), § 109 Rn. 16 aE.

87 應附言者係：1986年（舊）非訟法第16條之1制定時，立法者鑑於1898年（舊）民訴法第328條第2項原已大幅排除承認外國法院非財產權裁判之相互承認要求，嗣又經1976年第一婚姻及親屬法修正法案（1. EheRG）明定外國法院針對親子關係事件（舊民訴640）所為裁判無庸相互承認者等情，未一併承繼民訴法第328條第1項第5款之規定（參見BT-Drucks. 10/504, S. 93）；此種僅要求外國法院針對「訴訟事件」所為裁判符合相互承認條件之基本立場，於2009年家事及非訟法制定時，亦未改變（*Rauscher* (Fn. 43), § 109 Rn. 58）。

88 參見前揭註63。

89 *Geimer* (Fn. 1), vor § 97 FamFG Rn. 26, § 109 FamFG Rn. 72; *Hau* (Fn. 4), § 108 Rn. 22.

90 *Geimer* (Fn. 1), vor § 97 FamFG Rn. 25, 27; *Wagner* (Fn. 7), S. 1624, 氏指出，此

於德國發生如何之效力，單純取決於是否符合德國國際民事程序法之要求，而全然不考慮德國國際私法之內容及其所指定原因關係準據法（含：德國法及外國法）之立場（所謂國際民事程序法之優先性）⁹¹。

申言之，德國家事及非訟法第109條之規定係適用於(1)外國裁判，亦即，僅外國裁判始係承認之標的而具承認標的適格⁹²：所謂外國，係指德國以外之高權主體，包含位於德國境內之外交機關⁹³，而所謂裁判，係指法院或其他功能上得與德國法院同視之行政機關（如：受理離婚事件之挪威郡長、受理收養事件之瓜地馬拉公證人）所為⁹⁴，容認或駁回本案事件之終局實體裁判⁹⁵。準此，外國行政機關無判定法律關係效力之行為（如：親子身分登記）⁹⁶、單純具執行力之公（權）證書或程序上和解⁹⁷，並不屬之，外國法院指揮程序之處置或程序裁判⁹⁸、承認他國法院裁判之裁判（所謂「雙重執行宣告」），亦然⁹⁹。外國法院之實體裁判雖應依該外國法已經生效，且未經該外國法院撤銷或廢棄¹⁰⁰，惟依照德國多數學說見解，其承認本身並不以確定（即：形式確定力）為必要（德家非

項區別之正當化基礎係對於外國法院（或其他公權機關）之信賴；關於實體法上承認之具體內涵，參見Wagner, ebd. S. 1623, 1629; Rauscher (Fn. 43), § 109 Rn. 10.

91 Geimer (Fn. 1), vor § 97 FamFG Rn. 24, 26; Hau (Fn. 4), § 108 Rn. 22; Schack, IZVR⁷ (Fn. 51), Rn. 24; Kropholler (Fn. 63), S. 547; Wagner (Fn. 7), S. 1622 f.; Rolf Wagner, Anerkennung und Wirksamkeit ausländischer familienrechtlicher Rechtsakte im autonomen Recht, FamRZ 2006, S. 744 (746 f.).

92 Hau (Fn. 4), § 108 Rn. 4.

93 Rauscher (Fn. 43), § 108 Rn. 11; Spellenberg (Fn. 43), § 108 FamFG Rn. 116 ff.

94 Hau (Fn. 4), § 108 Rn. 5; Rauscher (Fn. 43), § 108 Rn. 10.

95 Rauscher (Fn. 43), § 108 Rn. 15; Spellenberg (Fn. 43), § 108 FamFG Rn. 128 ff.

96 BGH, NJW 2019, S. 1608, Rz. 16; Wagner (Fn. 7), S. 1625.

97 Sieghörtner (Fn. 41), § 108 Rn. 31; Rauscher (Fn. 43), § 108 Rn. 14; Hau (Fn. 4), § 108 Rn. 6; 寬鬆見解：Dimmler (Fn. 46), § 108 Rn. 6.

98 Rauscher (Fn. 43), § 108 Rn. 15; Spellenberg (Fn. 43), § 108 FamFG Rn. 134.

99 Hau (Fn. 4), § 108 Rn. 4b; Rauscher (Fn. 43), § 108 Rn. 15 aE.

100 Hau (Fn. 4), § 108 Rn. 10a; Spellenberg (Fn. 43), § 108 FamFG Rn. 145.

110 III 2) ¹⁰¹；因此，循略式程序所核發且附隨於本案事件之暫時處分，學說、實務向來認為亦屬承認之標的¹⁰²。要之，外國法院創設、廢止、變更、確定權利或其他影響法益之處置，對於關係人得生特定之法效者，即構成本條所謂之裁判¹⁰³。

關於家事及非訟法第109條第1項所列之拒絕承認事由，其重要內涵則有如下述：

就(2)承認管轄權（德家非109 I ①）而言，如裁判國依照德國之法律即家事及非訟法第98條至第105條之國際管轄規定，可認為其於裁判作成時享有國際管轄權¹⁰⁴，即不欠缺同法第109條第1項第1款所稱之管轄權，而不問該國之國際管轄規範或具體之國際管轄原因為何（所謂鏡像原則）¹⁰⁵；此要不因德國法院對於系爭事件依德國法亦享有國際管轄權一事，而有所不同，蓋其國際管轄權並不具專屬性（德家非106）¹⁰⁶。

就(3)程序開始之通知（德家非109 I ②）而言，如其權利因外國裁判受影響，而自德國法之觀點應參與程序之關係人¹⁰⁷，並未就該裁判所涉程序標的法律關係表示意見即未對於本案有所陳述¹⁰⁸，且外國法院依該國法據以著手處理系爭事件之開始程序文書¹⁰⁹，有以

¹⁰¹ *Hau* (Fn. 4), § 108 Rn. 4; *Rauscher* (Fn. 43), § 108 Rn. 16; *Sieghörtner* (Fn. 41), § 108 Rn. 30; *Dimmler* (Fn. 46), § 108 Rn. 8; *Wagner* (Fn. 7), S. 1626; *Klinck* (Fn. 54), S. 744 f.; 區別見解：*Schack*, IZVR⁷ (Fn. 51), Rn. 910; *Spellenberg* (Fn. 43), § 108 FamFG Rn. 142 f.

¹⁰² *Rauscher* (Fn. 43), § 108 Rn. 17; *Dimmler* (Fn. 46), § 108 Rn. 9; *Hau* (Fn. 4), § 108 Rn. 4a; *Klinck* (Fn. 54), S. 744 f.; *Wagner* (Fn. 91), S. 749; 保守見解：*Spellenberg* (Fn. 43), § 108 FamFG Rn. 151 f.

¹⁰³ 參見BT-Drucks. 10/504, S. 93.

¹⁰⁴ 關於判斷有無承認管轄權之基準時點，參見*Hau* (Fn. 4), § 109 Rn. 22.

¹⁰⁵ 關於本款所謂德國之法律，參見*Rauscher* (Fn. 43), § 109 Rn. 11 ff.

¹⁰⁶ 參見*Sieghörtner* (Fn. 41), § 106 Rn. 1, § 109 Rn. 19 aE.

¹⁰⁷ 關於本款所謂之關係人，參見*Hau* (Fn. 4), § 109 Rn. 32.

¹⁰⁸ 關於本款所謂之對於本案未為陳述，參見*Hau* (Fn. 4), § 109 Rn. 36.

¹⁰⁹ 關於本款所謂之開始程序之文書，參見*Rauscher* (Fn. 43), § 109 Rn. 27.

下兩種情事之一者¹¹⁰，即：或未循該國法所規定之方式依法通知該關係人¹¹¹，或其通知並未給予該關係人充分準備事實上或法律上陳述之時間而不夠及時¹¹²，該關係人知悉外國程序之聽審請求權即受侵害¹¹³，而得加以主張以阻止該外國裁判於德國（對於該關係人¹¹⁴）發生效力¹¹⁵；縱其嗣後受裁判之通知或依其他方式知悉該裁判，而未依裁判國法提起救濟，仍不因此喪失抗辯其未受程序開始之通知的權限，蓋裁判前之防禦機會與裁判後之救濟途徑在審判上並非等價，尚不能強要該關係人在裁判國尋求救濟，而課予其所謂救濟之對己義務（*Rechtsmittelobliegenheit*）¹¹⁶。

就(4)裁判或程序之衝突（德家非109 I ③）而言，如外國裁判與德國或他外國裁判關於共通重要事項（含：程序標的或其先決法律關係）之判斷有所歧異，以致於二裁判之法律效果不能併存（如：撤銷認領之裁判與確認婚生子女關係之裁判¹¹⁷）¹¹⁸，則應區分二種情形，分別決定之：在外國裁判與德國裁判相牴觸的情形，採取本國裁判優先原則（*Nationalitätsgrundsatz*），拒絕承認該外國裁判，而在外國裁判與他外國裁判相牴觸之情形，採取先裁判優先原則（*Prioritätsgrundsatz*），該外國裁判之作成先於他外國裁判者，

110 參見BGH, NJW 2019, S. 2940, Rz. 19 ff.

111 關於本款所謂之依法通知，參見Rauscher (Fn. 43), § 109 Rn. 29.

112 關於本款所謂之及時通知，參見Rauscher (Fn. 43), § 109 Rn. 30.

113 參見BT-Drucks. 10/504, S. 93; Dimmler (Fn. 46), § 109 Rn. 5, 7，氏並指出，如系爭事件之處理本即著重對於相對人之突襲性（如：暫時處分），而有限縮聽審請求權之正當理由，則無本款之適用。

114 參見Geimer (Fn. 1), § 109 FamFG Rn. 66.

115 關於本款作為抗辯事項之性質，參見Rauscher (Fn. 43), § 109 Rn. 32.

116 BGH, NJW 2019, S. 2940, Rz. 27；亦參見Herbert Roth, Ordnungsgemäße Zustellung und ausreichende Wahrnehmung der Verteidigungsmöglichkeit des Beteiligten als kumulative Erfordernisse für die Anerkennung nach § 109 Abs. 1 Nr. 2 FamFG, IPRax 2018, S. 606 (608)；區別見解：Spellenberg (Fn. 43), § 109 FamFG Rn. 191.

117 OLG Bremen, FamRZ 2017, S. 2042, Rz. 9.

118 關於本款所謂之相牴觸，參見Rauscher (Fn. 43), § 109 Rn. 35.

即不拒絕加以承認¹¹⁹；此外，如外國裁判與德國法院程序相牴觸（如：外國准予離婚之裁判與德國請求離婚之程序）¹²⁰，則在外國裁判所據程序之繫屬後於德國程序的情形，採取本國繫屬優先原則，拒絕承認該外國裁判¹²¹。上開解決裁判或程序衝突之方案¹²²，尤其鑑於非訟裁判所常欠缺之既判力或多具之可變更性（*Abänderbarkeit*），實未必妥適¹²³；因此，如外國裁判之基礎係包含德國或他國法院作成裁判後始發生之情事，而可認為先前之裁判已經嗣後之裁判所變更者¹²⁴，即使前、後裁判之內容有所矛盾，亦不該當前揭相牴觸之要件¹²⁵。

就(5)公序（德家非109 I ④）而言，基於家事及非訟法第109條第5項明示之禁止實質再審查原則，外國裁判違反該外國、他國或德國實體、程序或衝突法規等事，均非否定其於德國發生效力之理由（上述「貳、一、（一）、1.」）；除非外國裁判與德國法上正義理念之牴觸已達到不能忍受的程度¹²⁶，或其作成之過程在德國法上無法被認為合於法治國的要求¹²⁷，而於承認判定時違反德國之公

119 參見Dimmler (Fn. 46), § 109 Rn. 15 f.

120 OLG München, FamRZ 2017, S. 131, Rz. 12.

121 參見Dimmler (Fn. 46), § 109 Rn. 17.

122 應附言者係：家事及非訟法第109條第1項第3款係原樣移用自（舊）非訟法第16條之1第3款（BT-Drucks. 16/6308, S. 222），而後一規定則又係套用民訴法第328條第1項第3款所設者（BT-Drucks. 10/504, S. 93 f.）；民訴法第328條第1項第3款係1986年之國際私法改正法案刪除原內容後（前揭註63）加以增訂，其關於裁判衝突之解決方案係追隨布魯塞爾公約（1968 Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters）第27條第3款及第5款，而關於程序衝突之解決方案則係立法者所新創者（BT-Drucks. 10/504, S. 88；另參見Herbert Roth, in: Bork/Roth (Hrsg.), Stein/Jonas Kommentar zur Zivilprozessordnung, Bd. 5, 23. Aufl., 2015, § 328 Rn. 94 aE，氏指出，於本款增訂前，德國實務上係以公序條款解決裁判或程序衝突之問題）。

123 Hau (Fn. 4), § 109 Rn. 41; Rauscher (Fn. 43), § 109 Rn. 36.

124 關於本國法院變更外國法院裁判之容許性，參見下述「貳、一、（三）、1.」。

125 Hau (Fn. 4), § 109 Rn. 42; Spellenberg (Fn. 43), § 109 FamFG Rn. 219; Rauscher (Fn. 43), § 109 Rn. 36.

126 BGH, FamRZ 2018, S. 1846, Rz. 15.

127 BVerwG, FamRZ 2013, S. 547, Rz. 21; BGH, BeckRS 2020, S. 16546, Rz. 63.

序¹²⁸，否則不能拒絕承認之¹²⁹。換言之，唯有在外國裁判所涉事案與德國有所牽連即具備相當之內國關連性（*Inlandsbeziehung*）的前提下¹³⁰，其內容或審判程序重大偏離於德國實體法或程序法秩序之基本原則者，始能以本國之實體公序或程序公序遭違反為由拒絕予以承認¹³¹；上開審判程序之瑕疵，如為受不利裁判之關係人所及時知悉，而未依裁判國法提起救濟，原則上該關係人即不能再主張程序公序之違反，蓋公序之保留條款並非以矯正疏懈之程序遂行為目的，且得循裁判國之救濟程序加以排除之程序瑕疵亦難認為不合

¹²⁸ 關於判斷是否違反公序之基準時點，參見 *Sieghörtner* (Fn. 41), § 109 Rn. 34；應注意者係：德國通說、實務見解以承認判定時作為判斷是否違反公序之基準時點（關於基準時點之設定與後述效力延伸說之邏輯關係，參見 *Schack*, *IZVR*⁷ (Fn. 51), Rn. 972; *Reinhold Geimer*, *Der ordre public atténué de la reconnaissance im Adoptionsrecht* (OLG Hamm, S. 497), *IPRax* 2017, S. 472 (474))，並肯定於裁判作成時抵觸德國公序之外國裁判，於承認判定時無違變動後之德國公序者，仍應加以承認一事，雖有抑制跛行身分關係發生之意義（*Rauscher* (Fn. 43), § 109 Rn. 39），惟在相反之情形，如嗣後不認外國裁判之效力（尤其係：形成力），則容易導致身分關係之不安定，並有害其他利害關係人之信賴，而多受學說指摘（參見 *Hau* (Fn. 4), § 109 Rn. 47; *Spellenberg* (Fn. 43), § 109 FamFG Rn. 263; *Schack*, ebd. Rn. 973; *Rauscher*, ebd. § 109 Rn. 40）。

¹²⁹ 應附言者係：家事及非訟法第109條第1項第4款所定之公序，與民法施行法第6條所稱之公序，其違反與否之判斷標準，向來認為前者應較後者更為緩和，蓋相對於後一所謂「衝突法上公序」，前一所謂「承認法上公序」係涉及已作成之外國法院裁判應否於德國發生效力，而有保護關係人之信賴並避免跛行法律關係之需求，使用上宜更為保守（*Hau* (Fn. 4), § 109 Rn. 45; *Spellenberg* (Fn. 43), § 109 FamFG Rn. 227；同旨：BGH, *FamRZ* 2018, S. 1846, Rz. 15; *Sieghörtner* (Fn. 41), § 109 Rn. 32 aE）；在此意義上，固不妨稱「承認法上公序」為「緩和公序（*ordre public atténué*）」（*Geimer* (Fn. 1), § 109 FamFG Rn. 69），然不宜稱之為「國際公序（*ordre public international*）」（BGH, *FamRZ* 2018, S. 1846, Rz. 15），蓋「衝突法上公序」亦具有「國際公序」之性質（參見 *Jan von Hein*, in: von Hein (Hrsg.), *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, Bd. 12, 8. Aufl., 2020, Art. 6 EGBGB Rn. 8）。

¹³⁰ *Hau* (Fn. 4), § 109 Rn. 44; *Rauscher* (Fn. 43), § 109 Rn. 37; *Spellenberg* (Fn. 43), § 109 FamFG Rn. 256；不同見解：*Reinhold Geimer*, *Internationales Zivilprozessrecht*, 7. Aufl., 2015, Rn. 2967 aE; *Heinrich Nagel/Peter Gottwald*, *Internationales Zivilprozessrecht*, 7. Aufl., 2013, § 12 Rn. 172：「……[內國關連性]並非必要條件。縱無此事，抵觸最低限度之自然法上正義或人權者，仍構成公序之違反……」。

¹³¹ 參見 *Sieghörtner* (Fn. 41), § 109 Rn. 33; *Spellenberg* (Fn. 43), § 109 FamFG Rn. 257.

法治國要求，要求該關係人在裁判國尋求救濟非無正當性，而應課予其救濟之對己義務¹³²。準此，家事及非訟法第109條第1項第4款所稱德國法之重要原則，即指上開德國之實體公序及程序公序¹³³，其除得反映於普通法律之規定（如：德民施13 IV 1及德民1310 I 1¹³⁴、德家非160¹³⁵）外¹³⁶，受德國基本法或國際人權法（如：歐洲人權公約）所保護之基本權（或人權）（如：結婚自由或宗教自由¹³⁷、聽審請求權¹³⁸），更係立法者明文提示之典型德國法之重要原則¹³⁹。又，法文所謂之顯然，有其凸顯公序作為拒絕承認事由例外性、限制性之意義¹⁴⁰，並非指任何人（尤其係：非法律專家）均得立即注意到德國公序遭違反之情事，而係意味承認外國法院裁判之結果無疑重大偏離於德國法秩序基本原則¹⁴¹；此處之所以強調承認裁判之結果，旨在表明應受審查者係個別裁判之內容或審判程序，而非外國法院所適用之抽象實體、程序規範本身，尤不能誤解為公序之限制僅及於裁判之主文而已¹⁴²。

2. 父母責任事件

上述（「貳、一、（二）、1.」）有關德國家事及非訟法第109條

132 BGH, FamRZ 2009, S. 1816, Rz. 40; Hau (Fn. 4), § 109 Rn. 52; Rauscher (Fn. 43), § 109 Rn. 37 aE; Spellenberg (Fn. 43), § 109 FamFG Rn. 252 ff.，氏並指出，救濟之對己義務理論上雖亦可能指向實體公序，惟裁判內容之瑕疵能否透過救濟程序加以排除，實際上多難預料，而常不能滿足救濟之對己義務之發生條件；不同見解：Schack, IZVR⁷ (Fn. 51), Rn. 957.

133 Dimmler (Fn. 46), § 109 Rn. 18.

134 KG, FamRZ 2019, S. 367, Rz. 26 f.

135 Rauscher (Fn. 43), § 109 Rn. 42 aE.

136 Spellenberg (Fn. 43), § 109 FamFG Rn. 237.

137 Dimmler (Fn. 46), § 109 Rn. 18.

138 Hau (Fn. 4), § 109 Rn. 51.

139 參見BT-Drucks. 10/504, S. 44; Spellenberg (Fn. 43), § 109 FamFG Rn. 238 f., 244.

140 參見BT-Drucks. 10/504, S. 43; Wagner (Fn. 7), S. 1626.

141 Spellenberg (Fn. 43), § 109 FamFG Rn. 242; Nagel/Gottwald (Fn. 130), § 12 Rn. 172.

142 參見BT-Drucks. 10/504, S. 43; Spellenberg (Fn. 43), § 109 FamFG Rn. 232 f.

第1項之適用對象及其列舉之拒絕承認事由的說明，原則上均通用於外國法院定親權裁判之承認：

關於(1)外國裁判，得構成承認標的之終局實體裁判，除固有意義之司法處置外，亦包含親權或會面交往之協議，經法院或同等功能之行政機關實質審查後予以核可者¹⁴³。外國法院定親權裁判依該外國法一經生效，不待確定即得承認之¹⁴⁴；非純具保全性之暫時處分（如：暫由祖母任親權人並命交付子女予祖母）¹⁴⁵，亦同¹⁴⁶。

關於(2)承認管轄權，依照家事及非訟法第109條第1項第1款所採取之鏡像原則，外國法院取得管轄權之原因有四¹⁴⁷：其一為未成年子女具裁判國之國籍（德家非99 I 1 ①）、其二為未成年子女之習慣居所位於裁判國（德家非99 I 1 ②）、其三為未成年子女有受裁判國法院保護照顧之必要（德家非99 I 2）、其四則為裁判國對於已繫屬之離婚事件有國際管轄權，而系爭「父母責任事件」構成該離婚事件之結果事件，經夫妻之一方請求裁判國法院合併處理且其合併不牴觸未成年子女最佳利益（德家非98 III、137 III）。由於德國多數說、實務見解向來否定管轄恆定原則（德家非2 II）於「父母責任事件」之一概適用¹⁴⁸，故尤其在不具裁判國國籍之未成年子女，於程序繫屬中變更其習慣居所地至他國的情形，縱裁判國於程序繫屬時取得國際管轄權，仍應認為於裁判作成時已喪失之，其裁判自未滿足上開承認要件¹⁴⁹；至於前揭管轄原因於承認判定時是否

143 Hausmann (Fn. 39), N. Rn. 613.

144 OLG Köln, NJW-RR 2010, S. 1225 (1226).

145 Hausmann (Fn. 39), N. Rn. 615; Andrae (Fn. 66), § 6 Rn. 153.

146 Hausmann (Fn. 39), N. Rn. 616.

147 Henrich (Fn. 75), Art. 21 EGBGB Rn. 228; Andrae (Fn. 66), § 6 Rn. 161；關於德國家事及非訟法第99條第1項及第98條第3項之規定，詳見陳瑋佑（註29），頁216-221。

148 Henrich (Fn. 75), Art. 21 EGBGB Rn. 163 f.；關於德國家事及非訟法上之管轄恆定原則，參見陳瑋佑（註29），頁222。

149 Andrae (Fn. 66), § 6 Rn. 161; Hausmann (Fn. 39), N. Rn. 634.

因德國國際管轄法之修正而存在於裁判國，則非所問，以保護關係人對於德國國際管轄法之信賴¹⁵⁰。

關於(3)程序開始之通知，於「父母責任事件」並無特別之處¹⁵¹。外國法院酌定父母之一方為親權人的裁判，其開始程序文書雖未能依法通知他方，惟該他方已與法院為未成年子女指定之程序監理人相互聯絡，並透過該程序監理人取得相關文書且知悉程序期日者，尚難認為該他方得依據家事及非訟法第109條第1項第2款之規定，阻止該外國裁判於德國對之發生效力¹⁵²。至於未成年子女所應特別受保障之聽審請求權，家事及非訟法則未如布魯塞爾第二之一規則或海牙兒童保護公約設有明文規定（下述「貳、二、(二)」），而係藉由公序之保留條款一併予以保護（詳後述）¹⁵³。

關於(4)裁判或程序之衝突，家事及非訟法第109條第1項第3款所採用之先裁判優先原則，於婚姻事件或其他家事訟爭事件，固堪謂妥適，然於「父母責任事件」，則鑑於嗣後作成之裁判往往可斟酌新發生之情事而更能符合未成年子女最佳利益，而在立法論上受一定之批判¹⁵⁴。因此，本於德國法院所為定親權裁判得隨時變更之特徵（德民1696）¹⁵⁵，除嗣後作成之外國裁判與先前作成之德國裁判，其內容之矛盾非因事實基礎之不同，而僅係因法律評價之差異所致者外¹⁵⁶，非不得視外國法院裁判為變更裁判（*Abänderungsentscheidung*）而加以承認，以緩和前揭先裁判優先原則之不當¹⁵⁷。

150 *Hausmann* (Fn. 39), N. Rn. 634.

151 *Hausmann* (Fn. 39), N. Rn. 640.

152 *Henrich* (Fn. 75), Art. 21 EGBGB Rn. 236.

153 *Henrich* (Fn. 75), Art. 21 EGBGB Rn. 234; *Andrae* (Fn. 66), § 6 Rn. 168.

154 *Hausmann* (Fn. 39), N. Rn. 648.

155 參見 *Michael Coester*, in: *Coester u. a. (Hrsg.), J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen*, §§ 1684 — 1717, 2019, § 1696 Rn. 56 ff.

156 *Henrich* (Fn. 75), Art. 21 EGBGB Rn. 245.

157 *Henrich* (Fn. 75), Art. 21 EGBGB Rn. 243; *Hausmann* (Fn. 39), N. Rn. 644; *Andrae*

關於(5)公序，不論未成年子女最佳利益原則是否具有基本權之性質¹⁵⁸，於「父母責任事件」，其無疑屬於家事及非訟法第109條第1項第4款所稱之德國法上重要原則¹⁵⁹。因此，如外國法院定親權裁判之內容或審判程序顯然不合於未成年子女最佳利益，原則上即應拒絕承認之¹⁶⁰；其於裁判作成時尚無違未成年子女最佳利益，而於承認判定時斟酌嗣後發生之情事，可認為與之相牴觸者，亦同¹⁶¹，反之，於裁判作成時有違未成年子女最佳利益之外國裁判，於承認判定時斟酌嗣後發生之情事，可認為與之相合致者，則應加以承認¹⁶²。

申言之，一方面，如外國法院純依抽象之規定為處置，而非以謀求未成年子女最佳利益為依歸¹⁶³，或僅以不危害未成年子女最佳利益為其界限¹⁶⁴，即有違反實體公序之虞；此在外國法院未（充分）考量如何之親權歸屬或會面交往方法始能實現未成年子女最佳利益，而從事所謂「未成年子女最佳利益之審查（Kindeswohlprüfung）」的情形，尤其明顯¹⁶⁵。另一方面，如外國法院於酌定親權或會面交往方式及期間前，並未親自聽取未成年子女之意見（德家非159）¹⁶⁶，或未至少透過其他途徑（如：鑑定人）確認相關資

(Fn. 66), § 6 Rn. 173；亦參見Spellenberg (Fn. 43), § 109 FamFG Rn. 223.

158 參見Stefan Treichel, Kindergrundrechte und Partizipation, JZ 2020, S. 653 (659 f.); Schmahl (Fn. 26), Art. 3 Rn. 18.

159 Rauscher (Fn. 43), § 109 Rn. 41; BGH, NJW 1980, S. 529 (532).

160 Hausmann (Fn. 39), N. Rn. 650; Dieter Henrich, in: Johannsen/Henrich/Althammer (Hrsg.), Familienrecht, 7. Aufl., 2020, § 109 FamFG Rn. 14; Andrae (Fn. 66), § 6 Rn. 162 f.

161 Andrae (Fn. 66), § 6 Rn. 164; Dimmler (Fn. 46), § 109 Rn. 23.

162 Hausmann (Fn. 39), N. Rn. 649; Henrich (Fn. 75), Art. 21 EGBGB Rn. 249.

163 參見Heiderhoff, FS Geimer (Fn. 27), S. 237; Henrich (Fn. 160), § 109 FamFG Rn. 14.

164 參見Henrich (Fn. 75), Art. 21 EGBGB Rn. 248.

165 參見Hau (Fn. 4), § 109 Rn. 48; Geimer (Fn. 1), § 109 FamFG Rn. 70; Peter Finger, Anerkennung einer ausländischen Sorgerechtsentscheidung — deutscher ordre public, NZFam 2015, S. 191 (191).

166 參見Rauscher (Fn. 43), § 109 Rn. 42，氏認為，如外國法院未依照德國家事及非

訊¹⁶⁷，而未能完整蒐集得據以判斷未成年子女最佳利益之基礎資料，則除有急迫情事外¹⁶⁸，難謂與程序公序相符；此在因法院之處置而親權受影響之人，其聽審請求權未獲充分保障的情形，尚無不同¹⁶⁹。

不過，即使外國法院定親權裁判牴觸前述實體公序或程序公序，仍不表示一律必須拒絕承認之。毋寧是，特別在其審判程序未充分賦予未成年子女或父母陳述機會的情形，儘管未保障關係人之聽審請求權所生程序公序之違反，並不能透過於承認適格判定程序賦予陳述之機會，而予以補正¹⁷⁰，蓋此種事後程序保障在功能上與事前程序保障既有所不同¹⁷¹，德國法院（或其他公權機關）之聽審實際上又趨近於實質審查外國裁判之當否¹⁷²；可是，如該裁判之內容尚屬適當，而拒絕承認反將在個案中危害未成年子女最佳利益（如：侵害未成年子女依基本法第6條第2項所享有之受父母保護教養權）¹⁷³，則必須例外限制家事及非訟法第109條第1項第4款之適用，而予以承認¹⁷⁴。準此，於承認適格判定程序，德國法院判定外國法

訟法第159條所揭示之標準親自聽取未成年子女之意見，即構成程序公序之違反；Siegthörner (Fn. 41), § 109 Rn. 37.

167 參見 Dagmar Coester-Waltjen, Einige Überlegungen zur Kindesanhörung im familiengerichtlichen Verfahren, in: Brinkmann u. a. (Hrsg.), Dogmatik im Dienst von Gerechtigkeit, Rechtssicherheit und Rechtsentwicklung. Festschrift für Hanns Prütting, 2018, S. 247 (258)，氏認為，是否違反程序公序之判斷，不應以外國法院所行程序是否符合德國家事及非訟法第159條之規定為絕對標準，蓋親自聽取未成年子女意見並非充分保障其參與權即聽審請求權之唯一手段；Henrich (Fn. 75), Art. 21 EGBGB Rn. 234.

168 Andrae (Fn. 66), § 6 Rn. 168 aE.

169 參見 Helms (Fn. 38), Art. 21 EGBGB Rn. 50 aE; Hau (Fn. 4), § 109 Rn. 51; Henrich (Fn. 160), § 109 FamFG Rn. 14; Rauscher (Fn. 43), § 109 Rn. 42 aE.

170 Rauscher (Fn. 43), § 109 Rn. 50; Hau (Fn. 4), § 109 Rn. 51.

171 BverwG, FamRZ 2013, S. 547, Rz. 22.

172 參見 BGH, FamRZ 2015, S. 1101, Rz. 48.

173 關於基本法第6條第2項之此一內容，參見 BverfG, NJW 2008, S. 1287, Rz. 70 ff.

174 BverwG, FamRZ 2013, S. 547, Rz. 23; Rauscher (Fn. 43), § 109 Rn. 42; Heiderhoff, FS Geimer (Fn. 27), S. 239.

院定親權裁判之內容或審判程序牴觸未成年子女最佳利益者，尚應進一步審認其拒絕承認是否不致於過度限制個別兒童之福祉¹⁷⁵。

至於在「父母責任事件」作為某離婚事件之結果事件而由外國法院合併審判的情形，向來雖視離婚裁判之承認適格性經（邦司法行政機關）積極確認一事（德家非107）為承認定親權裁判之條件¹⁷⁶，惟現今多數學說否定二者間之所謂承認關連性（Anerkennungsverbund），蓋親權之單獨歸屬已不以婚姻之解消為限（德民1671），縱不承認外國法院之離婚裁判，外國法院定親權裁判亦不能謂失所附麗，而應獨立判定其承認適格性之有無¹⁷⁷。

3. 收養未成年人事件

上述（「貳、一、（二）、1.」）有關德國家事及非訟法第109條第1項之適用對象及其列舉之拒絕承認事由的說明，原則上亦通用於外國法院認可收養未成年人裁判之承認：

關於(1)外國裁判，屬於所謂程序法上承認對象者，除由法院或同等功能之行政機關、公證人所為具創設性之所謂收養宣告（Dekret）外¹⁷⁸，當事人間締結之收養契約，經外國法院實質審查（尤其係：是否合於未成年子女最佳利益），而確認其有效性，或得外國法院之事前許可、事後同意者，亦屬之¹⁷⁹；反之，收養契約未經外國法院實質審查，而僅單純予以登記甚或無庸任何公權力介入即生效力者，則應依其準據法（德民施22、23）為所謂實體法上承

¹⁷⁵ Heiderhoff, FS Geimer (Fn. 27), S. 240，氏並強調，此並非對於外國裁判進行法所不許之實質審查；Heiderhoff, Standards und Abgrenzungen (Fn. 27), S. 69 f.，氏指出，此事實際上以聽取未成年子女之意見為必要。

¹⁷⁶ Henrich (Fn. 75), Art. 21 EGBGB Rn. 251.

¹⁷⁷ Hausmann (Fn. 39), N. Rn. 627; Helms (Fn. 38), Art. 21 EGBGB Rn. 50; Andrae (Fn. 66), § 6 Rn. 154.

¹⁷⁸ Hausmann (Fn. 39), P. Rn. 105; BT-Drucks. 10/504, S. 93.

¹⁷⁹ Helms (Fn. 38), Art. 22 EGBGB Rn. 90; Henrich (Fn. 75), Art. 22 EGBGB Rn. 98.

認¹⁸⁰。外國法院認可收養未成年人裁判依該外國法一經生效，縱尚未確定，亦非不得承認之¹⁸¹。

關於(2)承認管轄權，依照家事及非訟法第109條第1項第1款所採取之鏡像原則，外國法院取得管轄權之原因有二¹⁸²：其一為收養者（含：於夫妻共同收養時，其中一方）或被收養人具裁判國之國籍（德家非101 ①）、其二則為上開關係人（之一）之習慣居所位於裁判國（德家非101 ②）。此等管轄原因是否存在於裁判國，固應視裁判作成時之狀況決之，然尤其在關係人均不具裁判國國籍，且於程序繫屬中變更其習慣居所地至他國的情形，如否定管轄恆定原則（德家非2 II）於「收養未成年人事件」之一概適用，即應否定上開承認要件之該當性¹⁸³；至於外國裁判得否因德國國際管轄法之修正而於承認判定時補正其承認管轄權之欠缺，則非無爭議¹⁸⁴。

關於(3)程序開始之通知，於「收養未成年人事件」並無特別之處¹⁸⁵。由於其程序之開始率依收養者之聲請為之，且家事及非訟法第109條第1項第2款之規定未必適於保護其他關係人之聽審請求權，故該承認要件既在實際上並無重要性¹⁸⁶，在理論上亦被認為宜由同條項第4款之規定取代之¹⁸⁷。

¹⁸⁰ Hausmann (Fn. 39), P. Rn. 101, 104; Helms (Fn. 38), Art. 22 EGBGB Rn. 90; Andrae (Fn. 66), § 7 Rn. 83.

¹⁸¹ Hausmann (Fn. 39), P. Rn. 107; Helms (Fn. 38), § 2 AdWirkG Rn. 5, 惟 § 5 AdWirkG Rn. 11, 13則將外國裁判確定證明列為進行承認及效力確認程序所應附具之文件。

¹⁸² Hausmann (Fn. 39), P. Rn. 117; Andrae (Fn. 66), § 7 Rn. 74.

¹⁸³ Hausmann (Fn. 39), P. Rn. 118, H. Rn. 19; 似不同: Helms (Fn. 38), Art. 22 EGBGB Rn. 93 aE.

¹⁸⁴ 否定見解: Hausmann (Fn. 39), P. Rn. 119, 氏強調應保護關係人對於德國國際管轄法之信賴; 肯定見解: Henrich (Fn. 75), Art. 22 EGBGB Rn. 87; Helms (Fn. 38), Art. 22 EGBGB Rn. 93.

¹⁸⁵ Hausmann (Fn. 39), P. Rn. 123.

¹⁸⁶ Hausmann (Fn. 39), P. Rn. 123 aE.

¹⁸⁷ Helms (Fn. 38), Art. 22 EGBGB Rn. 95.

關於(4)裁判或程序之衝突，家事及非訟法第109條第1項第3款之規定與同條項第2款同樣在實際上不具重要性¹⁸⁸。惟若被收養人已經外國或德國法院裁判認可其收養，除有允許同時為二人養子女之特別規定外（如：德民1742），他國法院又裁判認可他人對於該兒童之收養者，後一裁判即與前一裁判相牴觸，而構成拒絕承認事由¹⁸⁹。

關於(5)公序，於「收養未成年人事件」，德國民法第1741條以下規定所反映之收養法原則，係構成家事及非訟法第109條第1項第4款所稱德國法之重要原則¹⁹⁰；不過，此並不表示系爭事件由德國法院依德國強行規定處理之結果將有所不同者，即違背公序，毋寧是，為避免跛行身分關係，應限縮上開拒絕承認事由之適用¹⁹¹。其中，除應依收養者之聲請為之（德民1752、1760）、應得被收養人（德民1746、1760）及本生父母之同意（德民1747、1748、1760）等基本要求外¹⁹²，最關鍵之德國法上重要原則，係未成年子女最佳利益原則（德民1741 I）¹⁹³。依此，如外國法院認可收養未成年人裁判之內容或審判程序顯然不合於未成年子女最佳利益，自得拒絕承認之¹⁹⁴；其是否危害未成年子女最佳利益，雖應視承認判定時之狀況決之，而可斟酌嗣後發生之情事（尤其係：被收養人與收養者

188 Henrich (Fn. 75), Art. 22 EGBGB Rn. 88.

189 Helms (Fn. 38), Art. 22 EGBGB Rn. 96; Bettina Heiderhoff, in: Hau/Poseck (Hrsg.), BeckOK BGB, 54. Aufl., Stand: 01.05.2020, Art. 22 EGBGB Rn. 70.

190 Andrae (Fn. 66), § 7 Rn. 75.

191 BGH, NJW 2015, S. 2800, Rz. 34; Hausmann (Fn. 39), P. Rn. 129; 另參見 Heiderhoff (Fn. 189), Art. 22 EGBGB Rn. 69, 氏指出，德國實務上毋寧常見認定違反公序的案例。

192 參見Henrich (Fn. 75), Art. 22 EGBGB Rn. 89 ff.; Helms (Fn. 38), Art. 22 EGBGB Rn. 98 f.; Andrae (Fn. 66), § 7 Rn. 79.

193 Hausmann (Fn. 39), P. Rn. 130; Henrich (Fn. 75), Art. 22 EGBGB Rn. 88; Christian F. Majer, Die Anerkennung ausländischer Adoptionsentscheidungen, NZFam 2015, S. 1138 (1139); BGH, NJW 2015, S. 2800, Rz. 34 aE.

194 Rauscher (Fn. 43), § 109 Rn. 44a.

間親子關係之確立)，承認於裁判作成時原違背未成年子女最佳利益之外國裁判¹⁹⁵，惟如於裁判作成時尚符合未成年子女最佳利益之外國裁判，於承認判定時斟酌嗣後發生之情事（如：收養者性侵害被收養人）而被認為與之相牴觸者，則不應拒絕加以承認，以維護法安定性¹⁹⁶。

承上所述，德國實務最常認定為違反公序者，係外國法院未（充分）考量被收養人之出養必要性（Adoptionsbedürfnis）、收養者之養父母適合性（Elterneignung）、雙方間親子關係之發展可能性（Entstehen einer Eltern-Kind-Beziehung），而在意識收養之涉外性的基礎上，進行「未成年子女最佳利益之審查」的情形¹⁹⁷，蓋此事通常意味收養本身並不合於被收養人之福祉¹⁹⁸。亦即，不僅外國法院所適用之收養法並未以未成年子女最佳利益為要件、其裁判理由並未包含任何有關未成年子女最佳利益之說明或僅形式上表示收養合於未成年子女最佳利益者，得拒絕承認外國法院認可收養未成年人裁判¹⁹⁹，如外國法院係基於原生家庭經濟困難等類物質因素肯定出養必要性²⁰⁰、未由收養者所在國專業機構提出養父母適合性之評估

195 Hau (Fn. 4), § 109 Rn. 47; Hausmann (Fn. 39), P. Rn. 131; Helms (Fn. 38), Art. 22 EGBGB Rn. 97; Heiderhoff (Fn. 189), Art. 22 EGBGB Rn. 71; Andrae (Fn. 66), § 7 Rn. 78 aE; 另參見 Rauscher (Fn. 43), § 109 Rn. 44d, 氏認為，被收養人於其母國已無父母，而使其於德國與收養者間發生（或繼續）親子關係較符合其福祉之單純「既成事實」，並非充分之論據。

196 Andrae (Fn. 66), § 7 Rn. 75 aE; Wolfgang Weitzel, Zur Anerkennung ausländischer Adoptionsentscheidungen (AG Hamm, S. 326 und LG Karlsruhe, S. 328), IPRax 2007, S. 308 (312 f.), 氏強調，外國法院定親權裁判與認可收養未成年人裁判，性質上有所不同，而不應為同一處理；Geimer (Fn. 128), S. 474, 氏指出，嗣後拒絕承認外國法院認可收養未成年人裁判，將危害被收養人受基本法及歐洲人權公約所保障之身分地位安定性；不同見解：Majer (Fn. 193), S. 1140.

197 Hausmann (Fn. 39), P. Rn. 130, 133; Rauscher (Fn. 43), § 109 Rn. 45; Henrich (Fn. 75), Art. 22 EGBGB Rn. 88.

198 Andrae (Fn. 66), § 7 Rn. 76.

199 Rauscher (Fn. 43), § 109 Rn. 44c; Sieghörtner (Fn. 41), § 109 Rn. 40.

200 Henrich (Fn. 75), Art. 22 EGBGB Rn. 95.

報告²⁰¹、未基於被收養人與收養者先前接觸預測雙方間親子關係之發展可能性²⁰²，或全然未給予被收養人或其他關係人陳述意見之機會²⁰³，亦得否定其裁判於德國發生效力；相對於此，收養未經受許可之中介機構媒合²⁰⁴、未使收養者與被收養人試行共同生活²⁰⁵、雙方之年齡差距甚大²⁰⁶、共同收養者為同性伴侶²⁰⁷，或收養並無斷絕被收養人與其原父母（及其親屬）間法律關係之效力²⁰⁸等事，並不當然違背未成年子女最佳利益，而不構成前揭拒絕承認事由。

然而，外國法院認可收養未成年人之裁判，縱係未經（充分）「未成年子女最佳利益之審查」所為者，仍難謂應一概拒絕予以承

201 *Hausmann* (Fn. 39), P. Rn. 132；應注意者係：儘管德國實務上雖多受海牙兒童收養公約第15條等規定之影響，而視「收養者所在國專業機構提出養父母適合性之評估報告」一事為「未成年子女最佳利益之審查」的必要內容，以確保收養者能提供被收養人切合其福祉之環境（*Hausmann*, ebd.；亦參見*Henrich* (Fn. 75), Art. 22 EGBGB Rn. 95），然而，姑且不論實務上亦存在不同見解（參見*Andrae* (Fn. 66), § 7 Rn. 77），上開處理模式，雖有助於貫徹兒童權利公約第21條所課予之保護義務，惟容易造成跛行親子關係，且無異於排除德國人不經德國中介機構之媒合收養外國兒童的可能性，而多受批判（*Andrae*, ebd. § 7 Rn. 78; *Helms* (Fn. 38), Art. 22 EGBGB Rn. 105）。學說上毋寧不乏認為德國收養人之適合性評估非必由德國專業機構提出報告為之，而以外國法院取得足以瞭解收養者生活狀態並據以評價其養父母適合性即為已足（*Henrich*, ebd.; *Rauscher* (Fn. 43), § 109 Rn. 45；另參見*Majer* (Fn. 193), S. 1140）。

202 *Rauscher* (Fn. 43), § 109 Rn. 45；保留見解：*Henrich* (Fn. 75), Art. 22 EGBGB Rn. 94.

203 *Rauscher* (Fn. 43), § 109 Rn. 45a; *Hausmann* (Fn. 39), P. Rn. 137; 另參見OLG Frankfurt a. M., FamRZ 2019, S. 1073, Rz. 24 f., 該院認為，被收養人之生母雖未參與收養程序，惟已參與先前之停止親權程序並實質上對於收養事宜有所陳述者，即不能謂其聽審請求權受侵害。

204 *Rolf Behrentin*, in: Würdinger (Hrsg.), *JurisPK BGB, Internationales Privatrecht und UN-Kaufrecht*, Bd. 6, 9. Aufl., 2020, Art. 22 EGBGB Rn. 108 f.

205 *Helms* (Fn. 38), Art. 22 EGBGB Rn. 104 aE.

206 *Rauscher* (Fn. 43), § 109 Rn. 47 aE.

207 *Heiderhoff* (Fn. 189), Art. 22 EGBGB Rn. 69 aE; 亦參見*Phillipp Reuß*, *Gestaltung des europäischen abstammungsrechtlichen Kaleidoskops — Einige Überlegungen zur Anerkennung der niederländischen Duo-Mutterschaft in Deutschland*, in: Hilbig-Lugani u. a. (Hrsg.), *Zwischenbilanz — Festschrift für Dagmar Coester-Waltjen zum 70. Geburtstag*, 2015, S. 681 (690).

208 *Andrae* (Fn. 66), § 7 Rn. 81; *Henrich* (Fn. 75), Art. 22 EGBGB Rn. 97.

認。毋寧是，尤其於承認及效力確認程序（上述「貳、一、（一）、3.」），學說上傾向認為德國法院非不得補行「未成年子女最佳利益之審查」²⁰⁹，如其調查結果（如：養父母適合性之評估報告、親子關係發展狀態之訪視報告）顯示收養與德國收養法原則相合致²¹⁰，即可視上開審判程序之瑕疵已經補正，而否定公序之違反，以防止跛行親子關係之形成²¹¹，並避免須另為重複收養之不便²¹²，而促進未成年子女最佳利益²¹³；此時，德國法院並非對於外國裁判為實質審查，而係斟酌嗣後發生之情事並據此衡量被收養人之福祉²¹⁴，自無違禁止實質再審查原則（德家非109 V）²¹⁵。即使贊同實務上出於維持承認及效力確認程序之形式性、確保潛在外國收養未成年

209 參見Behrentin (Fn. 204), Art. 22 EGBGB Rn. 99, 107 aE, 114, 氏另指出，除「未成年子女最佳利益之審查」外，於承認及效力確認程序所得補行者，尚包含取得原欠缺之被收養人或本生父母的同意。

210 參照BT-Drucks. 14/6011, S. 29.

211 Andrae (Fn. 66), § 7 Rn. 78; Henrich (Fn. 75), Art. 22 EGBGB Rn. 95.

212 Helms (Fn. 38), Art. 22 EGBGB Rn. 102, 氏指出，現實上多不可能為重複收養，蓋除難以使身處外國之本生父母參與收養程序外，在諸多歷時甚久之收養，其有無效力成為遺產爭議之先決問題的情形，亦無從為重複收養；Heiderhoff, FS Geimer (Fn. 27), S. 241.

213 Helms (Fn. 38), Art. 22 EGBGB Rn. 102 f., 氏另指出，依照此項見解，絕大多數未經適當程序之外國收養最終均會被承認，而得對潛在之外國被收養人有所不利，因此，如收養程序之瑕疵頗為重大，且被收養人尚未中斷與本生父母間照護關係，仍得拒絕承認之，以兼顧其利益以達一般預防之目的；Hausmann (Fn. 39), P. Rn. 135, 氏認為，設重複收養將符合未成年子女最佳利益而受德國法院准許，即不能拒絕承認外國裁判，而要求關係人另為重複收養，蓋外國法院認可收養裁判既無違未成年子女最佳利益，其承認之結果自無抵觸德國公序之餘地；同旨：Dimmler (Fn. 46), § 109 Rn. 23 aE；亦參見Majer (Fn. 193), S. 1140, 氏認為，不論外國法院是否或如何進行「未成年子女最佳利益之審查」，德國法院均必須審認於承認判定時收養是否符合未成年子女最佳利益。

214 Helms (Fn. 38), Art. 22 EGBGB Rn. 102; Heiderhoff (Fn. 189), Art. 22 EGBGB Rn. 71; Andrae (Fn. 66), § 7 Rn. 78 aE; Christian F. Majer, Anerkennung einer Auslandsadoption (Gambia), NZFam 2019, S. 696 (696); Christian F. Majer, OLG Frankfurt a. M.: Nichtanerkennung einer Adoptionsentscheidung mangels Kindeswohlprüfung, NZFam 2020, S. 46 (46); Andreas Botthof, Anmerkung, FamRZ 2016, S. 29 (30)；保守見解：Rauscher (Fn. 43), § 109 Rn. 44d aE.

215 Hau (Fn. 4), § 109 Rn. 65 aE.

人程序之公正性等理由，反對補行「未成年子女最佳利益之審查」的見解²¹⁶，為避免拒絕承認反將在個案中危害未成年子女最佳利益，法院仍應在此限度內為一定之事證調查（如：聽取被收養人之意見）²¹⁷，如拒絕承認外國裁判有過度侵害個別被收養人福祉之虞，即必須例外限制家事及非訟法第109條第1項第4款之適用，而予以承認²¹⁸。

至於外國法院認可收養未成年人裁判是否係依德國民法施行法第22條所指定之準據法所為，或是否符合同法第23條之規定，則非所問²¹⁹，蓋（舊）非訟法第16條之1之立法者已明確排除國際私法之考量，而全面採取程序法上承認²²⁰；在此意義上，外國法院所為準據法之選擇，自德國法之觀點縱屬錯誤，仍應接受之²²¹。

（三）承認之效果

1. 基本原則

德國家事及非訟法第108條、第109條第1項、第5項及第110條第1項所設外國裁判承認（及執行）制度，並未明文規定合於承認要件之外國裁判究應於德國發生如何之效力²²²。不過，前揭條文既

216 OLG Frankfurt a. M., NJW-RR 2020, S. 326, Rz. 19; OLG München, BeckRS 2019, S. 10471, Rz. 15; 關於德國實務上傾向認為法院不得補行「未成年子女最佳利益之審查」，參見Siegthörtner (Fn. 41), § 109 Rn. 40.

217 另參見BVerfG, NJW 2016, S. 626, Rz. 24, 38, 該院認為，法院於依職權調查拒絕承認事由之存否時，如顯然忽略有助於解明事案之手段，即違反實效權利保護之要求而違憲。

218 Heiderhoff, FS Geimer (Fn. 27), S. 241 f.; Heiderhoff, Standards und Abgrenzungen (Fn. 27), S. 69 f.

219 Hausmann (Fn. 39), P. Rn. 143; Rauscher (Fn. 43), § 109 Rn. 47; Heiderhoff (Fn. 189), Art. 22 EGBGB Rn. 68; Helms (Fn. 38), Art. 22 EGBGB Rn. 108; 關於民法施行法第23條所要求關係人之同意與（舊）非訟法第16條之1所定公序之保留條款間之關係，參見BT-Drucks. 10/504, S. 93.

220 Henrich (Fn. 75), Art. 22 EGBGB Rn. 86; 前揭註63。

221 Behrentin (Fn. 204), Art. 22 EGBGB Rn. 118.

222 Spellenberg (Fn. 43), § 108 FamFG Rn. 173.

係承繼自（舊）非訟法第16條之1之規定，而後一條文之立法者已表示：「所謂外國裁判之承認，係指該裁判原則上於內國發生其裁判國所賦予之效力」²²³，自應認為家事及非訟法係採取通說所支持之效力延伸說（*Wirkungserstreckung*），而非視外國裁判為同種類德國裁判之同效力說²²⁴。依照效力延伸說，外國裁判具備承認適格性者，其於該外國所得發生之效力，除內容上為德國法所完全陌生或範圍上已廣泛至違背德國公序之程度者外²²⁵，亦延伸至德國²²⁶，而於該外國本不發生之效力，既無從加以延伸，自不因同種類德國裁判有此效力而額外取得之（如：准予別居之外國裁判於德國無離婚之效力）²²⁷。

上開外國裁判得受程序法上承認而於德國發生之效力，僅限於自德國法之觀點得定性為程序法效力者（含：既判力、參加效、執行力及形成力）²²⁸。其中，相對於承認外國民事訴訟裁判之效果係

223 BT-Drucks. 10/504, S. 93.

224 *Wagner* (Fn. 7), S. 1628; *Sieghörtner* (Fn. 41), § 108 Rn. 45; *Hau* (Fn. 4), § 108 Rn. 10; *Spellenberg* (Fn. 43), § 108 FamFG Rn. 174; 關於「同效力說」之具體內涵，參見 *Haimo Schack*, „Anerkennung“ ausländischer Entscheidungen, in: Becker-Eberhard u. a. (Hrsg.), *Rechtslage — Rechtserkenntnis — Rechtsdurchsetzung*. Festschrift für Eberhard Schilken zum 70. Geburtstag, 2015, S. 445 (450).

225 關於內容上之限制，參見 *Dimmler* (Fn. 46), § 108 Rn. 3; *Borth/Grandel* (Fn. 64), § 108 Rn. 8; *Rauscher* (Fn. 43), § 108 Rn. 20; 關於範圍上之限制，參見 *Hau* (Fn. 4), § 108 Rn. 11; *Spellenberg* (Fn. 43), § 108 FamFG Rn. 176; 亦參見 *Wagner* (Fn. 7), S. 1629.

226 *Hau* (Fn. 4), § 108 Rn. 11; *Spellenberg* (Fn. 43), § 108 FamFG Rn. 175 aE.

227 *Hau* (Fn. 4), § 108 Rn. 12，氏並指出，外國裁判之效力依其本國法原僅限於該國領域內者，亦無延伸至德國之餘地；*Spellenberg* (Fn. 43), § 108 FamFG Rn. 175; *Rauscher* (Fn. 43), § 108 Rn. 19.

228 *Hau* (Fn. 4), § 108 Rn. 13, 15，氏並指出，於非訟事件特別容易發生外國裁判（如：核發繼承證書、許可監護人之法律行為）有無得予承認之程序法效力的疑問；*Sieghörtner* (Fn. 41), § 108 Rn. 45 aE; *Klinck* (Fn. 54), S. 745; 另參見 *Schack* (Fn. 224), S. 446; 關於應依承認國法對於外國法院裁判之效力進行定性以決定得於承認國發生者，參見 *Klinck*, ebd.; *Wagner* (Fn. 7), S. 1628; *Geimer* (Fn. 130), Rn. 2787; 亦參照 *Schack*, *IZVR*⁷ (Fn. 51), Rn. 1020.

以其既判力為重點，外國（家事）非訟裁判則著重於其形成力²²⁹。儘管早期學說上鑑於法院變動身分地位之法律基礎及效果與實體法規範間之密切連結（如：德民1564），為求國際間法律關係之一致性，主張應對於外國裁判之形成力為所謂衝突法上相對化（*kollisionsrechtliche Relativierung*），而視德國法律衝突規範所指定之原因關係準據法所屬國（含：德國、裁判國或第三國）是否承認該裁判，以決定其得否於德國發生效力之見解（所謂原因關係準據法說）²³⁰，非但忽略原因關係準據法與國際管轄權間之非併行性所凸顯國際民事程序法不同於國際私法的獨自性²³¹，且亦不足以完全確保裁判之無矛盾性²³²，更因1986年之國際私法改正法案明確肯定國際民事程序法之優先性（上述「貳、一、（二）、1.」），而為現今通說所不採²³³。不過，此並不表示與外國法院變動身分地位所據之實體法規範毫無重要性，毋寧是，外國裁判所得生形成力之內容及範圍，仍應依裁判國法即該外國法院所適用之法決之²³⁴。

外國裁判滿足承認要件者，其於該外國所得發生之效力，原則上於德國亦有之，已如前述。此事並不妨礙德國法院加以變更（*Abänderung*）²³⁵，以符合現實需要；無論裁判國法是否容許之，

229 *Geimer* (Fn. 1), vor § 97 FamFG Rn. 12; *Reinhold Geimer*, Internationale Freiwillige Gerichtsbarkeit, in: Mansel u. a. (Hrsg.), Festschrift für Erik Jayme, Bd. 1, 2004, S. 241 (250).

230 參見 *Geimer* (Fn. 1), vor § 97 FamFG Rn. 13; *Geimer* (Fn. 130), Rn. 44 f.; *Spellenberg* (Fn. 43), § 108 FamFG Rn. 185.

231 *Geimer* (Fn. 130), Rn. 46 f., 2814.

232 *Spellenberg* (Fn. 43), § 108 FamFG Rn. 186; *Kropholler* (Fn. 63), S. 636; 亦參見 *von Hein* (Fn. 129), Ein. IPR Rn. 213.

233 *Hau* (Fn. 4), § 108 Rn. 22; *Spellenberg* (Fn. 43), § 108 FamFG Rn. 186; *Nagel/Gottwald* (Fn. 130), § 12 Rn. 126 f.; *Kropholler* (Fn. 63), S. 636; 不同見解： *Loyal* (Fn. 11), S. 392 f.

234 *Rauscher* (Fn. 43), § 108 Rn. 18; *Geimer* (Fn. 130), Rn. 2816 f.; *Nagel/Gottwald* (Fn. 130), § 12 Rn. 127 aE.

235 *Sieghörtner* (Fn. 41), § 108 Rn. 46.

均不生國際公法上之疑慮²³⁶。換言之，德國法院對於系爭事件有國際管轄權者，原則上即得調整外國裁判之承認效果²³⁷。至於決定是否變更外國裁判（即：變更之要件）所應適用之法律為何，學說上雖存在法庭地法程序說與原因關係準據法說之對立²³⁸，惟外國裁判既係經程序法上承認，其效力自應受承認國包含變更裁判制度在內之程序法規範之限制，而應依德國家事及非訟法第238條等類規定決之²³⁹；外國裁判應予變更者，除發生（真正）準據法變更（*Statutenwechsel*）外，應依外國裁判所據實體法決定如何變更之（即：變更之標準）²⁴⁰。

2. 父母責任事件

上述（「貳、一、（三）、1.」）德國家事及非訟法解釋論上所採取之效力延伸說及變更外國裁判之容許性，均通用於外國法院定親權裁判之承認：一方面，依照效力延伸說²⁴¹，外國法院酌定由父母之一方照護未成年子女並保留他方探視機會之裁判，依其所適用之法（如：塞爾維亞家族法第77條第3項²⁴²）並未排除他方的重大事項共同決定權者，於德國尚不能發生如同德國法院依德國法酌定單獨親權人之效力²⁴³，否則不啻在未受程序保障的狀況下完全剝奪他方之親權²⁴⁴；同樣地，如外國法院於酌定父母一方為單獨親權人時並未同時命他方交付子女，該裁判於德國除有規制親權歸屬之形成

236 Schack, IZVR⁷ (Fn. 51), Rn. 1108, 1110, 1113; Hau (Fn. 4), § 108 Rn. 26.

237 Dimmler (Fn. 46), § 108 Rn. 14.

238 參見Schack, IZVR⁷ (Fn. 51), Rn. 1114; Ulrich Meyer-Holz, in: Keidel/Engelhardt/Sternal (Hrsg.), FamFG, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 20. Aufl., 2020, § 238 Rn. 11a.

239 參見Schack, IZVR⁷ (Fn. 51), Rn. 1115, 1118; Meyer-Holz (Fn. 238), § 238 Rn. 11a.

240 參見BGH, NJW 2015, S. 694, Rz. 23 ff.

241 Hausmann (Fn. 39), N. Rn. 623.

242 OLG Hamm, FamRZ 2014, S. 1935.

243 Hau (Fn. 4), § 108 Rn. 12; Rauscher (Fn. 43), § 108 Rn. 19.

244 Bettina Heiderhoff, Anmerkung, FamRZ 2014, S. 1937 (1937).

力外，能否發生強制交付子女予親權人之執行力²⁴⁵，亦必須依該外國法院所適用之法決之²⁴⁶。另一方面，基於變更外國法院定親權裁判之原則上容許性²⁴⁷，如外國法院作成裁判後情事有所改變（如：單獨親權人遭判刑入獄）²⁴⁸，德國法院得審判管轄該「父母責任事件」者（德家非99）²⁴⁹，自得循同法第166條所定程序，依其應適用之法律予以變更²⁵⁰，以謀求未成年子女最佳利益²⁵¹；此事亦不違反禁止實質再審查原則（德家非109 V）²⁵²。

3. 收養未成年人事件

上述（「貳、一、（三）、1.」）德國家事及非訟法解釋論上所採取之效力延伸說，亦通用於外國法院收養未成年人裁判之承認：外國法院（或其他公權機關）所為之收養宣告或經實質審查而核可之收養契約，既屬程序法上承認之對象（上述「貳、一、（二）、3.」），而應肯定國際民事程序法之優先性，其承認要件及效果自與德國民法施行法第22條、第23條所指定之原因關係準據法無涉²⁵³。毋寧是，依照效力延伸說²⁵⁴，外國法院認可收養未成年人之裁判，依其所適用之法（如：伊朗無監護人兒童保護法第1條至第3條、第5條、第6條及第11條²⁵⁵）並不斷絕被收養人與其原父母（及其親

245 關於外國法院定親權裁判之效力類型，參見Hausmann (Fn. 39), N. Rn. 625, 659.

246 Hau (Fn. 4), § 108 Rn. 11 aE; Henrich (Fn. 75), Art. 21 EGBGB Rn. 263.

247 Hausmann (Fn. 39), N. Rn. 624 aE; Henrich (Fn. 75), Art. 21 EGBGB Rn. 253 f.

248 另參見Spellenberg (Fn. 43), § 109 FamFG Rn. 223，氏主張，縱情事無所改變，亦得變更定親權裁判。

249 Henrich (Fn. 75), Art. 21 EGBGB Rn. 255.

250 Andrae (Fn. 66), § 6 Rn. 199; Henrich (Fn. 75), Art. 21 EGBGB Rn. 260.

251 Schack, IZVR⁷ (Fn. 51), Rn. 1110.

252 Hausmann (Fn. 39), N. Rn. 657.

253 參見Helms (Fn. 38), Art. 22 EGBGB Rn. 91; Rauscher (Fn. 43), § 109 Rn. 10 aE; Behrentin (Fn. 204), Art. 22 EGBGB Rn. 118 aE：「……在外國收養於德國發生效力之限度內，該外國法排除民法施行法第22條第1項及第2項所指定法律之適用」。

254 Hausmann (Fn. 39), P. Rn. 110.

255 OLG Köln, NJOZ 2012, S. 1341 (1342).

屬)之法律關係者，於德國即不能發生如同德國法院依德國法宣告收養之效力²⁵⁶，蓋關係人之同意及法院之審查均僅及於該法所定之收養型態²⁵⁷。

相對於此，前揭變更外國裁判之容許性，除亦有以下意義外，即：外國法院認可收養未成年人裁判所成立之收養關係，得由具收養事件國際管轄權(德家非101)之德國法院基於嗣後發生之情事(如：養女指控養父長期性侵)宣告終止²⁵⁸，更反映於德國收養效力法第3條、第5條及第6條所創設之效力強化(或稱：轉換)程序(Umwandlungsverfahren)。申言之，為儘可能於內國一致化收養之效力及避免必須另為重複收養所生之困擾，而透過簡速之程序使被收養人徹底斷絕單純收養(schwache Adoption)所殘餘之親子關係，並以完全收養(Volladoption)之形式在法律上全面融入收養家庭²⁵⁹，受啟發於海牙兒童收養公約第27條之規定(下述「貳、三、(三)」)²⁶⁰，德國收養效力法第3條明定：「第2條第3項第1句第2款規定之情形，具備下列各款要件者，家事法院得依聲請，宣告未成年子女有同於依德國實質規定所收養者之法律地位：一、有助於未成年子女之最佳利益者。二、有必要時，終結親子關係之收養經同意者。三、對於收養者或被收養者之配偶、伴侶或子女無重大不利者。第1句第2款所稱同意之必要性及其表示，依收養之同意所應適用之條文及民法施行法第6條之規定為之。未成年子女之同意，並依民法第1746條之規定為之。被收養者於法院為第1句之裁定時已滿18歲者，不適用第1句第1款所定條件(第1項)。第2條第3項第1句第1款規定之情形，收養之效力異於依德國實質規定所為之收養

256 Heiderhoff(Fn. 189), Art. 22 EGBGB Rn. 67; Andrae(Fn. 66), § 7 Rn. 82.

257 Hausmann(Fn. 39), P. Rn. 111; Helms(Fn. 38), Art. 22 EGBGB Rn. 110.

258 參見Andrae(Fn. 66), § 7 Rn. 96 ff.; Helms(Fn. 38), Art. 22 EGBGB Rn. 48 f.

259 參見Busch(Fn. 77), S. 14, 16; Helms(Fn. 38), § 3 AdWirkG Rn. 1; Weitzel(Fn. 76), § 3 Rn. 1.

260 BT-Drucks. 14/6011, S. 30 f.

者，準用第1項之規定（第2項）。依此，外國認可收養未成年人裁判經裁定確認其承認適格性者（德收養效力2 I）²⁶¹，德國法院得依單獨收養者或共同收養之夫妻（德收養效力5 I 1 ①、②）之聲請，依家事非訟事件所應適用之程序規範（如：職權探知主義）及收養效力法第6條第3項第2句、第4句分別針對被收養人、收養者、原父母及主管機關所設之特別程序參與規定²⁶²，於確定相關人等（如：原父母、被收養人）已為必要之同意（德收養效力3 I 1 ②）²⁶³、收養效力之強化對於被收養人更為有利（德收養效力3 I 1 ①）²⁶⁴且對於特定第三人不造成過度之不利益（德收養效力3 I 1 ③）²⁶⁵後，以裁定宣示被收養人取得如同收養者親生子女之法律地位，其形成力並有變更收養準據法為德國法之效果²⁶⁶，而其既判力原則上亦具拘束全體（含：法院及行政機關）之對世效（德收養效力5 II 1）²⁶⁷。

二、布魯塞爾第二之一規則與海牙兒童保護公約

布魯塞爾第二之一規則關於歐盟成員國（不含：丹麥）法院針對相當於本文所稱「未成年子女親權事件」之「父母責任（elterliche Verantwortung）事件」（布魯塞爾二1 I ②、II）所為裁判

²⁶¹ Hausmann (Fn. 39), P. Rn. 85; Helms (Fn. 38), § 3 AdWirkG Rn. 3.

²⁶² Helms (Fn. 38), § 5 AdWirkG Rn. 2 f., 10；關於「效力強化事件」應否定性為收養事件（德家非186）之爭議，參見Weitzel (Fn. 76), § 5 Rn. 4.

²⁶³ 參見Heiderhoff (Fn. 189), Art. 22 EGBGB Rn. 72; Weitzel (Fn. 76), § 3 Rn. 6 f.，氏指出，在重新取得原父母之同意事實上有所困難的情形，亦可能適用公序之保留條款（德收養效力3 I 2、德民施6），而依德國民法第1747條第4項之規定免得其同意，以保護被收養人之利益。

²⁶⁴ 參見Weitzel (Fn. 76), § 3 Rn. 8; Hausmann (Fn. 39), P. Rn. 81，氏認為，被收養人與原家庭已無聯繫者，多符合此條件，而如被收養人將喪失請求原父母扶養或繼承之權利，則不屬之。

²⁶⁵ 參見Helms (Fn. 38), § 3 AdWirkG Rn. 7，氏認為，此一要求實際上幾無意義。

²⁶⁶ Weitzel (Fn. 76), § 3 Rn. 11; Andrae (Fn. 66), § 7 Rn. 95.

²⁶⁷ Weitzel (Fn. 76), § 4 Rn. 5; Helms (Fn. 38), § 4 AdWirkG Rn. 10，氏並指出，縱原父母並未參與效力強化程序，亦受既判力所及，而與承認及效力確認程序有所不同（參見前揭註82）。

之承認（及執行），係規定於第21條至第52條：第21條及第26條規定其承認程序、第23條及第24條規定拒絕承認事由，而第28條及第40條則規定給付裁判之執行力；海牙兒童保護公約關於締約國權責機關（authority）針對「父母責任（parental responsibility）事件」（海牙兒保1 II、3）所為措施（measure）之承認（及執行），係規定於第23條至第28條：第24條及第27條規定其承認程序、第23條及第25條規定拒絕承認事由，而第26條及第28條則規定給付措施之執行力。不論係布魯塞爾第二之一規則，抑或海牙兒童保護公約，既均以促進未成年子女最佳利益為宗旨²⁶⁸，上開規範之創設與運作自亦（應）反映未成年子女最佳利益原則²⁶⁹；此尤見於公序之保留條款的立法與解釋²⁷⁰。

（一）承認之程序

布魯塞爾第二之一規則第21條第1項、第4項分別規定：「成員國之裁判於其他成員國之承認，無庸依特別之程序為之」、「裁判之承認為其他成員國法院受理事件之先決問題者，該法院得審判之」；海牙兒童保護公約第23條第1項規定：「締約國權責機關之措施於其他締約國之承認，依法（by operation of law）為之」。準此，如同德國家事及非訟法（上述「貳、一、（一）、1.及2.」），布魯塞爾第二之一規則亦明白採取自動承認制及所謂中間承認之規範

268 關於布魯塞爾第二之一規則，參見Dagmar Coester-Waltjen, Die Berücksichtigung der Kindesinteressen in der neuen EU-Verordnung Brüssel IIa, FamRZ 2005, S. 241 (241)；關於海牙兒童保護公約，參見Reinhard Huter, in: Gitschthaler (Hrsg.), Internationales Familienrecht, 2019, Vorbem. KSÜ Rn. 26.

269 關於布魯塞爾第二之一規則與海牙兒童保護公約在承認法上的繼受關係，參見Huter (Fn. 268), vor Art. 23 KSÜ Rn. 21.

270 關於布魯塞爾第二之一規則，參見Thomas Rauscher, in: Rauscher (Hrsg.), Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR, Bd. 3, 4. Aufl., 2016, Art. 23 Brüssel IIa-VO Rn. 4；關於海牙兒童保護公約，參見Katharina Hilbig-Lugani, in: Rauscher (Hrsg.), Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR, Bd. 5, 4. Aufl., 2016, Art. 23 KSÜ Rn. 20.

模式²⁷¹；海牙兒童保護公約，亦然²⁷²。相對於此，不同於前揭德國家事及非訟法，外國裁判或措施具給付性而有予以執行之必要者，依照布魯塞爾第二之一規則第28條之規定，除涉及會面交往權之行使（布魯塞爾二41）或誘綁子女之返還（布魯塞爾二42）而符合一定之條件者外（布魯塞爾二40）²⁷³，應先經他承認國法院循簡速（即：不賦予相對人、未成年子女聽審機會）之許可執行程序（布魯塞爾二31 I）為執行宣告，始得為之²⁷⁴；依照海牙兒童保護公約第26條之規定，亦應經承認國循簡單且迅速（simple and rapid）（海牙兒保26 II）之許可執行程序為執行宣告後行之²⁷⁵。

此外，如同德國家事及非訟法，為謀求法安定性，布魯塞爾第二之一規則第21條第3項亦明文創設獨立、任意之承認確認程序，而允許利害關係人循許可執行程序所應適用之程序規範，請求承認國法院確認外國裁判有無承認適格性，其裁判並多被認為僅具相對效（*inter partes*）²⁷⁶；海牙兒童保護公約第24條同樣設有獨立、任意之承認確認程序，利害關係人得循承認國所設非必同於許可執行程序之程序規範，請求承認國權責機關確認外國措施是否合於承認要件，其裁判則多被認為得生對世效²⁷⁷。

271 Rauscher (Fn. 270), Art. 21 Brüssel IIa-VO Rn. 15, 19 ff., 氏並指出，布魯塞爾第二之一規則第21條第4項僅具注意規定之性質。

272 Hausmann (Fn. 39), N. Rn. 356.

273 Andrea Schulz, Das Vollstreckungssystem in der neuen Brüssel IIa-Verordnung, in: Budzikiewicz u. a. (Hrsg.), Standards und Abgrenzungen im Internationalen Familienrecht, 2019, S. 93 (95 f.); 亦參見Peter Gottwald, in: Rauscher (Hrsg.), Münchener Kommentar zum FamFG, Bd. 2, 3. Aufl., 2019, Art. 28 Brüssel IIa-VO Rn. 3 aE.

274 Andrae (Fn. 66), § 6 Rn. 175 ff., 183.

275 Hilbig-Lugani (Fn. 270), Art. 26 KSÜ Rn. 8.

276 Bettina Heiderhoff, in: von Hein (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bd. 12, 8. Aufl., 2020, Art. 21 Brüssel IIa-VO Rn. 5; Gottwald (Fn. 273), Art. 21 Brüssel IIa-VO Rn. 7.

277 Hilbig-Lugani (Fn. 270), Art. 24 KSÜ Rn. 1, 6, 氏並指出，海牙兒童保護公約第24條第2句並未如同公約第26條第2項般要求承認確認程序亦應簡單且迅速，而應採行對審程序。

承認國無論在何種場合審查外國裁判或措施之承認適格性，在未牴觸承認國之公共秩序（public policy）（下簡稱：公序）的限度內，均應遵守德國家事及非訟法同樣定有明文之禁止實質再審查（no review of the merits）原則，此觀布魯塞爾第二之一規則第26條謂：「對於裁判，要不得為實質審查」²⁷⁸、海牙兒童保護公約第27條謂：「對於措施，除適用前述條文而有必要者外，不得為實質審查」等語即明²⁷⁹。

（二）承認之要件

布魯塞爾第二之一規則第23條規定：「關於父母責任之裁判，有下列各款情形之一者，不予承認：一、經斟酌未成年子女之最佳利益，承認顯然違背受請求承認之成員國之公共秩序者。二、除有急迫情事外，裁判之程序未予未成年子女聽審機會，而違背受請求承認之成員國之程序法上基本原則者。三、受影響之人未參與程序，而開始程序或相類之文書未適時且未以其得為防禦之方式送達之。但能確定其明確同意該裁判者，不在此限。四、裁判之程序未予父母責任受限制之人聽審機會，經其請求拒絕承認者。五、裁判與其後於受請求承認之成員國作成之關於父母責任之裁判相牴觸者。六、裁判與其後於其他成員國作成，或於未成年子女習慣居所所在之第三國作成，而合於受請求承認之成員國之承認要件之關於父母責任之裁判相牴觸者。七、未遵守第56條所定程序者」；海牙兒童保護公約第23條第2項規定：「有下列各款情形之一者，仍得拒絕承認之：一、依第2章之規定，作成措施之權責機關無管轄權者。二、除有急迫情事外，作成措施之司法或行政程序未予未成年子女聽審機會，而違背受請求承認國之重要程序原則者。三、除有

278 Heiderhoff (Fn. 276), Art. 26 Brüssel IIa-VO Rn. 1; Gottwald (Fn. 273), Art. 26 Brüssel IIa-VO Rn. 1 f.

279 Hilbig-Lugani (Fn. 270), Art. 27 KSÜ Rn. 1, 4.

急迫情事外，作成措施之程序未予父母責任受妨害之人聽審機會，經其請求拒絕承認者。四、經斟酌未成年子女之最佳利益，承認顯然違背受請求承認國之公共秩序者。五、措施與其後於未成年子女習慣居所所在之非締約國作成，而合於受請求承認國之承認要件之措施相牴觸者。六、未遵守第33條所定程序者」。上開二條文所定拒絕承認事由，均具窮盡列舉之性質²⁸⁰，且因承認之拒絕皆被認為係屬承認原則之例外，而應為限縮之解釋²⁸¹。準此，如同德國家事及非訟法（上述「貳、一、（二）、1.及2.」），布魯塞爾第二之一規則否定離婚裁判與定親權裁判之承認關連性²⁸²，且不對於外國裁判從事衝突法上控制²⁸³；海牙兒童保護公約，亦無不同²⁸⁴。不過，如有上開拒絕承認事由之一，布魯塞爾第二之一規則雖同於德國家事及非訟法，以拒絕承認為必要，惟海牙兒童保護公約則明文賦予承認國權責機關不拒絕承認之裁量權²⁸⁵，以兼顧未成年子女最佳利益²⁸⁶。

如進一步比較前述德國家事及非訟法與布魯塞爾第二之一規則、海牙兒童保護公約所設承認要件之異同，可知：

第一，就承認標的適格而言，相較於德國家事及非訟法，布魯塞爾第二之一規則雖亦不要求成員國裁判（布魯塞爾二2 ④）之確定（即：形式確定力），惟僅在暫時處分係由本案事件管轄法院所

280 關於布魯塞爾第二之一規則，參見Gottwald (Fn. 273), Art. 23 Brüssel IIa-VO Rn. 1；關於海牙兒童保護公約，參見PAUL LAGARDE, EXPLANATORY REPORT ON THE 1996 HAGUE CHILD PROTECTION CONVENTION para. 128 (1998).

281 關於布魯塞爾第二之一規則，參見EuGH, 19.11.2015 – C-455/15 PPU – P, Rz. 35 f.; 關於海牙兒童保護公約，參見Huter (Fn. 268), Art. 23 KSÜ Rn. 9 f.

282 Andrae (Fn. 66), § 6 Rn. 154; Rauscher (Fn. 270), Art. 23 Brüssel IIa-VO Rn. 2.

283 Hausmann (Fn. 39), N. Rn. 85 aE; Marco Nademleinsky/Matthias Neumayr, Internationales Familienrecht, 2. Aufl., 2017, Rz. 08.99.

284 LAGARDE, *supra* note 280, at para. 128; Hilbig-Lugani (Fn. 270), Art. 23 KSÜ Rn. 10, 22; Huter (Fn. 268), Art. 27 KSÜ Rn. 5.

285 Huter (Fn. 268), Art. 23 KSÜ Rn. 14; LAGARDE, *supra* note 280, at para. 121.

286 Andrae (Fn. 66), § 6 Rn. 154 aE.

為之情形，始肯定其得依同規則予以承認（及執行）²⁸⁷；海牙兒童保護公約則既不以締約國之措施（海牙兒保1、3）已確定為必要，亦一概肯定暫時處分得依同公約加以承認（及執行）²⁸⁸。至於具執行力之公權證書或程序上和解，布魯塞爾第二之一規則另準用裁判之承認（及執行）規範，而亦對之為程序法上承認（布魯塞爾二46）²⁸⁹。

第二，就承認管轄權而言，不同於德國家事及非訟法，基於歐盟成員國彼此間相互信賴之基本原則及外國裁判承認（及執行）之簡速要求，布魯塞爾第二之一規則第24條禁止承認國審查裁判國法院國際管轄權之有無，且表明國際管轄規範亦非屬同規則第23條第1款所稱公序之內涵²⁹⁰；鑑於海牙公約締約國彼此間之相互信賴尚未達到上開程度，海牙兒童保護公約仍以承認管轄權為拒絕承認事由（之一）²⁹¹，不過，為謀求外國措施承認（及執行）之簡易、迅速，同公約第25條明定承認國於審查裁判國權責機關有無國際管轄權時，應受後者所認定管轄基礎事實（含：合於未成年子女最佳利益之評價²⁹²）之拘束²⁹³。

第三，就程序開始之通知而言，類似於德國家事及非訟法，布魯塞爾第二之一規則明文保障關係人適時受程序開始通知之權利（布魯塞爾二23 ③），並在解釋上不課予未參與程序且未受通知者救濟之對己義務²⁹⁴；海牙兒童保護公約則未設置類似之拒絕承認事

287 Hausmann (Fn. 39), N. Rn. 52 f., 39.

288 Huter (Fn. 268), vor Art. 23 KSÜ Rn. 13, 15.

289 Rauscher (Fn. 270), Art. 46 Brüssel IIa-VO Rn. 1 f., 4.

290 Thomas Garber, in: Gitschthaler (Hrsg.), Internationales Familienrecht, 2019, Art. 24 Brüssel IIa-VO Rn. 1.

291 Hilbig-Lugani (Fn. 270), Art. 23 KSÜ Rn. 11 f.

292 參見LAGARDE, *supra* note 280, at para. 131.

293 Hilbig-Lugani (Fn. 270), Art. 25 KSÜ Rn. 1.

294 Gottwald (Fn. 273), Art. 23 Brüssel IIa-VO Rn. 6 f.

由，而係透過公序之保留條款（海牙兒保23 II ④）加以顧慮²⁹⁵。

第四，就裁判之衝突而言，相反於德國家事及非訟法，布魯塞爾第二之一規則明白採取後裁判優先原則（*Posterioritätsprinzip*）（布魯塞爾二23 ⑤、⑥），蓋在定親權裁判有其可變更性的前提上，後裁判常能斟酌前裁判並斟酌嗣後發生之情事，而更符合未成年子女最佳利益²⁹⁶；海牙兒童保護公約亦出於同樣之理由，採用後裁判優先原則（海牙兒保23 II ⑤）²⁹⁷。

第五，就公序而言，布魯塞爾第二之一規則第23條第1款與海牙兒童保護公約第23條第2項第4款所定公序，如同德國家事及非訟法，亦可區別為實體公序及程序公序二大面向²⁹⁸，而其不同之處，則在於上開二條文明白提及處理「父母責任事件」本必須加以斟酌之未成年子女最佳利益²⁹⁹，以及原屬程序公序內涵之聽審請求權保障，在涉及未成年子女及其親權人之限度內，已被明定為獨立之拒絕承認事由（布魯塞爾二23 ②、④、海牙兒保23 II ②、③³⁰⁰）二者。申言之，一方面，未成年子女最佳利益原則作為判斷承認國之公序是否遭違反之核心標準³⁰¹，應依循兒童權利公約所揭示之指標³⁰²，並兼顧其他家庭相關基本人權（如：歐洲人權8、14）³⁰³，在外國法院定親權裁判之承認將重大損害未成年子女最佳利益之情

295 Jutta Krah, Das Haager Kinderschutzübereinkommen, 2004, S. 258.

296 Gottwald (Fn. 273), Art. 23 Brüssel IIa-VO Rn. 10; Andrae (Fn. 66), § 6 Rn. 169.

297 Krah (Fn. 295), S. 255; Hilbig-Lugani (Fn. 270), Art. 23 KSÜ Rn. 25.

298 關於布魯塞爾第二之一規則，參見Hausmann (Fn. 39), N. Rn. 82；關於海牙兒童保護公約，參見Krah (Fn. 295), S. 254.

299 Gottwald (Fn. 273), Art. 23 Brüssel IIa-VO Rn. 2; Andrae (Fn. 66), § 6 Rn. 162.

300 關於布魯塞爾第二之一規則，參見Heiderhoff (Fn. 276), Art. 23 Brüssel IIa-VO Rn. 5；關於海牙兒童保護公約，參見Krah (Fn. 295), S. 252 ff.

301 Rauscher (Fn. 270), Art. 23 Brüssel IIa-VO Rn. 4; Hilbig-Lugani (Fn. 270), Art. 23 KSÜ Rn. 20.

302 Hilbig-Lugani (Fn. 270), Art. 23 KSÜ Rn. 20.

303 Rauscher (Fn. 270), Art. 23 Brüssel IIa-VO Rn. 6a; Gottwald (Fn. 273), Art. 23 Brüssel IIa-VO Rn. 2.

形，肯定公序之違背³⁰⁴，而在其拒絕承認反有危害未成年子女最佳利益之虞的情形，否定公序之牴觸³⁰⁵；另方面，為實現未成年子女最佳利益所不可或缺，而受兒童權利公約第12條保障之聽審請求權³⁰⁶，如未成年子女已有相當之表達能力，又無不能聽取其意見之急迫情事（如：返還誘綁子女事件、家庭暴力事件）³⁰⁷，且未予聽審機會情節重大，即得拒絕承認之³⁰⁸，惟若此事反將害及未成年子女最佳利益，則仍應加以承認³⁰⁹。

（三）承認之效果

布魯塞爾第二之一規則及海牙兒童保護公約所設承認（及執行）制度，類同於德國家事及非訟法（上述「貳、一、（三）、1.及2.」），雖未明文規定合於承認要件之外國裁判或措施究應於承認國發生如何之效力，惟多被認為亦係採取效力延伸說³¹⁰。亦即，除給

304 *Garber* (Fn. 290), Art. 23 Brüssel IIa-VO Rn. 12; *Hausmann* (Fn. 39), N. Rn. 86; 亦參見*Heiderhoff* (Fn. 276), Art. 23 Brüssel IIa-VO Rn. 6 aE, 氏並否定「救濟之對己義務」。

305 *Heiderhoff* (Fn. 276), Art. 23 Brüssel IIa-VO Rn. 7 f.; *Alegria Borrás*, Erläuternder Bericht zu dem Übereinkommen aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische Union über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen, 1998, Rn. 73.

306 *Rauscher* (Fn. 270), Art. 23 Brüssel IIa-VO Rn. 7; *Hilbig-Lugani* (Fn. 270), Art. 23 KSÜ Rn. 15.

307 BGH, FamRZ 2015, S. 1101, Rz. 35 ff., 該院並指出，在此類具急迫性之事件，其審判程序縱未為未成年子女選任程序監理人（Verfahrensbeistand），亦不當然牴觸德國之程序公序；*Garber* (Fn. 290), Art. 23 Brüssel IIa-VO Rn. 17 ff., 氏並強調，單純聽取之困難（如：未成年子女之習慣居所地位於他國）尚非不使未成年子女表示意見之正當理由。

308 *Heiderhoff* (Fn. 276), Art. 23 Brüssel IIa-VO Rn. 14 f.; *Rüdiger Ernst*, Standards für Kindesanhörungen im internationalen Familienrecht, in: Budzikiewicz u. a. (Hrsg.), Standards und Abgrenzungen im Internationalen Familienrecht, 2019, S. 9 (23).

309 *Heiderhoff* (Fn. 276), Art. 23 Brüssel IIa-VO Rn. 16; 亦參見*Hausmann* (Fn. 39), N. Rn. 96.

310 關於布魯塞爾第二之一規則，參見*Hausmann* (Fn. 39), N. Rn. 54; 關於海牙兒童保護公約，參見*Huter* (Fn. 268), Art. 23 KSÜ Rn. 5; 應附言者係：依照海牙兒童保護公約第28條之規定，經執行宣告之措施，應如同承認國所為者實施

付裁判或措施（如：命交付子女）依裁判國法所具有之執行力，（原則上）應經執行宣告始能於承認國發生外（上述「貳、二、（一）」）³¹¹，外國法院定親權裁判於該外國所得發生之效力（尤其係：形成力）³¹²，均延伸至承認國，而使裁判國法院或權責機關所指定之親權人、監護人亦於承認國取得未成年子女身上或財產上照護之權限³¹³。至於外國法院定親權裁判經承認後，如嗣後情事有所改變（如：未成年子女習慣居所地之變更）³¹⁴，不論依照布魯塞爾第二之一規則或海牙兒童保護公約，承認國法院或權責機關對於該「父母責任事件」有國際管轄權者，均得加以變更³¹⁵，以貫徹未成年子女最佳利益原則³¹⁶；此事要與禁止實質再審查原則無違（布魯塞爾二26、海牙兒保27）³¹⁷。

三、海牙兒童收養公約

海牙兒童收養公約關於締約國權責機關針對「收養未成年人事

其執行，在此限度內，學說上認為海牙兒童保護公約亦兼採同等效力說（*Krah* (Fn. 295), S. 264；亦參見LAGARDE, *supra* note 280, at para. 134）。

311 *Rauscher* (Fn. 270), Art. 21 Brüssel IIa-VO Rn. 13；關於執行宣告係以系爭裁判或措施於裁判國具有執行力為要件（之一），參見*Gottwald* (Fn. 273), Art. 28 Brüssel IIa-VO Rn. 8；*Hilbig-Lugani* (Fn. 270), Art. 26 KSÜ Rn. 4。

312 *Gottwald* (Fn. 273), Art. 21 Brüssel IIa-VO Rn. 5。

313 *Hausmann* (Fn. 39), N. Rn. 358；*Krah* (Fn. 295), S. 242。

314 應附言者係：在海牙兒童保護公約，其第14條之規定向來被視為變更外國措施之規範基礎，學說上即有據以主張，縱基礎事實並未發生改變，而僅係法律評價有所不同，上開條文所指新取得國際管轄權之權責機關亦非不得變更原措施者（*Hilbig-Lugani* (Fn. 270), Art. 27 KSÜ Rn. 5；*Huter* (Fn. 268), Art. 27 KSÜ Rn. 11；不同見解：*Andrae* (Fn. 66), § 6 Rn. 197，氏認為，如情事無何改變，外國措施之撤銷即為禁止實質再審查原則所不許）；此項寬認變更之要件的見解，在布魯塞爾第二之一規則，亦不無著眼於未成年子女最佳利益原則而加以支持者（*Rauscher* (Fn. 270), Art. 26 Brüssel IIa-VO Rn. 5 f.，氏指出，縱不採此見解，實務上亦得以重新鑑定等方式輕易符合基礎事實改變的要求；不同見解：*Gottwald* (Fn. 273), Art. 26 Brüssel IIa-VO Rn. 3）。

315 關於布魯塞爾第二之一規則，參見*Gottwald* (Fn. 273), Art. 21 Brüssel IIa-VO Rn. 20；關於海牙兒童保護公約，參見*Krah* (Fn. 295), S. 249。

316 參見*Rauscher* (Fn. 270), Art. 21 Brüssel IIa-VO Rn. 14。

317 *Borrás* (Fn. 305), Rn. 78；*Andrae* (Fn. 66), § 6 Rn. 197。

件」(海牙收養2)所為裁判之承認,係規定於第23條至第27條:第23條規定其承認程序、第24條規定拒絕承認事由,而第26條及第27條則規定其承認效果³¹⁸。上開規定,係與海牙兒童收養公約上收養媒合程序、最低限度之實質要件等保護規範及中央主管機關(Central Authority)間互助合作之相關制度,一併構成該公約轉化兒童權利公約第21條及第35條之要求³¹⁹、實現未成年子女最佳利益原則之宗旨(海牙收養前言)所不可或缺者(海牙收養1)³²⁰。

(一) 承認之程序

海牙兒童收養公約第23條第1項規定:「收養,經收養實施國之權責機關認證(certify)其合於本公約之規定者,於其他締約國之承認,依法(by operation of law)為之。依第17條第3款之規定所為之同意,其時間及同意之人,應載明於該認證」。依此,如同德國家事及非訟法(上述「貳、一、(一)、1.及3.」),海牙兒童收養公約亦明文採取自動承認制³²¹,蓋收養既經權責機關審查認定符合公約所設實體、程序之保護規範(詳後述)³²²,原則上即不生有害未成年子女最佳利益之疑慮,而得簡化其承認機制³²³;此事並不妨

318 應附言者係:依照海牙兒童收養公約第2條之規定,該公約係適用於所有涉及被收養人之習慣居所地自締約國變更至他締約國,而與收養者建立永久親子關係(permanent parent-child relationship)之收養,此不限於本文所探討外國收養中之宣告收養,亦及於純粹之契約收養,且不區分完全收養(full adoption)及單純收養(simple adoption)(參見GONZALO PARRA-ARANGUREN, EXPLANATORY REPORT ON THE 1993 HAGUE INTERCOUNTRY ADOPTION CONVENTION para. 94 (1994)),並包含繼親收養(Stiefkindadoption)與親戚收養(Verwandtenadoption)(參見Helms (Fn. 38), vor Art. 23 HAdoptÜ Rn. 5)。

319 參見Andrae (Fn. 66), § 7 Rn. 2; Gesine Lange, Die Adoption nach internationalem Recht, FPR 2001, S. 327 (328 f.).

320 參見Hausmann (Fn. 39), P. Rn. 14 f.; Nademleinsky/Neumayr (Fn. 283), Rz. 07.06.

321 Hausmann (Fn. 39), P. Rn. 29; Helms (Fn. 38), Art. 23 HAdoptÜ Rn. 1.

322 Helms (Fn. 38), Art. 23 HAdoptÜ Rn. 2.

323 Andreas Botthof, in: Rauscher (Hrsg.), Münchener Kommentar zum FamFG, Bd. 2, 3. Aufl., 2019, Art. 23 HAdoptÜ Rn. 1.

礙締約國所設承認確認程序（如：德收養效力2）之適用性³²⁴。

（二）承認之要件

海牙兒童收養公約第24條規定：「收養，經斟酌未成年子女之最佳利益，顯然違背締約國之公共秩序者，始得拒絕承認之」。準此，不同於德國家事及非訟法（上述「貳、一、（二）、1.及3.」），海牙兒童收養公約以公序為單一之拒絕承認事由，而尤不允許承認國以承認管轄權之欠缺為由否定經認證（海牙收養23）之收養於本國發生效力³²⁵，以儘可能避免跛行身分關係³²⁶；上開以未成年子女最佳利益為其特別型態之拒絕承認事由，並應為限縮之解釋³²⁷。

申言之，公序是否遭違反，其調查對象主要係外國法院有無進行（充分）「未成年子女最佳利益之審查」及被收養人或其生父母之聽審權、同意權是否受保障³²⁸；此固得自收養是否遵守海牙兒童收養公約之規定一事著手，而以其違反推認外國法院認可收養未成年人裁判之承認牴觸公序³²⁹，然應留意者係，並非所有不合該公約之規定（如：海牙收養32）所生瑕疵，均足以正當化承認之拒絕³³⁰，而仍應達顯然之程度始可（如：收養者所在國未為適合性評估、被收養人遭誘綁、收養所必要之同意係經偽造或詐欺、脅迫）³³¹。不過，由於外國裁判是否害及未成年子女最佳利益而違背

324 參見Weitzel (Fn. 76), § 2 Rn. 5; Botthof (Fn. 323), Art. 23 HAdoptÜ Rn. 5，氏指出，德國實務上多仍要求收養者進行收養效力法所定程序並取得確認裁判。

325 Hausmann (Fn. 39), P. Rn. 32; Robert Fucik, in: Gitschthaler (Hrsg.), Internationales Familienrecht, 2019, Art. 24 HAÜ Rn. 4.

326 Botthof (Fn. 323), Art. 24 HAdoptÜ Rn. 1.

327 PARRA-ARANGUREN, *supra* note 318, at para. 426; Botthof (Fn. 323), Art. 24 HAdoptÜ Rn. 2 f.

328 Hau (Fn. 4), § 109 Rn. 64.

329 Fucik (Fn. 325), Art. 24 HAÜ Rn. 2.

330 PARRA-ARANGUREN, *supra* note 318, at para. 413; Hausmann (Fn. 39), P. Rn. 32.

331 Hausmann (Fn. 39), P. Rn. 33; Fucik (Fn. 325), Art. 24 HAÜ Rn. 2；另參見Helms (Fn. 38), Art. 23 HAdoptÜ Rn. 2 aE.

公序，應視承認判定時之狀況決之，故其於裁判作成時縱不合於未成年子女最佳利益，如拒絕承認反而有損被收養人之福祉（如：本生父母無意接回已與收養者一定期間共同生活之被收養人），仍應加以承認³³²。

其實，海牙兒童收養公約第24條所定公序之保留條款，實際上並無多大之作用，蓋得依同公約第23條受承認者，係限於遵守公約之規定而經權責機關予以認證之收養，而海牙兒童收養公約所設如下之實體、程序保護規範，既係以確立保護未成年人之最佳方案為目的，自不易發生有害未成年子女最佳利益之情事³³³；其實體保護規範係海牙兒童收養公約第4條及第5條³³⁴，依照前一條文，被收養人所在國權責機關（或經許可之機構）應確認(1)被收養人適於被收養、(2)相較於其他安置方案，跨國收養更合於其最佳利益、(3)收養所必要之同意經合法表示及(4)妥適斟酌該被收養人之意見，而依照後一條文，收養者所在國權責機關（或經許可之機構）應確認(1)收養者之養父母適合性、(2)收養者已獲必要之諮詢及(3)被收養人得入境並永久居留；其程序保護規範為同公約第14條至第22條³³⁵，此等雙方權責機關彼此合作之所謂配對（*matching*）流程，其成否係取決於被收養人所在國依照同公約第17條之規定，尤其在二國中央主管機關均同意續行收養程序（海牙收養17 ③）之基礎上所作成託付（*entrust*）未成年人於養父母之配對決定³³⁶。

332 *Botthof* (Fn. 323), Art. 24 HAdoptÜ Rn. 3，氏並強調，為確認拒絕承認是否危害未成年子女最佳利益，承認國法院應為一定之事證調查；*Fucik* (Fn. 325), Art. 24 HAÜ Rn. 3.

333 *Andrae* (Fn. 66), § 7 Rn. 66; *Nademleinsky/Neumayr* (Fn. 283), Rz. 07.39.

334 參見*Nademleinsky/Neumayr* (Fn. 283), Rz. 07.12.

335 參見*Nademleinsky/Neumayr* (Fn. 283), Rz. 07.14.

336 *Busch* (Fn. 77), S. 16.

(三) 承認之效果

海牙兒童收養公約第26條規定：「收養之承認，包含下列事項之承認：一、兒童及其養父母間之親子關係。二、養父母對於兒童之父母責任。三、於實施收養之締約國有終止兒童及其父母間原有法律關係之效力者，其終止（第1項）。收養有終止原有法律關係之效力者，收養國（the receiving State）或其他承認該收養之締約國有同一效力之收養所生權利，該兒童亦有之（第2項）。承認收養之締約國更有利於該兒童之規定，不因前二項之規定而不得適用（第3項）」。³³⁷依此，不同於德國家事及非訟法（上述「貳、一、（三）、1.及3.」），海牙兒童收養公約針對合於承認要件之外國裁判所得於承認國發生之效力，一面創設最小限度之統一法，一面兼採效力延伸說、同等效力說及優惠原則³³⁷。亦即，外國法院認可收養未成年人裁判經承認者，在收養者與被收養人間，不問收養準據法之規定為何³³⁸，即成立親子關係（海牙收養26 I ①），收養者並取得對於被收養人之親權（海牙收養26 I ②）³³⁹，而在被收養人與其原父母間，其法律關係是否斷絕，則採取效力延伸說，依裁判國法即該外國法院所適用之法決之（海牙收養26 I ③）³⁴⁰。在此基礎上，外國裁判有（全部或部分³⁴¹）斷絕原法律關係之效力者，縱同種類之承認國裁判無此效力，仍得延伸至該國³⁴²，而如同種類之承認國裁判亦有此效力，則本於兒童權利公約第21條第3款之要求³⁴³，酌採同等效力說，以承認國之實質法替代之，使收養之效力於承認國歸

337 參見Andrae (Fn. 66), § 7 Rn. 67; Nademleinsky/Neumayr (Fn. 283), Rz. 07.44 f.

338 PARRA-ARANGUREN, *supra* note 318, at para. 439; Hausmann (Fn. 39), P. Rn. 38.

339 Botthof (Fn. 323), Art. 26 HAdoptÜ Rn. 3 f.; Fucik (Fn. 325), Art. 26 HAÜ Rn. 3.

340 Hausmann (Fn. 39), P. Rn. 39.

341 PARRA-ARANGUREN, *supra* note 318, at paras. 449, 468; Hausmann (Fn. 39), P. Rn. 41；關於完全收養之子型態，參見Dimmler (Fn. 46), § 108 Rn. 32 f.

342 PARRA-ARANGUREN, *supra* note 318, at para. 452; Fucik (Fn. 325), Art. 26 HAÜ Rn. 4.

343 PARRA-ARANGUREN, *supra* note 318, at para. 465; Botthof (Fn. 323), Art. 26 HAdoptÜ Rn. 6.

於一致（海牙收養26 II）³⁴⁴；外國裁判無斷絕原法律關係之效力者，如同種類之承認國裁判的個別效力（如：繼承權）有利於被收養人，亦不妨依優惠原則加以擴張（海牙收養26 III）³⁴⁵。

前揭優惠原則，並無強化收養效力，而將單純收養轉換為完全收養之作用³⁴⁶；此毋寧係德國收養效力法所仿效之海牙兒童收養公約第27條規定的任務，該條謂：「於出養國（the State of origin）實施之收養無終止原有親子關係之效力者，如收養國依本公約之規定承認該收養，而具備下列各款要件，得將其轉換為有該類效力之收養：一、收養國之法律許可者。二、該類收養依第4條第3款及第4款之規定經同意者（第1項）。第23條之規定，於轉換決定（decision converting the adoption）亦適用之（第2項）」。³⁴⁷因此，在外國法院認可收養未成年人裁判，依其所適用之法並無斷絕被收養人與其原父母間法律關係之效力的情形，如欲變更收養準據法為具上開效力之承認國法，而使被收養人取得依承認國法所收養者之法律地位³⁴⁷，收養者尚無庸於承認國為重複收養，而得循承認國所設效力強化程序（如：德收養效力3），以相關人等（如：原父母、被收養人）事前或事後表示同意原有法律關係之斷絕為前提³⁴⁸，依承認國之轉換決定為之³⁴⁹；該轉換決定經承認國權責機關認證者，其他締約國亦應承認之³⁵⁰。

³⁴⁴ Hausmann (Fn. 39), P. Rn. 40; Busch (Fn. 77), S. 16; 亦參見Botthof (Fn. 323), Art. 26 HAdoptÜ Rn. 6.

³⁴⁵ PARRA-ARANGUREN, *supra* note 318, at para. 471; Hausmann (Fn. 39), P. Rn. 43.

³⁴⁶ Botthof (Fn. 323), Art. 26 HAdoptÜ Rn. 7; Fucik (Fn. 325), Art. 26 HAÜ Rn. 6.

³⁴⁷ Botthof (Fn. 323), Art. 27 HAdoptÜ Rn. 1.

³⁴⁸ PARRA-ARANGUREN, *supra* note 318, at paras. 482-483; 亦參見Botthof (Fn. 323), Art. 27 HAdoptÜ Rn. 5.

³⁴⁹ Hausmann (Fn. 39), P. Rn. 44.

³⁵⁰ PARRA-ARANGUREN, *supra* note 318, para. 484; Helms (Fn. 38), Art. 27 HAdoptÜ Rn. 7.

參、我國法之規範與解釋

如上(「壹、一」)所述，外國法院之裁判，自我國法之觀點得予以定性為家事非訟裁判者，應依家事法第97條準用非訟法第49條之規定(及家事法第186條第2項準用強執法第4條之1之規定)承認(及執行)之，而上開規範之解釋適用，不論在承認程序、承認要件或承認效果等面向上，均不無疑義。關於該等疑問，至少在涉及「未成年子女親權事件」及「認可收養未成年人事件」之限度內，上述(「貳」)德國家事及非訟法、收養效力法、布魯塞爾第二之一規則、海牙兒童保護公約及海牙兒童收養公約所提示之解決方案，頗值參考。此等比較法上規範狀態之認知，亦能用以凸顯我國實務處理相關議題之進步空間(上述「壹、二」)：於【事例一】，系爭美國法院指定X為A2之單獨親權人之裁判，其所為親權歸屬之規制，既不具給付性，為何亦成為許可執行程序之審判對象？美國法院對於系爭「未成年子女親權事件」有無承認管轄權之認定，為何係依家事法第52條第1項為之？系爭美國法院未聽取A2之意見且未表明其處置合於未成年子女最佳利益之依據，為何不牴觸我國之公序良俗？系爭美國法院裁判並未命Y交付A2予X，為何我國法院得逕行肯定其執行力？又於【事例二】，系爭日本法院准許Y及B收養A之裁判，應否為程序法上承認？如是，能否僅以系爭日本法院裁判不合於我國民法第1073條之1或第1076條之1之規定，即當然認其違背我國之公序良俗？

以下即針對外國法院定親權、認可收養未成年人裁判於我國之承認(及執行)，一面參照前揭德國、歐盟及國際法之研究結果，一面本於兒童權利公約所揭示之未成年子女最佳利益原則，提示運用相關規定之基本方針。

一、承認之程序

（一）自動承認制與許可執执行程序

我國非訟法第49條對於外國法院非訟裁判無疑係採取自動承認制³⁵¹，蓋不論依照本條所參考、繼受之我國民訴法第402條或德國（舊）非訟法第16條之1的解釋論，外國法院裁判於我國發生效力一事，均無庸先經我國法院（或其他公權機關）行承認程序賦予之³⁵²；此並合致於非訟法第49條之立法者所表示促進外國法院裁判流通性之政策目標³⁵³。在外國法院裁判之標的依我國法應定性為家事非訟事件的情形，依照家事法第97條之規定，其承認係準用非訟法第49條之規定，而如符合同條所設承認要件，亦自動於我國發生效力。

相對於此，外國法院非訟裁判具給付性而有予以執行之必要者，雖亦應如同外國法院民事訴訟裁判，經我國法院之執行宣告以取得執行力³⁵⁴，惟其許可執执行程序得否附隨於非訟法第47條之執行事件³⁵⁵，或必須類推適用強執法第4條之1之規定獨立行之³⁵⁶，則未必明確；不過，在外國法院裁判之標的依我國法應定性為家事非訟事件的情形，依照家事法第186條第2項之規定，其執行既準用強執法，即應依強執法第4條之1之規定進行獨立之許可執执行程序³⁵⁷。此一「外國法院家事非訟裁判許可執行事件」，應鑑於其審理（尤

351 前揭註13。

352 關於我國民訴法第402條採取之自動承認制，參見最高法院105年度台上字第232號民事判決；陳啓垂（註12），頁230；關於德國（舊）非訟法第16條之1採取之自動承認制，參見前揭註42；Walter Zimmermann, in: Keidel/Kuntze/Winkler (Hrsg.), *Freiwillige Gerichtsbarkeit*, 15. Aufl., 2003, § 16a Rn. 9.

353 前揭註30。

354 參照Roth (Fn. 116), S. 76; Zimmermann (Fn. 352), § 16a Rn. 12; Hau (Fn. 4), § 110 Rn. 14.

355 參照BGH, NJW 1983, S. 2776 (2776)；臺灣高雄地方法院100年度訴字第1001號民事判決。

356 參見沈冠伶（註7），頁335。

357 參見許士宦（註2），頁46-47。

其係：是否違背我國之公序良俗）多牽涉家事專業，而納為家事法第3條第6項所稱之其他家事事件³⁵⁸，且似亦應著眼於職權裁量（如：依職權核發暫時處分）或程序保障（如：聽取未成年子女意見）之需求，進一步將之定性為同法第74條所謂其他家事非訟事件，而行家事非訟程序³⁵⁹；此對於外國法院定親權裁判之執行，尤具意義，蓋如同海牙兒童保護公約第26條第2項所明文揭示者般（上述「貳、二、（一）」），如交付子女或容忍會面交往之命令不能透過簡單且迅速之途徑儘早實現，親權或會面交往方式及期間之酌定亦會隨時間之經過而徒留形式³⁶⁰。

（二）承認確認程序

承上（「參、一、（一）」）所述，承認外國法院家事非訟裁判所採行之自動承認制，理論上固能節省關係人之勞力、時間、費用，然於外國法院裁判之標的構成我國法院（或其他公權機關）所受理事件之（實體法或程序法上）先決問題時，該法院（或公權機關）既仍須判斷承認要件是否該當³⁶¹，而其認定結果原則上並無拘束他機關或關係人之效力，則不僅容易造成重複審理之程序不經濟（如：外國法院酌定父母之一方為單獨親權人裁判之承認要件該當性，分別於我國法院受理之交付子女事件及我國戶政機關受理之未成年子女權利義務行使負擔登記事件受審查），亦可能因矛盾裁判而危害法安定性（如：外國法院認可收養未成年人裁判之承認要件該當性，分別於我國法院受理之遺產分割事件及我國內政部所受理

358 許士宦，許可外國民事及家事裁判執行之訴（下），月旦法學教室，208期，頁47-48（2020年）（以下簡稱：許士宦，許可之訴）；許士宦，家事事務法，頁29（2020年）（以下簡稱：許士宦，家事法）。

359 相同見解：沈冠伶（註7），頁336；亦參見Roth (Fn. 116), S. 78；不同見解：許士宦（註2），頁50-51；關於將許可執行程序定性為家事訴訟事件所生受訴法院得否核發暫時處分之爭議，參見最高法院105年度台簡抗字第7號民事裁定。

360 參見Krah (Fn. 295), S. 242.

361 參照劉鐵錚、陳榮傳（註10），頁650。

之歸化事件遭歧異判定)，實際上未必全然妥適³⁶²；此等伴隨於自動承認制所生之不利益，尤難謂切合於未成年子女最佳利益原則³⁶³。

因此，前揭比較法上明文允許利害關係人請求承認國法院確認外國裁判是否具備承認要件之折衷方案（上述「貳、一、（一）」、「貳、二、（一）」及「貳、三、（一）」），實值我國法借鏡。亦即，除在立法論上宜增訂任意、獨立之承認確認程序外，在解釋論上亦應肯定「外國法院家事非訟裁判承認確認事件」為家事法第3條第6項所稱其他家事事件³⁶⁴。至少在確認標的係外國法院定親權、認可收養未成年人裁判的限度內，由於其審判係以謀求未成年子女最佳利益為指標（詳後述），而與其他涉及未成年子女之非訟事件同樣需求法院之職權裁量並重視程序之簡易迅速³⁶⁵，故上開「外國法院家事非訟裁判承認確認事件」更應定性為家事法第74條所謂其他家事非訟事件，而行家事非訟程序³⁶⁶，並配合非訟法所採取之關係人概念（家事97、非訟10），擴張其確認裁判之既判力及於所有利害關係人³⁶⁷，以在我國法秩序內確保親權歸屬狀態或養親子關係之一致性³⁶⁸。若然，則利害關係人（尤其係：因承認之結果親權或親子關係受影響之人）得類推適用民訴法第247條第1項之規定³⁶⁹，聲請

362 參見Schack, FS Spellenberg (Fn. 51), S. 501; Schack, IZVR⁷ (Fn. 51), Rn. 971; 類似見解：劉鐵錚、陳榮傳（註10），頁653註9。

363 參照Heiderhoff, Standards und Abgrenzungen (Fn. 27), S. 67, 72.

364 同旨：許士宦，家事法（註358），頁29；關於德國（舊）非訟法第16條之1亦允許獨立之承認確認程序，參見Zimmermann (Fn. 352), § 16a Rn. 9.

365 參照Huter (Fn. 268), Art. 24 KSÜ Rn. 17 aE.

366 不同見解：許士宦，許可之訴（註358），頁50，氏認為應允許當事人提起承認或不承認外國裁判之確認訴訟。

367 關於非訟法上確認裁判之既判力，參見Krah (Fn. 295), S. 260；關於非訟法上關係人概念與既判力主觀範圍之連結，參見Thomas Klicka/Paul Oberhammer/Tanja Domej, Außerstreitverfahren, 5. Aufl., 2014, Rn. 163.

368 關於確認外國法院裁判承認或不承認裁判之對世效的關鍵意義，參見Schack, FS Spellenberg (Fn. 51), S. 499, 503.

369 參照Werner Sternal, in: Keidel/Engelhardt/Sternal (Hrsg.), FamFG, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 20. Aufl., 2020, § 23 Rn. 37; BGH, NJW 1982, S. 387 (388).

我國（家事）法院（庭）以裁定確認外國法院定親權、認可收養未成年人裁判之承認或不承認，其（積極或消極）確認裁判並得生拘束全體（含：法院及行政機關）之對世效；至於在外國法院家事非訟裁判之承認與否構成我國法院所受理事件之先決問題的情形，得以追加中間確認事件之方式為之（家事79），自不待言。

二、承認之要件

（一）承認標的適格

我國非訟法第49條之規定係立足於國際民事程序法之優先性，對於外國法院非訟裁判採取徹底之程序法上承認。亦即，在促進國際合作之憲法精神下（憲141）³⁷⁰，外國法院非訟裁判是否於我國發生效力，端視非訟法第49條所列拒絕承認事由之有無，而不問我國涉民法之內容及其所指定原因關係準據法之立場，以給予外國司法適當之信賴並儘量避免跛行法律關係³⁷¹；此觀本條繼受母法（即：德舊非訟16-1、德民訴328）之沿革益明³⁷²。外國法院家事非訟裁判之承認既準用非訟法第49條之規定（家事97），自應為同一解釋；此於外國法院所為之收養宣告，要無不同³⁷³。前揭肯定國際民事程序法之優先性的理由，亦應邏輯一貫地指向非訟法第49條所

370 參照Christoph Ohler, in: Merten/Papier (Hrsg.), Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, Bd. VI/2, 2009, § 184 Rn. 33.

371 參照小林秀之、村上正子，國際民事訴訟法，頁184（2009年）；不同見解：李後政（註12），頁306-307。

372 前揭註63。

373 參照西谷祐子（註7），頁751-752，氏並批判日本戶政實務向來所採取之所謂準據法方法（即：實體法上承認），而指出，對於外國法院認可收養未成年人裁判不採所謂承認方法（即：程序法上承認）一事，容易導致外國（宣告）收養於本國不生效力，而多所危害養子女之利益；不同見解：陳榮傳，涉外與涉陸收養準據法之研究，臺北大學法學論叢，66期，頁161（2008年）；最高法院103年度台簡抗字第182號民事裁定（【事例二】）；最高法院108年度台上字第1668號民事判決：「……無論收養者或被收養者之本國法規定應經法院認可者，均應遵其規定辦理，否則該收養即難認已成立……」。

稱「外國法院……裁判」之擴張解釋³⁷⁴：所謂法院，亦兼指其他功能上得與我國法院同視之公權機關³⁷⁵，而所謂裁判，則得包含經法院（或其他公權機關）實質審查而賦予效力之法律行為³⁷⁶。依此，就「未成年子女親權事件」及「認可收養未成年人事件」而言，父母間於外國調解或法院程序上所達成親權歸屬之協議，經外國法院實質審查後予以核可者、收養者與被收養人間之收養契約，經外國法院實質審查而得事前許可或事後同意者，均具承認標的適格³⁷⁷；反之，父母間程序外之親權歸屬協議、收養者與被收養人間未受法院審認有效性之「收養契約」，縱經法院或其他機關辦理登記或核發證書，仍非程序法上承認之對象，而應依其準據法（涉民54 I、55）為「實體法上承認」。

至於非訟法第49條另要求外國法院裁判已經確定一事，則鑑於非訟裁判常有即時生效以儘快發生保護照顧作用之需求，在立法論上難謂妥當³⁷⁸。因此，在解釋論上除不應據以排除欠缺本案終局性之暫時處分外³⁷⁹，亦應視事件類型對於上開規定進行目的性限縮，而以外國法院非訟裁判依該外國法已經生效為已足³⁸⁰；如同比較法之規範狀態所示（上述「貳、一、（二）、2.」及「貳、二、（二）」），外國法院定親權裁判即其適例。

374 參照Wagner (Fn. 7), S. 1624; Nademleinsky/Neumayr (Fn. 283), Rz. 01.73.

375 參照內野宗揮，一問一答 平成30年人事訴訟法・家事事件手続法等改正——國際裁判管轄法制的整備，頁164（2019年）。

376 參照Rauscher (Fn. 43), § 108 Rn. 13 f.

377 關於家事非訟事件之程序上和解及調解的承認標的適格，參見許士宦（註2），頁56、59。

378 參照ErläutRV, 296 BlgNR XXI GP, S. 95; Alexander R. Markus, Internationales Zivilprozessrecht, 2014, Rn. 1373.

379 參見2003年民訴法第402條修正理由五：「外國法院所為之確定裁定，例如命扶養或監護子女等有關身分關係之保全處分……亦有承認其效力之必要……」。

380 關於外國法院裁判生效與否應依該外國法決之，參見最高法院109年度台上字第1094號民事判決。

(二) 拒絕承認事由：未成年子女最佳利益原則之具體實踐

我國非訟法第49條所列四款拒絕承認事由，應有其窮盡列舉之性質，且因承認之拒絕係立法者所表明承認原則之例外，而應為限縮之解釋³⁸¹；又由於非訟程序之構造、標的及目的均與（民事）訴訟程序不盡相同，故非訟法第49條雖係參考民訴法第402條第1項而來，惟非訟法上拒絕承認事由之設計及運用尚不能原樣移用民訴法所定者，而必須兼顧非訟事件有別於訴訟事件之特性³⁸²。準此，非訟法不僅禁止對於外國法院裁判從事所謂衝突法上控制，而不問外國法院所適用之法律是否為我國法律衝突規範所指定者，縱我國與裁判國間並未相互承認，亦不得逕行拒絕承認其裁判（非訟49 ④但）；此等略同於非訟法第49條之繼受母法（上述「貳、一、（二）、1.」），而有助於外國法院裁判流通性之規範與解釋，正切合於非訟裁判因著重變動法律關係之形成力所生避免跛行法律關係的高度需求³⁸³。以上基本原則，在依家事法第97條準用非訟法第49條之情形，初無不同。

然而，如外國法院家事非訟裁判係針對「未成年子女親權事件」或「認可收養未成年人事件」等（未滿18歲）未成年子女相關事件所為者，則我國法院（或其他公權機關）對於其有無承認適格性之判定，亦屬兒童權利公約第3條第1項所稱兒童相關事務（actions concerning children）³⁸⁴，而必須遵守該條項揭示之未成年子女最佳利益原則；並且，鑑於此類裁判之承認與否影響未成年子

381 前揭註30；應附言者係：外國法院無審判權者，我國無疑不應承認其所為（非訟）裁判之效力，而應類推適用非訟法第49條第1款之規定拒絕承認之（參照Hau (Fn. 4), § 109 Rn. 30）。

382 參照內野宗揮（註375），頁159；村上正子，外國裁判の承認・執行，論究ジュリスト，27号，頁48（2018年）。

383 參照山本和彥（註25），頁68-69；關於形成力作為承認之效果之一，參見下述「參、三、（一）」。

384 參照聯合國兒童權利委員會第14號一般性意見段碼17、19、21。

女於我國之法律地位（如：是否與收養者發生養親子關係）或家庭生活狀態（如：如何與未任親權人之父母會面交往）的重大性，非經審慎考量未成年子女最佳利益，尚不得逕行承認或拒絕承認之³⁸⁵。因此，在未成年子女最佳利益原則之適用範圍內，非訟法第49條所列拒絕承認事由之構成，應依循合公約解釋（含：法之續造）原則予以修正、調整，以貫徹兒童權利公約之要求³⁸⁶；海牙兒童保護公約明文賦予承認國不拒絕承認之裁量權、海牙兒童收養公約以公序為單一之拒絕承認事由等事（上述「貳、二、（二）」及「貳、三、（二）」），即同此旨。果爾，則著眼於未成年子女最佳利益原則所具實體權利、解釋原則與程序規則之三重意義³⁸⁷，應認為該原則一方面有其拒絕承認機能，如承認外國法院家事非訟裁判並非最能貫徹兒童福祉之選項，或甚礙於他人權益、公益，即應拒絕之，另方面能發揮阻卻拒絕承認機能，如承認外國法院家事非訟裁判與兒童福祉更為契合，且不甚礙於他人權益、公益者，即應否定拒絕承認事由之該當性，而不得加以拒絕³⁸⁸。

申言之，於承認適格判定程序（含：承認適格性作為主要問題及先決問題受審查者），我國法院不應沿襲向來逐一調查承認管轄權、程序開始之通知、公序良俗及相互承認等拒絕承認事由之處理模式，而應改採如下之二階段審查：先對於外國法院家事非訟裁判

385 參照聯合國兒童權利委員會第14號一般性意見段碼20：「……影響兒童（們）越為重大之決定，宜為更高度之保護及行更詳盡之程序以考慮其最佳利益……」（非官方中譯）。

386 關於以謀求內國法化之國際人權公約與其他內國法間法秩序之一致性為基礎所應肯定之合公約解釋原則，參見陳瑋佑，適時審判請求權於民事程序上之侵害與救濟——試論民事法院遲延審判之國家賠償責任，中研院法學期刊，22期，頁148（2018年）；關於以合公約解釋原則貫徹兒童權利公約要求之例證，參見陳瑋佑（註29），頁268、271。

387 關於未成年子女最佳利益原則之意義、內容及其於個案之運用方針，參見前揭註26。

388 另參照Hau (Fn. 4), § 109 Rn. 49, 氏指出，如外國裁判之拒絕承認有侵害人權之虞，維護本國法秩序基本原則之要求即應退讓。

之內容及審判程序進行回顧性之審查，檢視其是否合於未成年子女最佳利益（下述「參、二、（二）、1.」），再斟酌嗣後發生之情事，依照未成年子女最佳利益原則從事展望性之審查，控制前一審查之結果（下述「參、二、（二）、2.」）。以下即以「未成年子女親權事件」及「認可收養未成年人事件」為例，分別說明之：

1. 未成年子女最佳利益之檢視

為認定外國法院定親權、認可收養未成年人裁判之承認或不承認，何者合於未成年子女最佳利益原則，首先應鑑於該原則所反映之實體權利及程序規則面向，回顧系爭裁判之內容及審判程序是否無違未成年子女最佳利益：就前者（即：實體權利面向）而言，應審視外國法院裁判之內容是否與兒童權利公約針對父母與子女之分離、聯繫及共同教養責任（兒權9、10、18）或家庭外照護及（跨國）收養（兒權20、21）所提示之原則相一致，而就後者（即：程序規則面向）而言，則應檢查外國法院之審判程序是否確保兒童權利公約所強調未成年子女之參與權即聽審請求權（兒權12）；此時，我國法院（或其他公權機關）可謂係在公序良俗之拒絕承認事由（家事97、非訟49 ③）的範疇內為審查³⁸⁹，而應注意禁止實質再審查原則³⁹⁰，尚不得徒憑其裁判內容與我國法院依我國民法或兒少保護相關規定（如：民1055-1、1089-1、1090、1079-1、兒福16、71、家暴43）所可能採取之處置有所不同，或其審判程序未循我國家事法所設定之方式進行（如：家事106、108、109、119），

389 關於未成年子女最佳利益所具之憲法價值，參見司法院釋字第365號解釋理由：「……父母對於未成年子女權利之行使意思不一致時……應基於兩性平等原則及兼顧未成年子女之最佳利益，規定其解決途徑……」；司法院釋字第587號解釋理由：「……民法規範父母子女間之法律關係，向以追求與維護子女之最佳利益為考量（民法第一千零五十五條至第一千零五十五條之二、第一千零八十九條第二項、第一千零九十四條第二項規定參照），以實現憲法保障子女人格權益之價值……」。

390 參見許士宦（註2），頁52。

遽謂其違背未成年子女最佳利益而牴觸我國公序良俗³⁹¹。

毋寧是，如外國法院係在未成年子女適當、充分參與的基礎上，蒐集包含未成年子女意願在內之相關因素，而可認為該外國法院已有考量未成年子女之最佳利益，即能（暫時）推認其裁判之承認有助於未成年子女最佳利益，反之，如不能認為外國法院裁判係經斟酌未成年子女最佳利益所為者，則得（暫時）推認其承認有害於未成年子女最佳利益；此種以「未成年子女最佳利益之審查」具體化承認法上公序良俗之見解，亦為德國實務、學說見解所採（上述「貳、一、（二）、2.及3.」）。在此意義上，承認管轄權之拒絕承認事由（家事97、非訟49 ①）可謂涵蓋於公序良俗之內，而無庸獨立加以審查，蓋我國家事法針對「未成年子女親權事件」及「認可收養未成年人事件」所設國際管轄原因（如：家事104 I、114 I）及國際管轄裁量權（如：家事5、非訟3但）³⁹²，其規範目的無非係確保各該事件由最便利審理認定未成年子女最佳利益之法院受理³⁹³，而外國法院所完成之「未成年子女最佳利益之審查」，既指向其裁判與未成年子女最佳利益之一致性，自不能更認為該外國法院係不適於審判管轄者³⁹⁴；至於其他關係人對於我國國際家事管轄規範所可能抱持之信賴，則得在後一階段之審查謀求其保護（詳後述）。

進言之，不論係外國法院定親權或認可收養未成年人裁判，我國法院均應以兒童權利公約第12條（及第9條第2項、第21條第1

391 參照Heiderhoff, FS Geimer (Fn. 27), S. 237.

392 關於我國家事法及其所準用之非訟法上土地管轄規定之二重機能性，參見陳瑋佑（註29），頁244-247。

393 參見陳瑋佑（註29），頁247-248、262-263。

394 類似見解：西谷祐子（註7），頁754；另參照唐敏寶，承認外國離婚與未成年子女監護裁判之間接國際管轄權——兼評最高法院93年度台上字第1943號民事判決，法令月刊，61卷7期，頁72-73（2010年）。

款)之規定為基準³⁹⁵，審查於外國法院所行程序，未成年子女是否被賦予陳述機會及其意願是否受斟酌³⁹⁶，如否，則應進一步探知此事是否礙於其表達能力之限制(如：初生之嬰兒)³⁹⁷，或有無不適合聽取其意見之急迫情事(如：誘綁子女之返還)³⁹⁸，而有其正當性；至於法院對於未成年子女意見之聽取，係親自或以書狀、調查機構之報告等方式為之，則非所問³⁹⁹。此外，對於外國法院定親權裁判，我國法院應審查外國法院是否係以兒童權利公約第9條第1項、第3項及第18條第1項所強調之未成年子女最佳利益為酌定、停止親權、會面交往方式及期間或交付子女之指標⁴⁰⁰，而對於外國法院認可收養未成年人裁判，我國法院則應審查外國法院是否充分顧慮同公約第20條、第21條第2款所表明家庭外照護、跨國收養之補充性⁴⁰¹、是否實施同公約第21條第1款所要求之收出養評估⁴⁰²，以及是否以未成年子女最佳利益為準予收養之最大考量(the paramount consideration)⁴⁰³；外國法院裁判是否提及類如我國民法

395 關於兒童權利公約第12條規定於「未成年子女親權事件」及「認可收養未成年人事件」之適用，參見聯合國兒童權利委員會第12號一般性意見(CRC, General Comment No. 12, CRC/C/GC/12)段碼32；關於兒童權利公約第9條第2項保障未成年子女於「未成年子女親權事件」之聽審機會，參見Schmahl (Fn. 26), Art. 9 Rn. 8；關於兒童權利公約第21條第1款保障被收養人於「認可收養未成年人事件」之聽審機會，參見Schmahl, ebd. Art. 20/21 Rn. 18 aE.

396 參見許士宦，許可之訴(註358)，頁42；關於兒童權利公約第12條所保障聽審請求權之面向，參見聯合國兒童權利委員會第12號一般性意見段碼22、25、28。

397 關於兒童權利公約第12條寬認「形成自己意見能力」之立場，參見聯合國兒童權利委員會第12號一般性意見段碼20-21。

398 參照前揭註307。

399 參照前揭註167。

400 關於兒童權利公約第9條第1項、第3項所謂未成年子女最佳利益之判斷標準，參見JAAP DOEK, A COMMENTARY ON THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD, ARTICLES 8-9: THE RIGHT TO PRESERVATION OF IDENTITY AND THE RIGHT NOT TO BE SEPARATED FROM HIS OR HER PARENTS 25-26, 29-30 (2006).

401 參見Schmahl (Fn. 26), Art. 20/21 Rn. 6, 17 aE.

402 參見SYLVAIN VITÉ & HERVÉ BOÉCHAT, A COMMENTARY ON THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD, ARTICLE 21: ADOPTION 34-35 (2008).

403 關於兒童權利公約第21條所謂「最大考量」之意義，參見VITÉ & BOÉCHAT,

第1055條之1所列事項⁴⁰⁴，又是否符合海牙兒童收養公約所設實體、程序保護規範（上述「貳、三、（二）」）⁴⁰⁵，亦得成為判斷其是否妥適考量未成年子女最佳利益之輔助依據。

2. 未成年子女最佳利益原則之控制

未成年子女最佳利益原則作為判斷應否承認外國法院定親權、認可收養未成年人裁判之標準，其內涵並不止於外國法院有無從事一定「未成年子女最佳利益之審查」之回顧，而及於其裁判內容今後是否切合未成年子女最佳利益之展望⁴⁰⁶。亦即，縱使外國法院所為親權歸屬之規制或創設之養親子關係，於裁判作成時因未經（充分）「未成年子女最佳利益之審查」而不能認為有助於未成年子女最佳利益，如於承認判定時斟酌嗣後發生之情事，而可認為維持該親權歸屬狀態或養親子關係更能促進該兒童之福祉，仍不能斷言其違背未成年子女最佳利益而牴觸我國公序良俗，否則，該未成年子女將因外國法院定親權、認可收養未成年人裁判不能於我國發生效力而陷於跛行身分關係並蒙受重啟程序之不利益，反損害其福祉⁴⁰⁷；此項見解，亦與以承認判定時作為判斷是否違反公序良俗之基準時點的見解相通⁴⁰⁸。若然，則我國法院為確認外國法院裁判之承認是否較能實現未成年子女最佳利益，即必須以該裁判作成後所發生之情事為基礎，循家事非訟程序進行自己的「未成年子女最佳利益之審查」⁴⁰⁹；此時，由於我國法院應賦予未成年子女陳述機會（家事

supra note 402, at 25-26.

404 參照1996年民法第1055條之1增訂理由：「……何謂子女之最佳利益……宜明定具體客觀事由作為審酌之參考，爰增訂本條提示性規定」。

405 參照Schmahl (Fn. 26), Art. 20/21 Rn. 25：「……海牙兒童收養公約可謂補充兒童權利公約第21條之不足……」。

406 同旨：沈冠伶（註7），頁339；關於判斷是否符合未成年子女最佳利益之基準時點，參見Schmahl (Fn. 26), Art. 3 Rn. 11.

407 參照Heiderhoff, Standards und Abgrenzungen (Fn. 27), S. 69 f.

408 許士宦，許可之訴（註358），頁41；亦參照前揭註128。

409 參照前揭註175、213-215。

108、119)，且多有必要訪視或調查其家庭狀況並聽取其他關係人（如：親權人、養父母）之意見（家事106、119）⁴¹⁰，故在審認結果指向於承認外國法院定親權、認可收養未成年人裁判的情形（如：未成年子女明確同意親權或會面交往之安排、被收養人與收養者已建立穩固之親子關係），亦可視原先外國裁判內容或審判程序之瑕疵（如：未給予未成年子女表示意見之機會、未實施收出養評估）已經補正，而不復構成反對承認之理由。至於在前一階段之審查已遭認定為有害未成年子女最佳利益，其瑕疵又不能於承認適格判定程序被補正者，自屬違背我國公序良俗而不應予以承認，尚不待言。

然而，外國法院根據一定「未成年子女最佳利益之審查」而作成裁判，或其裁判經我國法院補行「未成年子女最佳利益之審查」而確認為合於兒童福祉等事，並不意味該外國法院裁判即當然具有承認適格性，蓋兒童權利公約第3條第1項雖表示未成年子女最佳利益係法院審判所應優先考量（a primary consideration）者，惟未賦予其絕對優先於他人權益或公益之價值，而可能存在兒童福祉必須退讓於其他更值得保護之法益的情況⁴¹¹。因此，如承認外國法院定親權、認可收養未成年人裁判將損害他人權益（如：父母一方之親權或會面交往權、本生父母之出養同意權、關係人之程序參與權）或公益（如：收養者與被收養人應有一定年齡差距或不得具一定親屬關係以維護傳統倫理觀念、要求收養應經受許可之中介機構媒合以預防誘綁子女或人口販賣），我國法院即應權衡該等法益侵害與不承認該外國法院裁判而回歸未經法院介入之狀況所得對未成年子女產生之不利益（如：身分地位之不安定、重啟程序之勞頓）間之輕重，而為如下之利益衡量：就利益衡量之基準而言，應鑑於未成

410 關於家事法為謀求未成年子女最佳利益所設之特別規定，參見李太正（註23），頁122-127。

411 參見Schmahl (Fn. 26), Art. 3 Rn. 7; FREEMAN, *supra* note 26, at 60-61.

年子女最佳利益原則所反映之解釋原則面向，以及前述限縮解釋非訟法所列拒絕承認事由之立法意旨，僅在前一他人權益或公益之損害遠大於後一未成年子女之不利益的情形，始例外否定承認要件之該當性；就利益衡量之考量因素而言，除應斟酌替代保護未成年子女利益方案之可行性（如：能否於我國重行收養）、其他關係人權利之保護必要性（如：是否以保障未任親權人之會面交往權為已足、有無不必經本生父母同意出養之正當事由）或其對於損害發生之可歸責性（如：是否故意隱匿行蹤致外國法院無從通知、得否循裁判國之救濟程序排除程序瑕疵）外，外國法院裁判所涉事案與我國之牽連性即所謂內國關連性（如：未成年子女是否住居於我國、關係人是否具備我國國籍），其程度高低更可影響我國公益受害大小之評價⁴¹²。在此限度內，程序開始之通知之拒絕承認事由（家事97、非訟49 ②）亦如同前述承認管轄權，被納入公序良俗之審查範疇內，而不再有其獨自之意義；比較法上被明定為拒絕承認事由之裁判（或程序）之衝突（上述「貳、一、（二）、1.」及「貳、二、（二）」），亦無不同。

要之，家事法第97條、非訟法第49條所列之拒絕承認事由，應依未成年子女最佳利益原則予以重構：如於承認判定時，外國法院定親權、認可收養未成年人裁判之承認有助於未成年子女最佳利益，且通過與相衝突之法益之利益衡量，即肯定該裁判之承認適格性，縱外國法院欠缺承認管轄權、審判程序未給予關係人充分之聽審機會或裁判內容偏離於我國實體法規範者，亦然；反之，如於承認判定時，外國法院裁判之承認有害於未成年子女最佳利益，或利益衡量之結果係指向其他（個人、國家）法益之優先保護，則應以該裁判違背我國公序良俗為由，拒絕承認之。

412 參照前揭註130；Kropholler (Fn. 63), S. 622；中西康、北澤安紀、橫溝大、林貴美，國際私法，頁191（2014年）。

三、承認之效果

(一) 效力延伸說

我國非訟法第49條雖未明文規定合於承認要件之外國法院裁判究應於承認國發生如何之效力，惟參酌本條所繼受之德國（舊）非訟法第16條之1的解釋論⁴¹³，亦應認為其原則上採取效力延伸說，而非同等效力說，以貫徹非訟法第49條之立法者促進外國法院裁判流通性及避免關係人遭受法律效果上突襲之基本態度⁴¹⁴；此尚不應因上開條文所參考之我國民訴法第402條之（原）立法理由使用（易滋疑義）之「有同一效力」等字而異⁴¹⁵。上開見解，於準用非訟法第49條之外國法院家事非訟裁判（家事97），亦通用之⁴¹⁶。準此，外國法院家事非訟裁判於該外國所得發生之效力，自我國法之觀點可定性為程序法效力者，原則上均依其程序法及實體準據法（即：該外國法院所適用之法）所定內容及範圍而延伸至我國。

其中，就外國法院定親權、認可收養未成年人裁判而言，最為重要者當屬發生、變動或消滅身分關係之形成力⁴¹⁷；外國法院指定由父母之一方照護子女之裁判並無停止他方重大事項之共同決定權者，於我國即不生如同我國法院依我國法酌定單獨親權人之效力⁴¹⁸，

413 關於德國（舊）非訟法第16條之1採取之效力延伸說，參見前揭註223；Zimmermann (Fn. 352), § 16a Rn. 3.

414 前揭註30；另參照山本和彥（註25），頁69；海老沢美広，非訟事件裁判の承認，收於：澤木敬郎、畑場準一編，國際私法の争点，新版，頁247（1996年）。

415 關於我國民訴法第402條是否及如何採取效力延伸說之探討，參見賴淳良，外國判決效力之承認及其效力之準據法——最高法院104年度台上字第1998號判決評釋，收於：賴淳良編，國際私法裁判選析，2版，頁113-114（2018年）；陳啓垂（註12），頁220-223；蔡華凱（註2），頁28。

416 參照村上正子（註382），頁48。

417 關於我國法觀點下家事非訟裁判之形成力，參見許士宦，家事法（註358），頁666。

418 參照前揭註243-244。

而外國法院命為伊斯蘭法之監護（*kafalah*）或其宣告之收養係屬單純收養者，於我國亦無如同我國法院依我國法認可收養所生創設養親子關係或完全收養之效力⁴¹⁹；該等裁判於我國所得發生之形成力，基於程序法上承認所據國際民事程序法之優先性（上述「參、二、（一）」），尚無庸且不得為所謂衝突法上相對化⁴²⁰。至於外國法院定親權裁判亦可能具備之執行力⁴²¹，除應先經執行宣告始能於我國發生，而與形成力之自動發生有所不同外（上述「參、一、（一）」），其內容與範圍同樣應視該外國法院所適用之法而定⁴²²：外國法院酌定父母一方為單獨親權人之裁判並未同時（明示或默示）命他方交付子女，且依其所適用之法單純親權之規制並無給付性者，於我國並無如同我國法院依我國法酌定單獨親權人所當然附隨之命交付子女效力⁴²³。

（二）外國法院裁判之變更或效力強化

承上（「參、三、（一）」）所述，外國法院定親權、認可收養未成年子女裁判滿足承認要件者，其於該外國所得發生之規制親權歸屬、創設養親子關係等效力，原則上於我國亦有之。不過，如外國法院作成裁判後情事有所改變，以致於繼續維持該裁判所形成之親權歸屬狀態不合未成年子女最佳利益，我國法院有該「未成年子女親權事件」之國際管轄權者（家事104、41 I、II），則不論外國法院定親權裁判之承認適格性是否已經承認確認程序予以判定（上述

419 參照前揭註256-257；關於伊斯蘭法之監護與收養之區別，參見Andrae (Fn. 66), § 6 Rn. 131; Harroudj v. France, App. No. 43631/09, Eur. Ct. H.R. (Oct. 4, 2012), para. 48, <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-113819>；關於單純收養與完全收養之區別，參見陳榮傳（註373），頁151-152；中西康、北澤安紀、橫溝大、林貴美（註412），頁335。

420 參照前揭註230-233。

421 關於我國法觀點下家事非訟裁判之執行力，參見許士宦，家事法（註358），頁668-669。

422 同旨：許士宦（註2），頁51-52。

423 參照前揭註246；不同見解：最高法院105年度台簡抗字第7號民事裁定。

「參、一、(二)」)，均得依我國法相關規定（如：民1055 III、V 但、1090、兒福71、72）加以變更，而以我國法院定親權裁判之效力取代之⁴²⁴；此亦可謂係比較法上之共識（上述「貳、一、(三)、2.」及「貳、二、(三)」）。此外，為妥適履行兒童權利公約第21條第3款所課予平等保障跨國與國內被收養人之義務，並謀求本國法秩序之一體性，海牙兒童收養公約及德國收養效力法有關承認效果之規定（上述「貳、一、(三)、3.」及「貳、三、(三)」），對於經承認之外國法院認可收養未成年人裁判應如何於我國發生效力之規範，甚具參考價值（兒權21 ⑤）⁴²⁵。亦即，除在立法論上宜增訂效力強化程序外，在解釋論上似亦得類推適用民法第1079條第1項之規定，允許住居於我國之被收養人或收養者，請求我國法院宣告其收養於雙方間有與依我國法所為之收養同一之效力（民1077 I），而如該收養係屬單純收養，則尚得以本生父母之同意（民1076-1、兒福18 I類推）且有助於未成年子女最佳利益（民1079-1類推）為條件，請求我國法院停止被收養人與其本生父母間之法律關係（民1077 II），而將其收養轉換為我國法上之完全收養；此等「外國收養效力強化事件」，不僅應定性為家事法第3條第6項所稱其他家事事件，亦應屬同法第74條所謂之其他家事非訟事件。

肆、結論

對於我國實務上並不罕見的外國法院家事非訟裁判之承認（及執行），我國家事法第97條（及第186條第2項）係準用非訟法第49條（及強執法第4條之1）為之。然而，非訟法第49條並未就承認程

424 沈冠伶（註7），頁341；亦參照山本和彥（註25），頁70。

425 參見VITÉ & BOÉCHAT, *supra* note 402, at 55，氏指出，聯合國兒童權利委員會經常建議締約國加入海牙兒童收養公約。

序及承認效果為明文規定，其就承認要件所設規定亦未必全然符合家事非訟事件之特性，而亟待建構穩妥之解釋論；此於外國法院針對「未成年子女親權事件」、「認可收養未成年人事件」所為裁判，尤因涉及兒童權利公約第3條所揭示未成年子女最佳利益原則之具體實踐而更形迫切。為此，本文乃以外國法院定親權、認可收養未成年人裁判為中心，參考繼受母法及國際上依循未成年子女最佳利益原則所設計之承認規範，嘗試提出運用我國法之基本方針。

要之，就承認之程序而言，應認為我國家事法雖採自動承認制，惟亦允許因（不）承認外國法院家事非訟裁判之結果而法律地位受影響之人，得聲請我國法院行家事非訟程序以裁定確認其承認適格性之有無。就承認之要件而言，應在家事法對於外國法院家事非訟裁判所採徹底之程序法上承認的基礎上，依照未成年子女最佳利益原則重構拒絕承認事由之審查，而依序回顧外國法院有無從事一定「未成年子女最佳利益之審查」、展望其裁判內容於承認判定時是否切合未成年子女最佳利益，並與相衝突之他人權益或公益進行利益衡量。就承認之效果而言，則應一面認為我國家事法原則上採取效力延伸說，一面容許我國法院變更外國法院定親權裁判及強化外國法院認可收養未成年人裁判之效力。

因此，於【事例一】，系爭美國法院指定X為A2之單獨親權人之裁判，其是否於我國發生使X取得單獨親權之形成力，有爭執者，尚非得循許可執行程序予以判定，而毋寧應循承認確認程序為之。此時，由於系爭美國法院並未從事（充分）「未成年子女最佳利益之審查」，故可（暫時）推認其裁判之承認有害於未成年子女最佳利益，惟若我國法院斟酌該裁判作成後所發生之情事，而認為維持X之單獨親權人地位更能促進A2之福祉，且不致過度侵害Y之聽審請求權，則仍不應以我國公序良俗遭違反為由拒絕加以承認。至於我國法院得否賦予系爭美國法院裁判命Y交付A2予X之執行力，則取決於該裁判依該美國法院所適用之法有無此種效力。又，

於【事例二】，系爭日本法院准許Y及B收養A之裁判，具有「承認標的適格」，應依家事法第97條、非訟法第49條之規定判斷其於我國是否發生創設Y、B及A間養親子關係及（或）斷絕X、A間權利義務之形成力，而與涉民法第54條第1項所指定之收養準據法無涉。至於系爭日本法院裁判是否具備承認適格性，則應視保持養親子關係對於A福祉之促進與對於X出養同意權、程序參與權之侵害、禁止直系血親收養之傳統倫理觀念的破壞等事間利益衡量之結果決之；如該裁判依該日本法院所適用之法僅有「單純收養」之效力，且所涉事案尚無多大之內國關連性，即應降低X權益或公益受害程度之評價。其應否承認，如有爭議，利害關係人得聲請我國法院確認系爭日本法院認可收養未成年人裁判之承認或不承認。

* * *

後記

本文脫稿後，憲法法庭作成111年憲判字第8號判決，表示受理親權事件（或其暫時處分事件）之法院直接聽取未成年子女之陳述，係憲法正當法律程序所要求（同判決段碼48-58）。此項見解，尤其在應於我國判定是否承認之外國法院定親權裁判，其所據程序（依該外國法）並未直接（親自）聽取未成年子女陳述的情形，得引發是否及如何影響我國外國親權裁判承認法之解釋適用的問題。就此，將另行撰文探討之。

參考文獻

1. 中文部分

- 小林貴典（2017），論涉外代孕案件中外國裁判之承認，臺北大學法學論叢，103期，頁193-256。
- 李太正（2018），家事事件法之理論與實務，5版，臺北：元照。
- 李後政（2015），國際民事訴訟法論，增訂3版，臺北：五南。
- 沈冠伶（2009），親權及交付子女事件之外國裁判的承認及執行與「未成年子女最佳利益保護」原則，收於：民事程序法之新變革，頁323-342，臺北：新學林。
- （2015），家事非訟裁定之效力，收於：家事程序之新變革，頁179-218，臺北：元照。
- 林沛君（2015），由聯合國兒童權利委員會第14號一般性意見重新檢視「子女最佳利益」，華岡法粹，58期，頁127-159。
- 邱聯恭（2017），口述民事訴訟法講義（三），2017年筆記版，臺北：自版。
- 施慧玲（2011），從《聯合國兒童權利公約》到子女最佳利益原則——兼談法律資訊之應用與台日比較研究方法，台灣國際法季刊，8卷2期，頁95-150。
- 柯澤東著、吳光平增修（2016），國際私法，5版，臺北：元照。
- 唐敏寶（2010），承認外國離婚與未成年子女監護裁判之間接國際管轄權——兼評最高法院93年度台上字第1943號民事判決，法令月刊，61卷7期，頁49-75。
- 徐美貞（2015），外國離婚判決承認與執行——兼論最高法院96年台上字第582號判決，真理財經法學，14期，頁79-102。
- 許士宦（2013），家事非訟之程序保障，收於：家事審判與債務執行，頁1-44，臺北：新學林。

- (2019), 家事審判之請求, 收於: 家事事件法論, 頁1-54, 臺北: 新學林。
- (2019), 許可外國民事及家事裁判執行之訴(上), 月旦法學教室, 206期, 頁46-63。
- (2020), 家事事件法, 臺北: 新學林。
- (2020), 許可外國民事及家事裁判執行之訴(下), 月旦法學教室, 208期, 頁34-54。
- 許耀明(2007), 外國確定身分判決之承認與執行, 月旦法學教室, 51期, 頁94-101。
- 陳啓垂(2001), 外國判決的承認與執行, 月旦法學雜誌, 75期, 頁147-170。
- (2014), 承認外國判決的效力及程序, 月旦法學雜誌, 235期, 頁219-234。
- 陳瑋佑(2018), 2017年民事程序法裁判回顧, 臺大法學論叢, 47卷特刊, 頁1793-1848。
- (2018), 適時審判請求權於民事程序上之侵害與救濟——試論民事法院遲延審判之國家賠償責任, 中研院法學期刊, 22期, 頁143-202。
- (2019), 國際家事管轄法之比較研究——以未成年子女親權事件為中心, 中研院法學期刊, 25期, 頁205-284。
- 陳榮傳(2008), 涉外與涉陸收養準據法之研究, 臺北大學法學論叢, 66期, 頁139-181。
- 劉鐵錚、陳榮傳(2018), 國際私法論, 修訂6版, 臺北: 三民。
- 蔡華凱(2021), 外國裁判承認執行之主、客觀範圍, 月旦法學教室, 219期, 頁26-29。
- 鄧學仁(2010), 子女最佳利益之適用爭議與發展方向, 台灣法學雜誌, 155期, 頁45-61。
- 賴淳良(2018), 外國判決效力之承認及其效力之準據法——最高法院104年度台上字第1998號判決評釋, 收於: 賴淳良編, 國

際私法裁判選析，2版，頁103-116，臺北：元照。

2. 外文部分

(1) 日文

內野宗揮（2019），一問一答 平成30年人事訴訟法・家事事件手続法等改正——國際裁判管轄法制的整備，東京：商事法務。

海老沢美広（1996），非訟事件裁判の承認，收於：澤木敬郎、煥場準一編，國際私法の争点，新版，頁246-247，東京：有斐閣。

小林秀之、村上正子（2009），國際民事訴訟法，東京：弘文堂。

中西康、北澤安紀、横溝大、林貴美（2014），國際私法，東京：有斐閣。

西谷祐子（2019），人事訴訟事件及び家事事件の國際裁判管轄等に関する新法制（2・完），法曹時報，71卷4号，頁715-762。

村上正子（2018），外国裁判の承認・執行，論究ジュリスト，27号，頁47-55。

山本和彦（2012），國際非訟事件における手続上の諸問題，判例タイムズ，1361号，頁61-72。

(2) 西文

Althammer, Christoph (2009), Verfahren mit Auslandsbezug nach dem neuen FamFG, IPRax, S. 381-388.

Andrae, Marianne (2014), Internationales Familienrecht, 3. Aufl., Baden-Baden: Nomos.

Augenhofer, Susanne (2013), in: Krüper (Hrsg.), Grundlagen des Rechts, 2. Aufl., Baden-Baden: Nomos, § 10.

Behrentin, Rolf (2020), in: Würdinger (Hrsg.), JurisPK BGB, Internationales Privatrecht und UN-Kaufrecht, Bd. 6, 9. Aufl.,

Saarbrücken: Juris, Art. 22 EGBGB.

Borrás, Alegría (1998), Erläuternder Bericht zu dem Übereinkommen aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische Union über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen, Brüssel: Rat der Europäischen Union.

Borth, Helmut/Grandel, Mathias (2018), in: Musielak (Hrsg.), Familiengerichtliches Verfahren 1. und 2. Buch FamFG, 6. Aufl., München: Franz Vahlen, §§ 108, 109.

Botthof, Andreas (2016), Anmerkung, FamRZ, S. 29-30.

——— (2019), in: Rauscher (Hrsg.), Münchener Kommentar zum FamFG, Bd. 2, 3. Aufl., München: C. H. Beck, Artt. 23, 24, 26, 27 HAdoptÜ.

Busch, Michael (2003), Adoptionswirkungsgesetze und Haager Adoptionsübereinkommen — von der Nachadoption zur Anerkennung und Wirkungsfeststellung, IPRax, S. 13-20.

Coester, Michael (2019), in: Coester/Rauscher/Salgo/Peschel-Gutzeit (Hrsg.), J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, §§ 1684 — 1717, Berlin: De Gruyter, § 1696.

Coester-Waltjen, Dagmar (2005), Die Berücksichtigung der Kindesinteressen in der neuen EU-Verordnung Brüssel IIa, FamRZ, S. 241-248.

——— (2018), Einige Überlegungen zur Kindesanhörung im familiengerichtlichen Verfahren, in: Brinkmann/Völzmann-Stickelbrock/Effer-Uhe (Hrsg.), Dogmatik im Dienst von Gerechtigkeit, Rechtssicherheit und Rechtsentwicklung. Festschrift für Hanns Prütting, Cologne: Carl Heymanns, S. 247-259.

Dimmler, Jörg (2020), in: Keidel/Engelhardt/Sternal (Hrsg.), FamFG,

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 20. Aufl., München: C. H. Beck, §§ 107, 108, 109.

Doek, Jaap. 2006. *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Articles 8-9: The Right to Preservation of Identity and the Right Not to Be Separated from His or Her Parents*. Leiden: Martinus Nijhoff.

Ernst, Rüdiger (2019), Standards für Kindesanhörungen im internationalen Familienrecht, in: Budzikiewicz/Heiderhoff/Klinkhammer/Niethammer-Jürgens (Hrsg.), Standards und Abgrenzungen im Internationalen Familienrecht, Baden-Baden: Nomos, S. 9-38.

Finger, Peter (2015), Anerkennung einer ausländischen Sorgerechtsentscheidung — deutscher ordre public, NZFam, S. 191.

Freeman, Michael. 2007. *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Article 3: The Best Interests of the Child*. Leiden: Martinus Nijhoff.

Fucik, Robert (2019), in: Gitschthaler (Hrsg.), Internationales Familienrecht, Wien: Österreich, Artt. 24, 26 HAÜ.

Garber, Thomas (2019), in: Gitschthaler (Hrsg.), Internationales Familienrecht, Wien: Österreich, Artt. 23, 24 Brüssel IIa-VO.

Geimer, Reinhold (2004), Internationale Freiwillige Gerichtsbarkeit, in: Mansel/Pfeiffer/Kronke/Kohler/Hausmann (Hrsg.), Festschrift für Erik Jayme, Bd. 1, Köln: Otto Schmidt, S. 241-262.

——— (2015), Internationales Zivilprozessrecht, 7. Aufl., Köln: Otto Schmidt.

——— (2017), Der ordre public atténué de la reconnaissance im Adoptionsrecht (OLG Hamm, S. 497), IPRax, S. 472-474.

——— (2020), in: Zöller/Althammer (Hrsg.), ZPO, 33. Aufl., Köln:

- Otto Schmidt, vor § 97 FamFG, § 109 FamFG, § 328.
- Gottwald, Peter (2019), in: Rauscher (Hrsg.), Münchener Kommentar zum FamFG, Bd. 2, 3. Aufl., München: C. H. Beck, Artt. 21, 23, 26, 28 Brüssel IIa-VO.
- (2020), in: Krüger/Rauscher (Hrsg.), Münchener Kommentar zur ZPO, Bd. 1, 6. Aufl., München: C. H. Beck, § 328.
- Hau, Wolfgang (2020), in: Prütting/Helms (Hrsg.), FamFG Kommentar, 5. Aufl., Köln: Otto Schmidt, §§ 108, 109, 110.
- Hausmann, Rainer (2018), Internationales und Europäisches Familienrecht, 2. Aufl., München: C. H. Beck, H., N., P.
- Heiderhoff, Bettina (2014), Anmerkung, FamRZ, S. 1937.
- (2017), Das Kindeswohl im internationalen Familienverfahren, in: Schütz (Hrsg.), Fairness Justice Equity, Festschrift für Reinhold Geimer zum 80. Geburtstag, München: C. H. Beck, S. 231-243.
- (2019), Kindeswohl im europäischen Familienverfahren — ein Lippenbekenntnis?, in: Budzikiewicz/Heiderhoff/Klinkhammer/Niethammer-Jürgens (Hrsg.), Standards und Abgrenzungen im Internationalen Familienrecht, Baden-Baden: Nomos, S. 39-72.
- (2020), in: Hau/Poseck (Hrsg.), BeckOK BGB, 54. Aufl., Stand: 01.05.2020, München: C. H. Beck, Art. 22 EGBGB.
- (2020), in: von Hein (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bd. 12, 8. Aufl., München: C. H. Beck, Artt. 21, 23, 26 Brüssel IIa-VO.
- von Hein, Jan (2020), in: von Hein (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bd. 12, 8. Aufl., München: C. H. Beck, Ein. IPR, Art. 6 EGBGB.
- Helms, Tobias (2020), in: von Hein (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bd. 12, 8. Aufl., München: C. H. Beck, vor § 1 AdWirkG, §§ 1, 2, 3, 4, 5 AdWirkG, Artt. 21, 22

- EGBGB, vor Art. 23 HAdoptÜ, Artt. 23, 27 HAdoptÜ.
- Henrich, Dieter (2019), in: Henrich/von Hein (Hrsg.), J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Artikel 19 — 24 EGBGB, Berlin: De Gruyter, Artt. 21, 22 EGBGB.
- (2020), in: Johannsen/Henrich/Althammer (Hrsg.), Familienrecht, 7. Aufl., München: C. H. Beck, § 109 FamFG.
- Hilbig-Lugani, Katharina (2016), in: Rauscher (Hrsg.), Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR, Bd. 5, 4. Aufl., Köln: Otto Schmidt, Artt. 23, 24, 25, 26, 27 KSÜ.
- Huter, Reinhard (2019), in: Gitschthaler (Hrsg.), Internationales Familienrecht, Wien: Österreich, Vorbem. KSÜ, vor Art. 23 KSÜ, Artt. 23, 24, 27 KSÜ.
- Junker, Abbo (2019), Internationales Zivilprozessrecht, 4. Aufl., München: C. H. Beck.
- Kischel, Uwe (2015), Rechtsvergleichung, München: C. H. Beck.
- Klicka, Thomas/Oberhammer, Paul/Domej, Tanja (2014), Außerstreitverfahren, 5. Aufl., Wien: Manz.
- Klinck, Fabian (2009), Das neue Verfahren zur Anerkennung ausländischer Entscheidungen nach § 108 Abs. II S. 1 FamFG, FamRZ, S. 741-749.
- Kodek, Georg E. (2013), Rechtsvergleichung als Auslegungsmethode im Privatrecht — akademischer Aufputz oder Bereicherung?, in: Gamper/Verschraegen (Hrsg.), Rechtsvergleichung als Juristische Auslegungsmethode, Wien: Jan Sramek, S. 23-52.
- Krah, Jutta (2004), Das Haager Kinderschutzübereinkommen, Bern: Peter Lang.
- Kropholler, Jan (2001), Internationales Privatrecht, 4. Aufl., Tübingen: Mohr Siebeck.

- Lagarde, Paul (1998). *Explanatory Report on the 1996 Hague Child Protection Convention*. Hague: HCCH-Publications.
- Lange, Gesine (2001), Die Adoption nach internationalem Recht, FPR, S. 327-331.
- Loyal, Florian (2018), Zur Struktur und Dogmatik der Anerkennung ausländischer Gerichtsentscheidungen, ZZP 131, 373-398.
- Majer, Christian F. (2015), Die Anerkennung ausländischer Adoptionsentscheidungen, NZFam, S. 1138-1142.
- (2019), Anerkennung einer Auslandsadoption (Gambia), NZFam, S. 696.
- (2020), OLG Frankfurt a. M.: Nichtanerkennung einer Adoptionsentscheidung mangels Kindeswohlprüfung, NZFam, S. 46.
- Markus, Alexander R. (2014), Internationales Zivilprozessrecht, Bern: Stämpfli.
- Meyer-Holz, Ulrich (2020), in: Keidel/Engelhardt/Sternal (Hrsg.), FamFG, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 20. Aufl., München: C. H. Beck, § 238.
- Nademleinsky, Marco/Neumayr, Matthias (2017), Internationales Familienrecht, 2. Aufl., Wien: Facultas.
- Nagel, Heinrich/Gottwald, Peter (2013), Internationales Zivilprozessrecht, 7. Aufl., Köln: Otto Schmidt, § 12.
- Ohler, Christoph (2009), in: Merten/Papier (Hrsg.), Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, Bd. VI/2, Heidelberg: C. F. Müller, § 184.
- Parra-Aranguren, Gonzalo. 1994. *Explanatory Report on the 1993 Hague Intercountry Adoption Convention*. Hague: HCCH-Publications.
- Rauscher, Thomas (2016), in: Rauscher (Hrsg.), Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR, Bd. 3, 4. Aufl.,

- Köln: Otto Schmidt, Artt. 21, 23, 26, 46 Brüssel IIa-VO.
- (2018), in: Rauscher (Hrsg.), Münchener Kommentar zum FamFG, Bd. 1, 3. Aufl., München: C. H. Beck, §§ 108, 109.
- Reimer, Franz (2016), Juristische Methodenlehre, Baden-Baden: Nomos.
- Reuß, Philipp (2015), Gestaltung des europäischen abstammungsrechtlichen Kaleidoskops — Einige Überlegungen zur Anerkennung der niederländischen Duo-Mutterschaft in Deutschland, in: Hilbig-Lugani/Jakob/Mäsch/Reuß/Schmid (Hrsg.), Zwischenbilanz — Festschrift für Dagmar Coester-Waltjen zum 70. Geburtstag, Bielefeld: Giesecking, S. 681-696.
- Roth, Herbert (2015), in: Bork/Roth (Hrsg.), Stein/Jonas Kommentar zur Zivilprozessordnung, Bd. 5, 23. Aufl., Tübingen: Mohr Siebeck, § 328.
- (2018), Ordnungsgemäße Zustellung und ausreichende Wahrnehmung der Verteidigungsmöglichkeit des Beteiligten als kumulative Erfordernisse für die Anerkennung nach § 109 Abs. 1 Nr. 2 FamFG, IPRax, S. 606-608.
- Schack, Haimo (2010), Das Anerkennungsverfahren in Ehesachen nach § 107 FamFG — Vorbild für Europa?, in: Bernreuther/Freitag/Leible/Sippel/Wanitzek (Hrsg.), Festschrift für Ulrich Spellenberg zum 70. Geburtstag, Köln: Otto Schmidt, S. 497-510.
- (2015), „Anerkennung“ ausländischer Entscheidungen, in: Becker-Eberhard/Gaul/Haertlein/Meller-Hannich (Hrsg.), Rechtslage — Rechtserkenntnis — Rechtsdurchsetzung. Festschrift für Eberhard Schilken zum 70. Geburtstag, München: C. H. Beck, S. 445-456.
- (2017), Internationales Zivilverfahrensrecht mit internationalem Insolvenzrecht und Schiedsverfahrensrecht, 7. Aufl., München: C. H. Beck.
- Schilling, Theodor (2010), Internationaler Menschenrechtsschutz, 2. Aufl., Tübingen: Mohr Siebeck.

- Schmahl, Stefanie (2017), *Kinderrechtskonvention mit Zusatzprotokollen*, 2. Aufl., Baden-Baden: Nomos, Einl., Artt. 3, 9, 20/21.
- Schulz, Andrea (2019), *Das Vollstreckungssystem in der neuen Brüssel IIa-Verordnung*, in: Budzikiewicz/Heiderhoff/Klinkhammer/Niethammer-Jürgens (Hrsg.), *Standards und Abgrenzungen im Internationalen Familienrecht*, Baden-Baden: Nomos, S. 93-122.
- Sieghörtner, Robert (2020), in: Hahne/Schlögel/Schlünder (Hrsg.), *BeckOK FamFG*, 35. Aufl., Stand: 01.07.2020, München: C. H. Beck, §§ 106, 108, 109.
- Spellenberg, Ulrich (2016), in: Spellenberg/Henrich (Hrsg.), *J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: Internationales Verfahrensrecht in Ehesachen*, Bd. 2, Berlin: De Gruyter, §§ 108, 109 FamFG.
- Sternal, Werner (2020), in: Keidel/Engelhardt/Sternal (Hrsg.), *FamFG, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit*, 20. Aufl., München: C. H. Beck, § 23.
- Treichel, Stefan (2020), *Kindergrundrechte und Partizipation*, JZ, S. 653-660.
- Vité, Sylvain, and Hervé Boéchat. 2008. *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Article 21: Adoption*. Leiden: Martinus Nijhoff.
- Wagner, Rolf (2006), *Anerkennung und Wirksamkeit ausländischer familienrechtlicher Rechtsakte im autonomen Recht*, FamRZ, S. 744-753.
- (2013), *Ausländische Entscheidungen, Rechtsgeschäfte und Rechtslagen im Familienrecht aus der Sicht des autonomen deutschen Rechts — Eine Neubearbeitung*, FamRZ, S. 1620-1630.
- Weitzel, Wolfgang (2007), *Zur Anerkennung ausländischer*

Adoptionsentscheidungen (AG Hamm, S. 326 und LG Karlsruhe, S. 328), IPRax, S. 308-312.

—— (2013), Adoptionswirkungsgesetz (2012), 2. Aufl., Baden-Baden: Nomos.

Zimmermann, Walter (2003), in: Keidel/Kuntze/Winkler (Hrsg.), Freiwillige Gerichtsbarkeit, 15. Aufl., München: C. H. Beck, § 16a.

Recognition of Foreign Judgments on Matters of Parental Responsibility and Child Adoption:

A Comparative Study on Taiwanese Law, German Law, EU Law and the Hague Convention

*Wei-Yu Chen**

Abstract

It is common for foreign judgments on non-contentious family matters to be recognized and enforced in Taiwan. In this regard, Article 49 of the Taiwanese Non-Contentious Proceedings Act and Article 4-1 of Compulsory Enforcement Act states that it shall be applied pursuant to Article 97 and Article 186 II of the Taiwanese Family Act. However, Article 49 of Non-Contentious Proceedings Act does not explicitly regulate the procedural aspect of recognition of foreign judgments and the aspect concerning its effects is also missing; the said provision does not seem to provide satisfactory solutions in regard to the conditions of recognition of foreign judgments. Hence, it is imperative to cover the lack of regulation and review the current rules of recognition of foreign judgments. Moreover, when it comes to foreign judgments on matters of parental responsibility or child adoption, the current statutory status becomes more problematic, since the principle of the best interests of the child revealed in Article 3 of the Convention on the Rights of the Child must come into play; this gives rise to the question of how the principle should function in concrete terms. In this vein, this article will first conduct a comparative study on the German, EU law and the relevant Hague Conventions. The result of this comparative study will then serve

* Associate Professor, College of Law, National Taiwan University.

as basis for reviewing Taiwanese law on the recognition of foreign judgments, in particular with regard to the practical application of the principle of the best interests of the child. This article will conclude with guidelines for interpretation of Article 49 of the Taiwanese Non-Contentious Proceedings Act as well as proposals for legislative reform.

KEYWORDS: recognition and enforcement of foreign judgments, Convention on the Rights of the Child, best interests of the child, recognition by operation of law, public policy, the theory of effect extension.